

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 기본강의 1회

<p.4 법치행정 의 원칙(행정기본법 제8조)>

01. 법치주의의 의의, 근거, 내용에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 법치주의의 의의·근거(행정기본법 제8조)
II. 법치주의의 내용
1. 법률의 법규창조력
2. 법률우위의 원칙
3. 법률유보의 원칙

I. 법치주의의 의의·근거(행정기본법 제8조)

법치주의란 행정이 법률의 범위 내에서 이루어져야 한다는 원칙으로 정당한 법에 의한 통치를 하여야 한다는 통치 원리를 말한다. 법치주의는 협의로는 지배자의 자의 배제를 목적으로 공권력의 행사는 의회가 제정한 법률에 따라야 한다는 형식적 법치주의를 의미하고, 광의로는 법률의 제정과 그 적용에 있어서도 국민의 권리·의무를 최대한 보장할 수 있어야 한다는 실질적 법치주의를 의미한다.

II. 법치주의의 내용

1. 법률의 법규창조력

법률의 법규창조력이란 적법한 절차에 따라 의회에서 제정된 법률만이 국민의 권리·의무에 영향을 줄 수 있다는 것을 말한다. 헌법 제40조에 따라 법규는 의회에 의해 만들어지고 이러한 법률만이 국민의 권리·의무에 영향을 줄 수 있다.

2. 법률우위의 원칙(헌법 제107조 제2항)

1)의의

법률우위의 원칙이란 모든 행정작용은 법률에 위반되어서는 안 된다는 것을 의미한다. 행정의 법률에의 구속성으로 위반 시 이는 위법이 되어 무효(법규명령, 조례)나 취소사유(행정행위)가 된다.

2)법률의 범위와 적용범위

법률우위의 원칙에서 말하는 법률은 헌법과 국회가 제정한 법률을 말한다. 또한, 헌법 제75조 및 95조에 근거한 법규명령(대통령령·총리령·부령)도 포함되고, 행정법의 일반원칙 등 불문법을 포함한 모든 법규를 의미한다.

3)위반의 효과

법률우위의 원칙은 모든 행정 영역에 적용되며 위반 시 위법한 행정작용이 된다. 위법한 행정작용의 효력은 행정의 행위형식에 따라 다르게 나타난다. 즉, 행정행위의 경우 중대·명백설에 따라 무효 또는 취소의 대상이 되고 행정입법, 공법상 계약은 특별한 사정이 없는 한 무효가 된다. 또한, 위법한 행정작용으로 손해가 발생한 경우 손해배상책임이 인정될 수도 있다.

3. 법률유보의 원칙

1) 의의 및 법률의 범위

①법률유보의 원칙이란 행정작용은 법률에 근거하여야 한다는 원칙을 의미한다. 법률우위의 원칙은 소극적으로 기존 법률의 침해를 금지하는 것이지만, 법률유보의 원칙은 적극적으로 법률제정을 요구하는 것이다. ②법률의 유보에 있어서 법률은 원칙적으로 국회에서 법률제정의 절차에 따라 만들어진 형식적 의미의 법률을 의미한다. 그러나 헌법 제75조 및 제95 조에 따라 상위법령의 위임을 받아 제정된 법규명령(대통령령·총리령·부령)은 '법률'에 포함된다.

2) 적용범위

①행정은 복잡성·다양성을 가지고 있어 탄력적 대응이 필요하다. 이에 법률유보의 원칙의 적용범위에 대한 견해가 대립한다. ②학설은 침해유보설, 급부유보설, 중요사항유보설, 전부유보설 등 견해가 대립하나 ③판례는 중요사항유보설을 취한다. ④생각건대, 행정기본법 제8조 2문에서 '국민생활에 중요한 영향을 미치는 경우에는 법률에 근거하여야 한다'고 규정하고 있고, 국민의 기본권 보장과 행정의 탄력적 운영의 조화가 중요하므로, 중요사항유보설이 타당하다.

<p.6 평등의 원칙(행정기본법 제9조)>

02. 甲과 乙은 모두 토지보상법 제78조에 따른 이주대책대상자이다. 그런데 합리적인 이유 없이 甲에게는 24평형의 아파트를 공급하고, 乙에게는 32평형의 아파트를 공급하였다. 이에 甲은 평등의 원칙 위반을 주장한다. 甲 주장의 타당성을 검토하시오. (5점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 의의 및 근거(헌법11조 및 행정기본법 제9조)
III. 요건 및 한계
IV. 사안의 해결(甲주장 타당함)

I. 쟁점의 정리

동일 사안에 대해 합리적 이유 없는 차별이 있는 상황으로 평등의 원칙 위반이 문제되는바, 乙 주장의 타당성을 검토한다.

II. 의의 및 근거(헌법11조 및 행정기본법 제9조)

평등의 원칙이란 행정기관은 행정작용을 함에 있어 특별히 합리적인 사유가 존재하지 않는 한, 그 상대방인 국민을 공평하게 대우해야 한다는 것을 의미한다. 자의금지의 원칙이라고도 하며, 재량권 행사의 한계원리로서 중요한 의미를 갖는다. 근거로는 헌법 제11조 및 행정기본법 제9조가 있다.

III. 요건 및 한계

평등의 원칙은 ① 모든 행정작용에 적용되며, ② 차별에 합리적 이유가 없을 것을 요건으로 한다. 한계로서 평등의 원칙은 불법에는 적용되지 않는다.

IV. 사안의 해결(甲주장 타당함)

토지보상법 제78조의 이주대책 수립, 실시의무는 강행규정이나, 공급할 주택 등의 내용이나 수량 등을 정하는 데 재량을 가진다고 판시한다. 그러나 재량권이 인정된다고 하더라도 甲과 乙에게 다른 내용의 주택을 공급하는 것은 합리적인 이유가 없어 평등의 원칙에 위배된다.

<p.7 자기구속의 원칙(평등의 원칙 파생법리)>

03. 국토교통부장관은 내부규칙으로 10년간 징계기록이 없이 업무를 영위해온 감정평가법인등이 업무정지를 받을 경우 당해 업무정지 기간에 1/2 감경사유를 적용하는 내용을 규정한 뒤 수년간 적용해왔다. A법인은 수수료 요율 1회 위반으로 업무정지 1개월의 징계를 받았다. A법인은 10년간 무사고 감정평가법인으로 1/2 감경사유 적용이 배제된 것에 대해 자기구속 원칙 위반을 주장한다. 주장의 타당성을 검토하시오. (단, 업무정지는 재량행위이다.) (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 의의 및 근거(평등의 원칙 파생법리)
III. 요건
IV. 한계
V. 사안의 해결(乙주장 타당함)

I. 쟁점의 정리

재량행위인 업무정지 처분 시 동일 사안에 대해 동일 처분을 하여야 함에도 다른 처분이 내려진 사안으로 자기구속 원칙 위반 주장의 타당성을 검토한다.

II. 의의 및 근거(평등의 원칙 파생법리)

자기구속의 원칙이란 재량행위에 있어서 행정청은 동일한 사안에 대하여

이전에 한 처분과 동일한 처분을 하여야 한다는 원칙을 말한다. 재량행위에 있어 행정권의 자의를 방지하는 기능을 수행하며, 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙을 근거로 자기구속의 원칙을 인정하는 것이 일반적이다.

III. 요건

① 재량행위의 영역일 것, ② 동종의 사안일 것, ③ 동일한 행정청일 것, ④ 행정선례가 존재할 것을 요건으로 한다. 행정선례에 대해 견해대립이 있으나 판례는 반복적 선례가 되풀이되어 행정관행이 있어야 한다고 본다. 생각건대, 1회 선례 충분설은 행정을 경직화시킬 우려가 있고, 선례불요설은 행정규칙의 법규성을 인정하는 결과를 초래하는바 판례 입장이 타당하다.

IV. 한계

① 기속행위에는 인정될 수 없고, 성문의 법규를 보충하는 것으로서 ② 위법한 처분에 대하여는 인정되지 않는다. 또한 ③ 행정관행이 성립되었다 하더라도, 행정청이 행정선례와 다른 결정을 하여야 할 공익상 필요 등 특별한 사정이 있는 경우에는 자기구속의 원칙이 배제될 수 있다.

V. 사안의 해결(A법인 주장 타당함)

(자유롭게 검토해보세요)

<p.8 비례의 원칙(행정기본법 제10조)>

04. 토지보상법 20조 사업인정의 공익성에 대한 판단인 비례 원칙에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 의의 및 근거 II. 내용 (요건) 1. 적합성의 원칙 (수단의 적정성) 2. 필요성의 원칙 (최소침해의 원칙) 3. 상당성의 원칙 (협의의 비례원칙) 4. 상호관계 III. 판례

I. 의의 및 근거

비례의 원칙이란 행정목적과 행정수단 사이에 합리적 비례관계가 있어야 한다는 원칙을 말한다. 헌법 제37조 제2항, 행정기본법 제10조 및 행정절차법 제48조 제1항과 개별법 등에 근거가 있다.

II. 내용 (요건)

1. 적합성의 원칙 (수단의 적정성)

적합성의 원칙이란 행정기관은 행정목적 달성을 위해 유효하고 적절한 수단을 선정하여야 한다는 것을 의미 한다. 목적 달성을 위해 가능한 수단이 여러 개가 있는 경우 모든 수단이 법령상 허용되는 것이라면 이들 중 어떤 것을 취하더라도 적합성원칙에는 위반되지 않는다.

2. 필요성의 원칙 (최소침해의 원칙)

필요성의 원칙이란 적합한 수단이 여러 가지라면 그 중에서 국민의 권리나 자유에 대한 침해가 가장 적은 수단을 선택해야 하는 것을 의미한다. 이를 최소침해의 원칙이라고도 하며, 개인이나 공중에 최소한의 침해를 주는 수단을 선정할 것을 요구하는 원칙이다.

3. 상당성의 원칙 (협의의 비례원칙)

상당성의 원칙이란 행정작용을 함에 있어 달성되는 공익보다 침해되는 국민의 권익이 더 크다면 그러한 행정조치를 취해서는 안 된다는 원칙을 말한다. 이는 협의의 비례원칙이라고도 하며, 공익과 사익 간의 이익형량을 통해 판단한다.

4. 상호관계

적합성의 원칙, 필요성의 원칙과 상당성의 원칙은 단계적 구조를 이루고, 적합의 원칙부터 상당성의 원칙까지 단계적으로 심사를 하여 비례의 원칙의 위반 여부를 판단한다.

III. 판례 (사업인정의 공익성에 대한 판단 : 비례의 원칙)

사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용 또는 사용할 사업으로 결정하는 것으로서 공익사업의 시행자에게 그 후일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 일정한 내용의 수용권을 설정하여 주는 형성행위이므로, 해당 사업이 외형상 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 사업에 해당한다고 하더라도 사업인정기관으로서 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부와 공익성이 있는 경우에도 그 사업의 내용과 방법에 관하여 사업인정에 관련된 자들의 이익을 공익과 사익 사이에서는 물론, 공익 상호간 및 사익 상호간에도 정당하게 비교·교량하여야 하고, 그 비교·교량은 비례의 원칙에 적합하도록 하여야 한다.

<p.9 성실의무 및 권한남용금지의 원칙 (「행정기본법」제11조)>

대법원 2011. 1. 27. 선고 2009두1051 판결
 사업인정을 받은 후 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성을 상실하여 관련된 자들의 이익이 현저히 비례의 원칙에 어긋나게 된 경우 또는 의사나 능력을 상실하였음에도 여전히 그 사업인정에 기하여 수용권을 행사하는 것은 수용권의 남용에 해당한다.

05. 상기 '수용권의 남용'을 성실의무 및 권한남용금지의 원칙 관련하여 설명하시오. (5점)

목차
I. 성실의무 및 권한남용금지의 원칙 의의 및 근거(행정기본법 제11조) II. 적용범위 III. 수용권 남용

I. 성실의무 및 권한남용금지의 원칙 의의 및 근거(행정기본법 제11조)

성실의무의 원칙이란 행정청이 법령등에 따른 의무를 성실히 수행하여야 한다는 원칙을 말하고, 권한남용금지의 원칙이란 행정청이 주어진 행정권한을 남용하거나 그 권한의 범위를 넘어서는 안된다는 원칙을 말한다. 행정기본법 제11조에 규정되어 있으며, 행정청의 의무와 권한의 범위에 관해 명문화한 것이다.

II. 적용범위

성실의무 및 권한남용금지의 원칙은 모든 행정작용에 적용되는 것으로 수익적 행정, 침해적 행정 및 급부행정 등모든 분야에서 적용된다.

III. 수용권 남용

사업인정을 받은 후 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성을 상실하여 관련된 자들의 이익이 현저히 비례의 원칙에 어긋나게 된 경우 또는 의사나 능력을 상실하였음에도 여전히 그 사업인정에 기하여 수용권을 행사하는 것은 수용권의 남용에 해당한다. 즉, 수용권한의 남용으로 권한남용금지의 원칙 위반이다.

<p.9 신뢰보호의 원칙 (「행정기본법」제12조)>

06. S시장은 2006년 5월 甲의 토지를 제2종전용주거지역으로 지정하였다. 甲은 이를 신뢰하여 자신의 토지에 용적률150%의 주택을 짓기 위한 준비를 하였다. S시장은 2010년 3월 도시근린공원을 조성하고자 甲의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정하였다. 甲은 2010년 3월 그의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정한 것은 신뢰보호 원칙 위반이라고 주장한다. 甲의 주장의 타당성을 검토하시오. (10) [기출24회 1-1 변형]

목차
I. 의의 및 근거(행정기본법 제12조)
II. 요건 및 한계
III. 甲 주장의 타당성(타당성 없음)

I. 의의 및 근거(행정기본법 제12조)

신뢰보호원칙이란 행정기관이 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다는 원칙을 말한다. 법적 안정성, 신의칙 및 사회국가원리에서 이론적 근거를 찾을 수 있고, 실정법으로는 행정기본법 제12조, 행정절차법 제4조 제2항 등을 근거로 들 수 있다.

II. 요건 및 한계

1. 행정기관의 선행조치(공적인 견해표명)

행정기관의 상대방인 국민에 대한 신뢰를 주는 어떠한 선행조치가 있어야 한다. 선행조치는 법령, 행정행위, 확약, 행정계획, 행정지도 등 국민이 신뢰를 가질 수 있는 일체의 조치를 말한다.

2. 보호가치 있는 신뢰 (상대방의 무귀책)

선행조치에 대한 상대방의 신뢰가 보호가치 있는 것이어야 한다. 즉, 상대방 등에게

귀책사유가 있어서는 안 되는데, 상대방의 귀책사유란 사기 등 부정행위에 의한 것뿐만 아니라 행정청의 견해표명에 하자가 있음을 알았거나 중대한 과실로 알지 못한 경우까지 포함한다.

3. 상대방의 조치 및 인과관계

상대방이 행정기관의 선행조치에 대한 신뢰에 입각하여 어떠한 조치를 취하여야 한다. 신뢰보호의 원칙의 목적은 선행조치를 믿고 어떠한 행위를 한 사인을 보호하기 위한 것이므로 단순히 선행조치를 신뢰한 것만으로는 부족하고, 사인의 후행 조치가 필요하다. 또한 이러한 행정기관의 선행조치와 이를 신뢰하고 행한 국민의 조치 사이에는 상당한 인과관계가 있어야 한다.

4. 선행조치에 반하는 후행행위와 권익침해

행정기관이 선행조치를 하였고 이를 신뢰한 상대방이 일정한 조치를 하였는데, 행정기관이 상대방의 신뢰에 반하는 행정권의 행사를 하여 상대방의 권익이 침해되어야 한다. 즉, 선행조치에 반하는 후행행위로 인해 구체적인 사인의 권익 침해가 있을 것을 요건으로 한다.

5. 한계(공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 없을 것)

①신뢰보호 원칙은 법적안정성을 위한 것이나, 행정청의 공적견해의 표명이 법률에 적합하지 않은 경우에도 개인의 신뢰와 그에 따른 행위가 보호받아야 하는지 관련하여 견해가 나뉜다. 공사의 비교형량하여 구체적으로 결정함이 타당하다. ②행정청의 공적견해표명에 따른 후속행위로 다른 제3자의 사익이 침해 되는 경우 당해 행정행위로 인하여 달성되는 공익과 관련 당사자의 손해를 종합적으로 비교형량하여 구체적으로 결정하여야 한다.

III. 甲 주장의 타당성(타당성 없음)

①S시장의 2006년5월 甲 토지에 대한 주거지역 지정은 주거지역을 유지하거나 녹지지역으로 변경하지 않겠다는 취지의 공적인 견해표명으로 볼 수 없다. ②甲은 S시장의 주거지역 지정에 대한 신뢰에 입각하여 주택 건축을 위한 준비행위를 하였더라도 그 사정만으로 ③S시장의 도시계획변경결정이 행정청의 공적인 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 그 견해표명을 신뢰한 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래된 것이라고 볼 수 없다. ④甲 주장은 타당하지 않다.

<p.12 부당결부금지의 원칙 (「행정기본법」제13조)>

07. 지방자치단체장이 사업자에게 주택사업계획승인을 하면서 그 주택사업과는 아무런 관련이 없는 토지를 기부채납하도록 부관을 주택사업계획승인에 불인 경우 부당결부금지 원칙에 위반되는지 검토하시오. (10)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 관련행정작용의 법적성질
III. 부당결부금지 원칙(「행정기본법」제13조)
1. 의의 및 근거
2. 요건
IV. 사안의 해결(부당결부금지 원칙 위반)

I. 쟁점의 정리

지방자치단체장이 주택사업계획승인을 하면서 그와 무관한 토지 기부채납 부관을 불인 것이 부당결부금지 원칙 위반인지 검토한다.

II. 관련행정작용의 법적성질

주택사업계획승인은 사업인정의제로 처분이며, 기부채납은 부관 중 급부하명의 성격을 갖는 부담으로 볼 수 있다.

III. 부당결부금지 원칙(「행정기본법」제13조)

1. 의의 및 근거

부당결부금지의 원칙이란 행정기관이 행정작용을 함에 있어 상대방에게 그것과 실질적인 관련이 없는 반대급부를 결부시켜서는 안 된다는 원칙을 말한다. 부당결부금지의 원

칙은 헌법상 법치국가 원칙과 자의금지 원칙에서 그 이론적 근거를 찾을 수 있고, 실정법상 행정기본법 제13조에 그 근거가 있다.

2. 요건

부당결부금지의 원칙의 요건으로 ① 행정청의 공권력 행사가 있을 것, ② 공권력의 행사가 상대방의 반대급부와 결부되어 있을 것, ③ 공권력의 행사와 반대급부 사이에 실질적 관련성이 없을 것이 있다. 실질적 관련성은 원인적 관련성과 목적적 관련성을 그 내용으로 하며, 부당결부금지의 원칙은 행정행위의 부관에서 주로 적용된다.

IV. 사안의 해결(부당결부금지 원칙 위반)

① 지방자치단체장의 주택사업계획승인이라는 행정청의 공권력 행사가 있었다. ② 주택사업계획승인에 기부채납이라는 상대방의 반대급부와 결부되어 있었다. ③ 주택사업계획승인과 기부채납 사이에 직접적인 인과관계도 없고, 주택사업이라는 동일한 행정목적도 추구하지 않고 있는바, 실질적 관련성이 없다. ④ 따라서 사안은 부당결부금지 원칙에 위반된다.

<p.13 공법관계와 사법관계>

08. 공법관계와 사법관계에 대해 설명하고, 공무수탁사인에 대해 설명하시오.
(10)

목차
I. 공법관계와 사법관계 1. 개념 2. 구별기준 1)학설 2)판례 3)소결 II. 공무수탁사인 1. 의의 2. 행정법 관계의 당사자 중 행정 주체

I. 공법관계와 사법관계

1. 개념

법률관계란 법에 의해 규율되는 권리, 의무 관계를 의미한다. 법률관계는 크게 공법관계와 사법관계로 구분할 수 있으며 소송, 관할법원, 공정력 인정 여부 등에 차이가 있어 구분의 실익이 있다.

2. 구별기준

1)학설

공법관계인지 사법관계인지는 법규정이 구분의 1차적 기준이 된다. 법규정 해석으로도 구분이 불분명할 경우 어떤 기준으로 공법관계 또는 사법관계로 볼 것인지에 대해서는 학설이 대립하는데, ① 주체가 행정주체이면 공법관계로 보는 <주체설>, ② 법률관계가 상하관계이면 공법관계로 보는 <종속설>, ③ 법률관계가 공익을 위한 것이면 공법관계로 보는 <이익설>, ④ 권리의무의 귀속주체가 공권력 주체이면 공법관계로 보는 <귀속

설>, ⑤ 위 기준을 종합 참작해야 한다고 보는 <복수기준설> 등이 있다.

2)판례

(1) 공법관계 (보상금증감청구소송 및 주거이전비)

토지보상법에 따라 손실보상금의 증액을 구하는 소송은 공법상 당사자 소송으로 보며, 동법에 따른 주거이전비 지급을 구하는 소송도 공법상 당사자 소송으로 본다. 또한, 도시 및 주거환경정비법에 의한 재개발조합에 대한 조합원 지위 확인을 구하는 소송도 공법상 당사자 소송으로 본다.

(2) 사법관계(공익사업을 위한 협의취득, 환매권)

토지보상법에 의한 협의취득은 사법상의 법률행위로 보고, 토지보상법에 따른 환매권 행사로 인한 매매도 사법상의 매매로 보아 민사소송에 의한다. 또한 환매금액의 증감을 구하는 소송도 민사소송에 의한다.

3)소결

근거법규가 행정주체에게 우월적 지위를 부여하고 있거나 공익실현을 직접적인 목적으로 하고 있다면 공법관계로 보아야 하며, 근거법규가 명확하지 않을 경우 근거법규의 목적, 내용과 당해 행위의 성질 등을 종합적으로 검토하여 결정하는 것이 타당하다.

II. 공무수탁사인

1. 의의

공무수탁사인이란 공적인 행정 영역에서 행정 권한이나 공권력적인 지위를 부여받아 행정행위를 자기 이름과 자기책임으로 행하는 사인을 말한다. 예로는 「토지보상법」상 사업인정을 받은 사업시행자가 있다.

2. 행정법 관계의 당사자 중 행정 주체

행정주체란 행정권을 행사하고 그 행위의 법적 효과(권리·의무의 생성, 변경, 소멸 등)가 궁극적으로 귀속되는 당사자를 말한다. 예로는 국가, 지방자치단체, 공공조합과 공무수탁사인 등이 있다. 행정주체는 행정기관을 통해 행정사무를 처리한다. 행정기관을 포괄하는 개념으로 행정기관의 대표를 행정청이라고 한다.

<p.15 공권>

09. 개인적 공권에 대해 설명하시오. (10)

목차
I. 개설
II. 개인적 공권
1. 의의
2. 성립요건

I. 개설

공법관계는 공법상의 권리·의무를 말하는데, 그 중 공권은 공법관계에서의 권리를 의미한다. 공권은 귀속주체에 따라 국가가 가지는 국가적 공권과 개인이 가지는 개인적 공권으로 구분할 수 있다. 공권은 사권 및 공의무에 대응하는 개념으로 공적 의무이다.

II. 개인적 공권

1. 의의

개인적 공권이란 개인이 직접 자기의 이익을 위하여 행정주체에게 일정한 행위를 할 것을 요구할 수 있는 법적인 힘을 말한다.

2. 성립요건

1) 강행법규의 존재

제1요건으로 행정주체에게 일정한 의무를 부과하는 강행법규가 존재하여야 한다. 원칙적으로 행정청의 행위가 기속행위의 성질을 가져야 하기에 과거에는 행정주체에게 재량이 인정되는 경우 공권이 성립될 수 없다고 보았지만, 오늘날에는 공권의 확대화 경향에 따라 재량행위에도 일정한 공권이 성립할 수 있다고 본다.

2) 사익보호성

제2요건으로 관련법규가 사익보호를 목적으로 하여야 한다.

사익보호의 판단기준은 처분의 근거법규 및 관련 법규의 목적, 취지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

<p. 18 수리거부의 처분성>

토지보상법 29조 3항

사업시행자가 협의가 성립된 토지의 소재지·지번·지목 및 면적 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 「공증인법」에 따른 공증을 받아 제1항에 따른 협의 성립의 확인을 신청하였을 때에는 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의 성립이 확인된 것으로 본다.

10. 토지보상법 29조 3항의 협의성립확인 신청을 행위요건적 신고로 볼 수 있는지 검토하고, 요건을 갖추지 못한 협의성립확인 신청에 대해 토지수용위원회가 신청을 수리하였다면 그 수리는 행정소송법상 '처분'의 개념에 해당하는지 검토하시오. (20)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 토지보상법 29조3항

III. 토지보상법 29조3항 협의성립확인 신청과 행위요건적 신고

1. 자기완결적 신고(수리를 요하지 않는 신고)
2. 행위요건적 신고(수리를 요하는 신고)
3. 구별기준
 - 1)관련규정
 - 2)학설
 - 3)판례
4. 검토

IV. 행위요건적 신고에서 '수리'가 행정소송법상 '처분'인지

1. 자기완결적 신고(수리를 요하지 않는 신고)

2. 행위요건적 신고(수리를 요하는 신고)
3. 판례
4. 검토

I. 쟁점의 정리

토지보상법 29조 3항의 협의 성립 확인 신청을 행위요건적 신고로 볼 수 있는지 법령의 목적을 기준으로 검토하고, 요건을 갖추지 못한 협의성립확인 신청에 대해 토지수용위원회가 수리하였다면 그 '수리'를 행정소송법상 '처분'으로 볼 수 있는지 판례를 통해 검토한다.

II. 토지보상법 29조3항

사업시행자가 협의가 성립된 토지의 소재지·지번·지목 및 면적 등 대통령령으로 정하는 사항에 대하여 「공증인법」에 따른 공증을 받아 제1항에 따른 협의 성립의 확인을 신청하였을 때에는 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의 성립이 확인된 것으로 본다.

III. 토지보상법 29조3항 협의성립확인 신청과 행위요건적 신고

1. 자기완결적 신고(수리를 요하지 않는 신고)

자기완결적 신고란 사인이 행정청에 대하여 일정한 사항을 통지하고 통지가 행정청에 도달함으로써 효과가 발생하는 신고를 말한다. 자기완결적 신고가 본래적 의미의 신고에 해당하며, 행정절차법 제40조를 자기완결적 신고의 근거로 보는 것이 다수설의 입장이다.

2. 행위요건적 신고(수리를 요하는 신고)

행위요건적 신고란 법령 등에 의하여 행정청에게 일정한 사항을 통지하고 행정청이 이를 수리함으로써 법적 효과가 발생하는 신고를 말한다. 변형적 신고라고도 불리며 실정법상 등록이라고도 한다.

3. 구별기준
 - 1)관련규정

행정기본법 제34조는 “법령등으로 정하는 바에 따라 행정청에 일정한 사항을 통지하여야 하는 신고로서 법률에 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있는 경우(행정기관의 내부 업무 처리 절차로서 수리를 규정한 경우는 제외한다)에는 행정청이 수리하여야 효력이 발생한다.”고 규정하고 있다.

2)학설

① 신고 요건이 형식적 요건만을 요구하는 경우에는 자기완결적 신고로 보고, 실질적 요건도 포함하는 경우 수리를 요하는 신고로 보는 <신고요건기준설>, ② 해당 법령의 목적과 문언에 대한 합리적이고 유기적인 해석을 통해서 구분하는 <법령해석기준설>, ③ 형식적 심사만 하는 경우는 자기완결적 신고로 보고, 실질적 심사까지 하는 경우에는 수리를 요하는 신고로 보는 <심사방식기준설> 등이 있다.

3)판례

판례는 실질적 적법요건을 두지 않고 형식적 요건만을 규정한 경우 자기완결적 신고로 보고, 근거 법에서 그 대상행위를 원칙적으로 금지하여 실질적 적법요건을 두고 있는 때에는 해당 신고의 수리를 거부할 수 있다고 보아 수리를 요하는 신고로 본다.

4. 검토

자기완결적 신고와 수리를 요하는 신고는 일차적으로 법령의 목적을 기준으로 판단하는 것이 타당하다. 다만, 그 해석이 명확하지 않는 경우에는 신고요건의 내용에 실질적 요건이 포함되어 있는지를 판단기준으로 삼아 다른 법령상의 요건 충족을 전제로 하거나 그 신고가 인·허가의제의 효과를 갖는 경우에는 수리를 요하는 신고라고 봄이 타당하다.

①토지보상법 29조 3항의 협의성립확인 신청은 관할 토지수용위원회가 수리함으로써 협의성립확인된 것으로 본다고 규정된 점 ②토지보상법 시행령 13조에서 협의성립확인 신청서에 토지소유자 및 관계인의 동의서를 첨부하도록 하여 실질적 요건이 포함되어 있는 점 등을 미루어 법29조3항의 협의성립확인신청은 행위요건적 신고로 봄이 타당하다.

IV. 행위요건적 신고에서 ‘수리’가 행정소송법상 ‘처분’인지

1. 자기완결적 신고(수리를 요하지 않는 신고)

자기완결적 신고에 대해 행정청이 거부를 하였더라도 사인의 신고만으로 법적 효과가 완성되므로 행정청의 수리 또는 거부가 아무런 법적 의미를 갖지 않는다. 따라서 행정

청의 수리 또는 수리거부행위는 처분성이 인정 되지 않으며, 이에 대해 항고소송을 제기하더라도 부적법 하여 각하된다고 보는 것이 종래 통설의 태도이다.

다만, 판례는 자기완결적 신고 중 인허가의제의 효과를 수반하는 건축신고의 거부를 처분으로 본 바 있고 (대법원 2010. 11. 28. 선고 2008두167판결), 착공신고 수리거부에 대해서도 처분성을 인정한바 있다.

2. 행위요건적 신고(수리를 요하는 신고)

행위요건적 신고의 경우 사인의 신고만으로는 법적 효과가 발생하지 않고, 행정청이 수리를 하여야 비로소 법적 효과가 발생하므로, 행정청의 수리 또는 수리의 거부는 준법률행위적 행정행위의 하나로서 행정소송법상의 처분의 개념에 해당한다. 수리를 요하는 신고는 원칙적으로 계속행위로 보는 것이 타당하나 판례는 사설납골 시설의 설치신고에 대해 법령상의 설치기준에 부합하더라도 중대한 공익상 필요가 있는 경우 수리를 거부할 수 있다고 보았다.

3. 판례 [대법원 2018. 12. 13. 선고 2016두51719 판결]

협의성립 확인의 법적 정당성의 원천은 사업시행자와 토지소유자 등이 진정한 합의를 하였다는 데에 있다. 토지보상법 제29조 제3항에 따른 토지소유자는 협의의 대상이 되는 ‘토지의 진정한 소유자’를 의미한다. 따라서 사업시행자가 단순히 등기부상 소유명의자의 동의만을 얻은 후 협의성립의 확인을 신청하였음에도 토지수용위원회가 신청을 수리하였다면 소유자의 동의 요건을 갖추지 못한 것으로서 위법하다. 사업시행자의 과실이 있었는지 여부와 무관하게 그 동의의 흠결은 위법사유가 된다.

4. 검토

①토지보상법 29조 3항의 협의성립확인 신청은 토지소유자 등의 진정한 합의를 실질적 요건으로 하는 ‘행위요건적 신고’로 볼 수 있고, ②관할 토지수용위원회가 수리를 하여야 비로소 법적 효과가 발생하므로 요건을 갖추지 못한 협의성립확인 신청에 대해 토지수용위원회가 신청을 수리하였다면 그 수리는 행정소송법상 ‘처분’의 개념에 해당한다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 2회

<p.21 법규명령>

01. 다음은 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행령과 시행규칙 제1조(목적)의 내용이다.

시행령 제1조(목적) 이 영은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에서 **위임된 사항**과 **그 시행에 필요한 사항**을 규정함을 목적으로 한다. [전문개정 2013. 5. 28.]

시행규칙 제1조(목적) 이 규칙은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 동법 시행령에서 **위임된 사항**과 **그 시행에 관하여 필요한 사항**을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2005. 2. 5.>

법규명령의 종류와 한계에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 법규명령의 의의·취지·근거·법적성질 II. 법규명령의 종류 1. 법적근거 기준 분류 2. 제정권자 기준 분류 III. 법규명령의 한계 1. 위임명령의 한계 2. 집행명령의 한계

I. 법규명령의 ①의의·②취지·③근거·④법적성질

①법규명령이란 법령의 수권에 근거하여 행정권이 정립하는 일반적·추상적 규범을 말한다. ②행정의 전문성·구체성·행정능률성에 취지가 있다. ③헌법 75조는 대통령령, 헌법95조는 총리령·부령의 근거규정이다. ④국민과의 관계에서 대외적 구속력(법규성)을 갖는다.

II. 법규명령의 종류

1. 법적근거 기준 분류(위임명령과 집행명령)

구체적인 위임규정의 유무에 따라 법규명령을 분류할 수 있다. ① 위임명령은 법률이나 상위명령의 위임에 의해 제정되는 명령으로서 위임의 범위 내에서 국민의 권리, 의무에 관한 사항에 관하여도 규율할 수 있고, ② 집행명령은 개별 구체적인 법률이나 명령상의 근거 없이 상위법령의 집행을 위하여 필요한 절차 및 형식을 규율하는 명령을 말하는 것으로 새로운 법규사항을 정할 수는 없다.

2. 제정권자 기준 분류

법규명령을 제정권자를 기준으로 분류하면 크게 시행령과 시행규칙으로 구분할 수 있다. ① 시행령은 대통령이 제정하는 명령인 대통령령으로, 국무회의의 심의를 거친다. ② 시행규칙은 총리가 제정하는 명령인 총리령과 행정각부의 장이 발하는 명령인 부령으로, 국무회의의 심의를 거치지 않는다.

III. 법규명령의 한계

1. 위임명령의 한계

1) 수권의 한계

①법률의 수권은 구체적이어야 하며 일반적이고 포괄적인 수권은 안 된다(헌법75조). '구체적 위임'이란 법률 규정만으로 하위법규에서 규정된 내용의 대강을 예측할 수 있는 정도를 의미한다. ②국민의 기본권을 제한하는 등 공동체의 중요사항은 입법자가 법률로써 제정하여야 하므로 행정입법에 위임할 수 없다(헌법37조2항).

2) 내용상 한계

위임명령은 상위 수권 법령의 범위 내에서 제정되어야 한다. 모법에서 수권 되지 않은 입법사항에 대해 행정주체는 스스로 규정할 수 없고 규정의 내용도 상위법령의 내용에 위반되지 않아야 한다.

2. 집행명령의 한계

집행명령은 상위법령을 "집행하기 위하여 필요한 사항(헌법 제75조)"만을 규정할 수 있다. 법률이나 상위명령의 개별·구체적인 수권 없이 직권으로 규정할 수 있으나, 그 내용은 법령의 집행에 필요한 절차나 형식에 관한 것만 가능하고 국민의 권리·의무에 영향을 주는 새로운 법규사항을 규정할 수는 없다.

<p.24 법규명령의 통제>

02. 甲은 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제2호(사실상의 사도의 부지에 대한 평가는 인근토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 한다)의 규정은 헌법 제23조상의 재산권보장 및 정당보상원칙을 위배하여 위헌적인 것이라고 주장한다. 甲의 주장을 관철할 수 있는 법적 수단을 설명하시오. (10점) [기출22회 1-3]

목차

I. 토지보상법 시행규칙 제26조제1항제2호의 위헌소지

II. 甲주장을 관철할 수 있는 법적 수단(법규명령의 통제)

1. 입법적 통제
2. 사법적 통제
 - 1) 일반법원에 의한 통제 중 구체적 규범통제(헌법 107조2항)
 - 2) 일반법원에 의한 통제 중 항고소송
 - 3) 헌법재판소에 의한 통제

I. 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제2호의 위헌소지

헌법 제23조 제3항은 정당보상할 것을 규정한다. 정당보상은 피수용재산의 객관적 재산 가치를 완전하게 보상하고 보상의 시기, 방법에 어떠한 제한도 없는 완전보상의 의미로 해석할 수 있으며, 판례도 같은 입장이다. 감가보상을 규정한 해당 규정은 헌법 23조1항의 재산권보상원칙과 보상방법에 과도한 제한을 뒤 완전보상에 미치지 못함으로써 정당보상원칙에 위배될 소지가 있다.

II. 甲주장을 관철할 수 있는 법적 수단(법규명령의 통제)

1. 입법적 통제
국회가 법규명령의 성립·발효·소멸 등에 직접 통제를 가하는 방법과 국회가 행정부에 대해 가지는 국정감시권을 발동시켜 간접적으로 통제하는 방법이 있다.
2. 사법적 통제
 - 1) 일반법원에 의한 통제 중 구체적 규범통제(헌법 107조2항)

①구체적 규범통제란 처분에 대해 다투는 소송에서 법규명령의 위헌·위법 여부가 재판의 전제가 되는 경우에 선결문제로 법규명령의 위헌·위법 여부를 심사하는 제도로 각급 법원이 통제하고 최종적인 심사권은 대법원에 있다. 구체적 규범통제의 대상은 명령과 규칙이 된다. 헌법 107조 2항에 근거를 둔다. ②명령이 위법하다는 대법원 판결이 있는 경우 그 효력에 대해 견해대립이 있으나 당해 사건에 한하여 적용된다는 견해가 일반적이다. ③사안의 토지보상법 시행규칙 26조 1항 2호는 법규명령으로 구체적 사안에서 재판의 전제가 되는 경우 구체적 규범통제로 甲의 주장을 관철할 수 있을 것이다.

2) 일반법원에 의한 통제 중 항고소송

행정소송법은 취소소송과 무효등확인소송의 대상을 '처분 등'으로 규정하고 있어, 일반적·추상적 규범인 법규명령은 원칙적으로 항고소송의 대상이 될 수 없다. 다만, 법규명령이 처분적 성질을 가지는 경우(처분적 법규명령)에는 항고소송의 대상이 될 수 있다. 판례는 두밀분교폐지조례의 처분성을 긍정한 바 있으나, 사안의 토지보상법 시행규칙 26조 1항 2호는 처분적 법규명령으로 보기 어려운바 항고소송으로 甲의 주장을 관철할 수 없다.

3) 헌법재판소에 의한 통제

①헌법 제107조 제2항은 명령규칙에 대한 위헌위법의 심사권을 일반법원에 부여하고 있고 행정입법에 대한 헌법소원을 인정하는 명문의 규정이 없어 헌법재판소가 명령·규칙에 대한 위헌·위법 심사권을 가질 수 있는지가 문제 된다. ②견해대립이 있으나 다수설은 명령 등이 국민의 기본권을 직접 침해하는 경우에는 헌법재판소도 심사할 수 있다고 본다. ③헌법재판소는 대법원규칙인 법무사 시행 규칙 헌법소원 사건 등에서 법규명령 등이 별도의 집행행위를 기다리지 않고 직접 기본권을 침해하는 것인 때에는 헌법소원심판의 대상이 될 수 있다고 판시하였다. ④생각건대, 기본권 보호 기능을 보장하기 위한 헌법소원의 제도적 취지에 비추어 법규명령에 대한 헌법소원을 일정한 경우 인정하는 긍정설이 타당하다. ⑤사안의 시행규칙만으로 甲의 재산권에 영향을 미친다고 보기 어려우나, 甲은 헌법소원을 통해 자신의 주장을 관철할 수 없다.

<p.26 행정규칙>

03. 사업시행자 A는 국토교통부장관이 제정한 K지침에 따라 구분지상권 보상액을 책정하였다. 상위법령의 위임이 없는 K지침에 법규성을 인정할 수 있는지 검토하시오. (10점) [기출21회 1-1 일부 변형]

목차
I. 쟁점의 정리
II. K지침(행정규칙)의 법적성질
1. 의의
2. 법적성질

I. 쟁점의 정리

사안의 K지침은 행정규칙으로 대외적 구속력(법규성)을 인정할 수 있는지 법적성질 논의를 검토한다.

II. K지침(행정규칙)의 법적성질

1. 의의

행정규칙이란 행정조직 내부에서 효력을 갖는 일반적·추상적 규율로서 행정의 조직과 활동을 규율하는 것을 목적으로 하는 행정기관 내부의 사무처리 기준을 말한다. 행정규칙은 내부적으로만 효력을 갖고 대외적 구속력 즉, 법규성은 없다. 다만 행정규칙도 개별적·구체적인 경우 행정처분으로 인정되어 행정소송의 대상이 되기도 하고 특히, 재량준칙의 경우에 행정관행이 성립되면 평등의 원칙과 신뢰보호의 원칙을 매개로 자기구속의 원칙에 따라 대외적 구속력을 갖게 되는 경우가 있다.

2. 법적성질

1) 학설

① 행정규칙은 원칙적으로 행정조직 내부를 규율하는 것으로 대내적 구속력만 있고, 대외적 구속력(법규성)이 없다는 견해(비법규설), ② 행정권은 권한범위 내에서 고유한 입

법권을 가지므로 행정규칙도 대외적 효력을 가진다고 보는 견해(법규설), ③ 행정규칙 중 재량준칙은 평등의 원칙 및 자기구속의 원칙에 의해 법규로 전환되어 법규성이 인정될 수 있다고 보는 견해(준법규설) 등 다양한 견해가 있다.

2) 판례

판례는 일관되게 행정규칙의 대외적 구속력 즉, 법규성을 부인하는 입장을 취하고 있다. 일부 법규성을 긍정하는 듯한 판례가 있으나 이는 행정규제기본법 제4조 제2항에 따른 법령보충적 행정규칙인 경우이며 재량준칙의 경우 예도 행정관행이 성립된 경우 자기구속의 원칙을 매개로 대외적 구속력을 인정하는 것에 불과하다.

3) 소결

법률의 법규창조력에 의거 원칙적으로 행정규칙의 대외적 구속력을 부정하는 것이 타당하나, 재량준칙의 경우 평등의 원칙이나 자기구속의 원칙을 매개로 법규성 가질 수 있다고 판단된다.

<p.27 법규명령형식의 행정규칙>

04. 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률(이하 감정평가법) 시행령 제29조 별표3의 법적성질을 검토하시오. (15점) [기출20회 3 변형]

목차
I. 쟁점의 정리
II. 법규명령형식의 행정규칙 의의
III. 법규명령형식의 행정규칙 법적성질
1. 학설
2. 판례
3. 검토

I. 쟁점의 정리

감정평가법 시행령 29조 별표3은 법규명령 형식으로 제재적 처분기준을 규정하여 행정규칙의 실질을 갖고 있는바, 그 법적성질 논의를 검토한다.

II. 법규명령형식의 행정규칙 의의

법규명령형식의 행정규칙이란 형식은 법규명령이나 그 내용이 국민의 권리·의무와 관련된 법규적 사항이 아닌, 행정청 내부의 사무처리기준이나 제재적 처분의 기준 등 행정규칙의 실질을 가지는 것을 말한다.

III. 법규명령형식의 행정규칙 법적성질

1. 학설

1) 법규명령설(형식설)

규범의 형식을 중시하고 법적 안정성 확보를 위해 법규명령으로 보는 견해를 말한다. 특히 제재적 처분기준은 제재의 정도를 가감할 수 있는 가중·감경 조항이 있어 개별적·탄력적 적용이 가능하므로 법규성을 긍정한다.

2) 행정규칙설(실질설)

규범의 실질을 중시하고 행정의 실질적 타당성과 탄력성 확보를 위해 행정규칙으로 보는 견해를 말한다. 즉, 행정규칙 사항을 대통령령·총리령·부령으로 정한다고 해서 그 성질이 법규명령이 되는 것은 아니라고 본다.

3) 수권여부기준설

수권여부를 기준으로 판단하는 견해로서, 상위법령의 수권에 근거하여 제정되었다면 법규명령으로 보고 위임이 없이 제정되었다면 행정규칙으로 본다. 이는 법규명령과 행정규칙의 개념을 중시하여 판단하는 견해이다.

2. 판례

1) 종합

판례는 일반적으로 법규명령형식의 행정규칙의 법규성을 인정하여 법규명령으로 보는 입장이다. 그러나 제재적 처분기준의 경우 아래와 같이 부령과 대통령령에 따라 법규성을 다르게 보고 있다.

2) 부령형식

구) 「식품위생법」 시행규칙으로 규정된 영업정지 등의 제재적 처분기준은 그 성질과 내용이 행정내부의 사무처리기준에 불과하므로 행정규칙의 성질을 가지며 대외적으로 국민이나 법원을 구속하는 것은 아니라고 보고 있다. 다만, 대법원은 이 경우 행정규칙(재량준칙)으로 보면서도 법원은 당해 제재적 처분기준을 존중하여야 한다고 본다.

3) 대통령령 형식

구) 「청소년보호법」 시행령으로 제정된 과징금 처분기준의 경우에 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 판시하였다. 다만, 대법원은 해당 과징금 처분의 기준을 최고한도액을 정한 것으로 보아 재량의 여지를 인정하고 있다.

3. 검토

대통령령과 부령의 형식적 차이에 따라 법규명령형식의 행정규칙의 법규성을 구분하는 것은 합리적인 이유가 없어 타당하지 않다. 대통령령과 부령 모두 헌법 제75조 및 제95조에 근거한 형식이며 법규명령으로서 절차적 정당성이 부여되어 있으므로 국민의 예측가능성을 보장하는 측면에서 형식을 기준으로 법규명령으로 보는 <법규명령설>이 타당하다.

<p.29 행정규칙형식의 법규명령(법령보충적 행정규칙)>

05. 표준지공시지가 조사·평가 기준의 법적성질을 검토하시오. (15점)

부동산 가격공시에 관한 법률

제3조 ④ 국토교통부장관이 제1항에 따라 표준지공시지가를 조사·평가하는 경우에는 인근 유사토지의 거래가격·임대료 및 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액, 인근지역 및 다른 지역과의 형평성·특수성, 표준지공시지가 변동의 예측 가능성 등 제반사항을 종합적으로 참작하여야 한다.

부동산 가격공시에 관한 법률 시행령

제6조 ① 법 제3조제4항에 따라 국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사·평가하는 경우 참작하여야 하는 사항의 기준은 다음 각 호와 같다.

[기출33회 2-1 변형]

목차

I. 쟁점의 정리

II. 행정규칙형식의 법규명령(법령보충적 행정규칙)의 의의

III. 법령보충적 행정규칙의 법적성질

1. 학설
2. 판례
3. 검토

I. 쟁점의 정리

표준지공시지가 조사·평가 기준은 훈령형식이나 국민의 권리의무에 영향을 미치는 법규명령 실질을 갖고 있어 그 법적성질 논의를 검토한다.

II. 행정규칙형식의 법규명령(법령보충적 행정규칙)의 의의

법령보충적 행정규칙이란 상위법령의 위임에 따라 대통령령·총리령·부령과 같이 법규명령 형식으로 제정되어야 할 사항을 훈령 등 행정규칙의 형식으로 제정한 것을 말한다. 즉, 그 형식은 행정규칙이나 실질(내용)이 법규명령인 것으로 행정규칙형식의 법규명령

이라고도 한다.

III. 법령보충적 행정규칙의 법적성질

1. 학설

1) 법규명령설(실질설)

법규명령설은 실질을 중시하는 견해로서 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있는 훈령·고시 등의 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 보는 견해이다.

2) 행정규칙설(형식설)

법규명령 형식은 대통령령·부령·총리령으로 한정되어 있으므로 이러한 형식에 의하지 않은 훈령 등은 행정규칙이라고 보는 견해로서 형식을 중시한다.

3) 기타(수권여부기준설, 규범구체화 행정규칙설, 위헌무효설)

상위법령의 수권 유무에 따라 구분하는 견해, 대외적으로는 법적 구속력을 인정하나, 내부적으로는 상위법령을 구체화하는 규범구체화 행정규칙으로 보는 견해, 헌법 제75조 및 제95조에서 법규명령의 형식을 한정하고 있으므로 행정규칙의 형식으로 법규명령을 제정하는 것은 위헌·무효라고 보는 견해 등이 있다.

2. 판례

판례는 국세청장의 훈령 형식인 재산제세사무처리규정과 관련하여 해당 규정이 소득세법 시행령의 위임에 따라 그 내용을 보충하는 기능을 가지면 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 법규명령으로서의 효력을 갖는다고 본다.

3. 검토

①상위법령의 위임을 받아 법규사항을 정하는 행정규칙은 위임을 한 명령을 보충·구체화 하는 것을 내용으로 하는 경우 상위법령의 위임의 한계 내에서 상위법령과 결합하여 대외적 구속력을 갖는다고 보는 것이 타당하다. 또한 행정규제기본법 제4조 제2항에 따라 전문적이고 기술적인 사항 등 최소한의 영역에서만 법령보충적 행정규칙의 법규성을 인정함이 타당하다. 따라서, ②표준지공시지가 조사·평가 기준은 부동산공시법 3조4항 및 시행령 6조 1항의 위임을 받아 그 내용을 보충·구체화하는 행정규칙으로 상위법령의 위임 한계 내 상위법령과 결합하여 대외적 구속력을 갖는다.

<「p.31 행정행위 및 p.125처분 등」의 개념요소>

06. 행정소송법 제19조(취소소송의 대상)는 “취소소송은 처분 등을 대상으로 한다”고 규정한다. ‘처분’의 학문상 용어인 행정행위의 개념요소와 ‘처분 등’의 개념요소를 비교하여 설명하시오. (10점)

목차
I. ‘행정행위’와 ‘처분 등’의 개념
1. 행정행위
2. 처분 등
II. 행정행위 및 처분 등의 개념요소
1. 행정청의 행위(공통)
2. 구체적 사실에 대한 행위(공통)
3. 법적행위(공통)
4. 공권력 행사(처분 등)
III. 양자의 구별

I. ‘행정행위’와 ‘처분 등’의 개념

1. 행정행위

행정행위란 학문상 용어로서 실정법으로는 인가, 허가, 면허, 결정 등 다양한 용어로 사용되는 것을 학문상 개념으로 정립한 것을 말한다. 실정법에서는 ‘행정처분’이나 ‘처분’이라는 용어를 행정행위와 상응하는 용어로 사용하고 있다.

통설에 따르면 행정행위는 행정청이 구체적 사실에 대한 법 집행으로서 행하는 권력적 단독행위인 공법행위라고 정의한다.

2. 처분 등(행정소송법 제2조제1항)

‘처분 등’이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 공권력의 행사 또

는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(처분) 및 행정심판에 대한 재결을 말한다.

II. 행정행위 및 처분 등의 개념요소

1. 행정청의 행위(공통)

<행정행위 및 처분 등>은 행정청의 행위이다. 행정청이란 행정조직법상의 개념이 아닌 기능면에서 파악한 개념으로서 사인 등도 공무를 위탁받아 수행하는 한 행정청의 개념에 포함될 수 있다.

2. 구체적 사실에 대한 행위(공통)

구체적 사실이란 규율내용이 구체적인 것으로 특정인에게 직접적인 영향을 미치는 행위를 말한다. <행정행위 및 처분 등>은 규범을 정립하는 행위가 아니라 구체적 사실에 대한 법 집행 행위를 말한다. 즉, 국민의 권리·의무에 변경을 가져오는 행위를 의미하는 것으로 법규명령(처분적 명령은 제외)과 같은 규범 자체는 행정행위가 아니다.

3. 법적행위(공통)

<행정행위 및 처분 등>은 사실행위가 아닌 법적 행위에 해당하며 외부적으로 권리·의무의 발생, 변경, 소멸이라는 법적 효과를 일으키는 행위를 말한다.

4. 공권력 행사(처분 등)

<처분 등>은 공권력 행사를 그 개념요소로 한다. 공권력 행사란 행정청이 우월한 지위에서 일방적으로 행하는 일체의 행정작용을 말한다. 따라서 대등한 지위에서 행하는 공법상 계약은 대상이 되지 않는다.

III. 양자의 구별

소송법상의 처분의 개념과 학문상의 행정행위 개념이 동일한 것인지에 관해 견해대립이 있으나 다수설에 따르면 처분 개념이 행정행위 개념보다 더 넓은 개념이라고 본다.

<p.32 행정행위의 종류-법적효과의 발생원인>

07. 토지보상법 20조의 사업인정의 법적성질에 대해 특허로 보는 견해와 확인행위로 보는 견해대립이 있다. 이하 법률행위적 행정행위와 준법률행위적 행정행위에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 의의 및 구별실익
II. 법률행위적 행정행위
1. 명령적 행정행위
2. 형성적 행정행위
III. 준법률행위적 행정행위
IV. 사업인정의 법적성질

I. 의의

법률행위적 행정행위란 행정청의 의사표시를 구성요소로 하고 그 의사표시의 내용에 따라 일정한 법적 효과가 발생하는 행위를 말하고, 준법률행위적 행정행위란 행정청의 의사표시 이외의 정신작용(판단, 인식 등)을 구성요소로 하고 행정청의 의사와는 무관하게 법규가 정한 바에 따라 법적 효과가 발생하는 행위를 의미한다.

II. 법률행위적 행정행위

1. 명령적 행정행위

명령적 행위란 질서유지를 위해 국민에 대하여 일정한 작위·부작위·급부·수인 등의 의무를 명하거나 해제하는 행정행위를 말한다. ①하명은 행정청이 작위·부작위·급부·수인 등의 의무를 명하는 행위를 말하며, 침익적 성질을 가지므로 법령의 근거가 필요하다. ②허가란 질서유지·위험예방 등을 위해 법률로 개인의 자유를 제한하고 일정한 요건이 구비된 경우에 그 제한을 해제하여 본래의 자유를 회복시켜 주는 행정행위를 말한다. ③면제란 법령에 의해 부과된 작위·급부·수인 등의 의무를 특정한 경우에 해제해 주는 행정행위를 말한다. 허가는 의무해제의 대상이 부작위라는 점에서 면제와 구별된다.

2. 형성적 행정행위

형성적 행위란 사인에게 새로운 권리·능력·법률상의 지위 또는 포괄적 법률관계, 기타 법률상의 힘을 발생, 변경, 소멸시키는 행정행위를 말한다. ① 특허란 특정인에 대하여 새로운 권리, 능력 또는 포괄적 법률관계를 설정하는 행위를 말한다. 설권행위라고 부르기도 한다. ②인가란 행정청이 제3자의 법률행위를 보충하여 그 법률상의 효과를 완성시키는 행정행위를 말한다. 보충행위라고도 한다. ③대리란 제3자가 해야 할 일을 행정청이 대신하여 행함으로써 제3자가 스스로 행한 것과 같은 법적 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다.

III. 준법률행위적 행정행위

준법률행위적 행정행위는 행정청의 의사표시(효과의사) 이외의 정신작용(판단·인식) 등을 구성요건으로 하는 행정행위로서 그 효과가 행정청의 의사가 아닌 법률 규정에 의해 발생하는 행위를 말한다. ①확인이란 진위가 불확실한 특정한 사실 또는 법률관계의 존재 여부 또는 정당성 여부에 관해 의문이나 다툼이 있는 경우 행정청이 공적인 권위로 판단하여 확정하는 행위를 말한다. ②공증이란 진위가 확실한 특정한 사실 또는 법률관계의 존재 여부를 공적으로 증명하는 행위를 말한다. ③통지란 행정청이 특정인 또는 불특정 다수인에 대해 일정한 사실을 알리는 행위를 말한다. 특정한 사실 또는 의사를 알리는 행위를 말하는 것으로서 일정한 법적 효과를 발생시키는 것을 의미한다. ④수리란 행정청이 타인의 행위를 유효한 행위로서 받아들이는 행위를 말한다. 수리를 요하는 신고에서 수리는 준법률행위적 행정행위인 수리로서 항고소송의 대상인 처분에 해당한다.

IV. 사업인정의 법적성질

사업인정은 공익사업을 토지 등을 수용·사용할 사업으로 결정하는 것으로 수용권의 주체를 사업시행자로 보는 경우 설권행위로 보고, 수용권의 주체를 국가로 보는 경우 확인행위로 본다. 판례는 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 형성행위라 판시한 바 있다. 사업인정은 해당 사업의 공익성 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여 수용권을 설정해주는 것으로 설권행위로 보는 것이 일반적이다.

<p.34 행정행위의 종류-법적효과의 성질>

08. 수익적 행정행위는 직권취소나 철회권 발동 시 제한법리가 고려된다. 한편, 침익적 행정행위는 행정절차에서 사전통지나 의견청취에 있어 의미를 갖는다. 이하 법적 효과의 성질을 기준으로 한 행정행위의 종류에 대해 설명하시오. (5점)

목차
I. 개요
II. 수익적 행정행위
III. 침익적 행정행위
IV. 복효적 행정행위

I. 개요

행정행위가 상대방 또는 관계자에게 어떠한 법적 효과를 발생시키는지를 기준으로 수익적·침익적·복효적 행정행위로 구분할 수 있다.

II. 수익적 행정행위

상대방에게 권리·이익을 부여하거나 권리의 제한을 해제해 유리한 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다. 특허나 인가 등을 예로 들 수 있다.

III. 침익적 행정행위

상대방에게 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 등 불이익한 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다. 위반건축물 철거명령, 조세부과 등을 예로 들 수 있다.

IV. 복효적 행정행위

하나의 행정행위가 이익과 불이익이라는 복수의 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다. 이때 그 복수의 효과가 동일인에게 발생되면 혼합효 행정행위라 하고, 상대방에게는 이익을 주고 제3자에게는 불이익을 주는 경우(혹은 그 반대)는 제3자효 행정행위라고 한다. 토지보상법 20조의 사업인정은 사업시행자에게는 수익을, 피수용자에게는 불이익을 주는 제3자효 행정행위이다.

<p.34 행정행위의 종류-행정청의 선택·결정권 유무 기준>

09. 기속행위와 재량행위에 대해 설명하고, 토지보상법 20조 사업인정이 재량 행위인지 검토하시오. (10점)

행정소송법 제27조 (재량처분의 취소)

행정청의 재량에 속하는 처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다.

행정기본법 제21조 (재량행사의 기준)

행정청은 재량이 있는 처분을 할 때에는 관련 이익을 정당하게 형량하여야 하며, 그 재량권의 범위를 넘어서는 아니 된다.

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제20조(사업인정)

① 사업시행자는 제19조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다.

목차

I. 의의

II. 구별실익

III. 구별기준

IV. 재량권의 한계(재량권 일탈·남용)

V. 토지보상법 20조 사업인정 검토

I. 의의

기속행위란 법령상 요건이 충족되면 행정청은 반드시 일정한 행위를 하거나 하여서는 안 되는 행정행위를 말한다. 기속행위는 행정청의 재량이 전혀 인정되지 않는데,

이에 반해 재량행위는 법령상 요건이 충족되더라도 행정법규가 행정청에 일정한 한도 내에서 재량권을 부여고 있어 행정청이 효과를 선택할 수 있는 행정행위를 말한다.

II. 구별실익

기속행위와 재량행위는 사법심사 방식에 차이가 있어 그 구별에 실익이 있다. 기속행위는 법령상 요건 충족시 반드시 일정한 행위를 하여야 하는 법규에 대한 기속성이 있으므로 그 행위의 위법여부를 법원이 독자적으로 심사할 수 있다. 즉, 법원이 법규의 해석과 적용을 통해 독자적인 결론을 도출한 후 행정청의 행위에 대한 적법 여부를 심사한다. 반면에 재량행위는 공익과 관련하여 행정청에 재량권이 있으므로 법원이 독자적 결론을 도출함이 없이 행정청의 행위에 대해 재량권의 일탈·남용이 있는지를 심사하게 된다.

III. 구별기준

기속행위와 재량행위는 법문의 해석을 통해 1차적으로 구분할 수 있다.

즉, 법령에서 ‘(행정청은).....하여야 한다’고 표현하면 기속행위로 보고, ‘(행정청은).....할 수 있다’고 표현하면 재량행위로 본다. 그러나 법문의 표현이 불분명한 경우에는 ① 당해 행위가 속하는 행정 분야의 주된 목적과 특성, ② 당해 행위 자체의 개별적 성질과 유형 등을 종합 고려하여 판단하여야 한다.

IV. 재량권의 한계(재량권 일탈·남용)

재량행위는 행정청에게 재량권이 있으므로 재량권에 부여된 목적과 한계 내의 것이라면 부당한 행위가 될 수는 있으나 위법한 것은 되지 않아 법원의 통제 대상이 되지 않는다. 재량의 하자에는 재량권 일탈과 남용, 재량권의 불행사 및 재량권의 해태가 있으나 실질적으로 재량권 일탈과 남용을 구분할 실익이 없고 재량권의 한계를 위반한 재량권 행사는 위법하게 된다.

V. 토지보상법 20조 사업인정 검토

‘사업시행자는~사업인정을 받아야 한다’고 규정되어 법문의 표현이 불분명하다. 토지보상법의 입법목적, 취지, 행위의 성질, 공익 관련성 등을 종합적으로 판단할 때 재량행위로 봄이 타당하다.

<p.36 행정행위의 종류-행정청의 선택·결정권 유무 기준>

10. 불확정개념과 판단여지에 대해 설명하시오. (5점)

목차
I. 불확정개념 II. 판단여지 1. 의의 2. 학설 및 판례 3. 판단여지의 한계

I. 불확정개념

불확정개념이란 법규의 요건 부분에 사용된 추상적이며 해석의 여지가 있는 다의적 개념을 말한다. 공공복지, 공공의 안녕과 질서 등의 개념을 예로 들 수 있으며, 행정의 다양성으로 그 사용이 증가하고 있다. 불확정개념은 법개념이고 사법심사의 대상이 된다.

II. 판단여지

1. 의의

요건에 불확정개념이 규정된 경우에 그 불확정개념의 해석·적용에 있어서 하나의 판단만이 적법하다고 보면서도, 행정청의 결정이 일정한 한계 내에서 이루어진 경우 법원은 이를 존중하여야 한다는 이론이다. 판단여지는 ① 비대체적 결정 영역(전문적, 학문적 평가에 관계되는 시험성적의 평가 등), ② 구속적 가치평가 영역(직무상 독립성을 가지는 위원회의 결정 등), ③ 형성적·정책적 결정 영역 등(외국인의 체류기간 연장 등)에서 인정될 수 있다. 판단여지가 인정되는 영역 내에서 행정청이 신중하게 내린 판단은 위법하지 않으며 법원에 의한 통제의 대상이 되지 않는다.

2. 학설 및 판례

판단여지를 재량과의 구별되는 독자적 개념으로 인정할 것인지에 대해서는 견해가 대립하는데, ① 사법심사가 제한된다는 점에서 양자를 구별할 실익이 없다는 <부정설>, ②

판단여지는 법인식 문제이고, 재량은 법률효과 선택의 문제라고 보아 양자를 구별하여 판단여지를 독자적 개념으로 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>이 있다. 판례는 판단여지의 영역의 문제(시험평가, 독립된 위원회의 결정 등)를 재량과 구별되는 개념으로 인정하지 않고 있다.

3. 판단여지의 한계

판단여지는 행정행위의 요건에 불확정개념이 규정된 경우 그 해석·적용에서 인정되는데, 이렇게 판단여지가 존재하는 경우에도 ① 판단기관이 적법하게 구성되었는지 여부, ② 절차 규정의 준수 여부, ③ 정당한 사실관계에서 출발하였는지 여부, ④ 일반적으로 승인된 평가 척도의 침해 여부 등은 사법심사의 대상이 된다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 3회

<p.38 행정행위 성립요건과 효력발생요건>

사업시행자에게 부여된 수용권의 내용을 구체적으로 확정하는 공용수용의 종국적 절차를 '재결'이라고 한다. 재결은 행정행위이다.

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)

제34조(재결)

- ① 토지수용위원회(주체)의 재결은 서면(형식)으로 한다.
 - ② 제1항에 따른 재결서에는 주문 및 그 이유와 재결일을 적고, 위원장 및 회의에 참석한 위원이 기명날인한 후 그 정본(正本)을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인에게 송달(효력발생요건)하여야 한다.
- (절차)제28조(재결의 신청) -> 제31조(열람) -> 제32조(심리) -> 제35조(재결기간)
(내용)제50조(재결사항)

01. 상단의 내용은 토지보상법 34조 재결의 성립요건과 효력발생요건에 관한 조문이다. 이하 행정행위 성립요건과 효력발생요건에 대해 설명하시오. (10점)

목차

I. 개설

II. 행정행위의 성립요건

1. 주체
2. 절차
3. 형식
4. 내용

III. 행정행위의 효력발생요건

I. 개설

행정행위가 성립하여 효력을 발생시키기 위해서는 성립 및 효력요건을 갖추어야 하며, 성립 및 효력요건은 행정행위의 적법요건으로서 이러한 요건을 갖추지 못한 경우는 하자 있는 행정행위가 된다.

II. 행정행위의 성립요건

1. 주체

행정행위는 정당한 권한을 가진 기관이 부여된 권한의 범위 내에서 정상적인 의사에 따라 행해야 한다.

2. 절차

행정행위는 법령상 규정된 일정한 절차를 거쳐야 하며, 다른 기관과의 협력절차가 요구되는 경우에는 그러한 절차를 거쳐야 한다.

3. 형식

행정행위는 그 내용과 존재를 객관적으로 명확히 하기 위해 일정한 형식이 요구되는 경우가 많다. 행정절차법은 행정청이 처분을 하는 경우에는 다른 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 문서로 하여야 한다고 규정함으로써 서면주의 원칙을 정하고 있다. (「행정절차법」 제24조 제1항)

4. 내용

행정행위는 그 내용이 법률에 적합하여야 하고, 법률상·사실상 실현 가능하며, 이해관계인이 인식할 수 있을 정도로 명확한 것이어야 한다.

III. 행정행위의 효력발생요건

행정행위의 효력발생요건이란 성립요건을 갖춘 행정행위가 상대방에 대해 효력을 발생하기 위한 요건을 말한다. 상대방이 있는 행정행위는 원칙적으로 상대방에게 도달된 때(도달주의)에 그 효력이 발생한다(행정절차법 제15조). 여기에서 '도달'이란 상대방이 알 수 있는 상태에 두는 것을 말한다. 즉 상대방이 직접 수령하여 그 내용을 현실적으로 알 것까지 요하지는 않는다. 통지는 상대방이 특정된 경우는 원칙적으로 송달에 의하고, 상대방이 불특정 다수인 이거나 상대방의 주소 등이 불분명하여 송달이 불가능한 경우에는 고시 또는 공고에 의한다.

<p.39~p.42 행정행위의 효력>

02. 행정행위의 효력을 개념 중심으로 설명하시오. (10점)

목차
I. 구속력
II. 공정력
III. 구성요건적 효력
IV. 존속력(불가쟁력·불가변력)
V. 강제력(자력집행력·제재력)

I. 구속력

구속력이란 행정행위가 성립·효력발생요건을 갖추면 행정청의 효과의사의 내용이나 (법률행위적 행정행위), 법령이 정하는 바에 따라(준법률행위적 행정행위) 일정한 법적효과를 발생시키고 행정주체와 관계인을 구속하는 힘을 가지게 되는데 이를 구속력이라고 한다.

II. 공정력(행정기본법 제15조)

공정력이란 행정행위에 하자가 있다 하더라도 그것이 중대·명백하여 당연히무효로 인정되는 경우를 제외하고는 권한 있는 기관(처분청, 감독청, 행정심판위원회, 법원)에 의하여 취소되기 전까지 상대방이나 이해관계인은 그 효력을 부인할 수 없는 구속력을 말한다. 즉, <하자 있는 행정행위라도 취소되지 않는 한 일단 유효한 것으로 통용되는 힘>을 말하며, 행정의 안정성과 실효성 확보에 그 이론적 근거가 있다.

III. 구성요건적 효력

구성요건적 효력이란 취소할 수 있는 행정행위일지라도 그 행정행위가 유효하게 존재하는 한 다른 행정기관이나 법원은 그 행위와 관련이 있는 자들의 결정에 그 행위의 존재와 법적 효과를 인정해야 하고 그 내용에 구속되는 효력을 말한다. 국가기관 상호간의 권한분배 문제로 다른 행정청 및 다른 법원관계에서 의미가 있고, 무효인 경우 인정되지 않는다.

IV. 존속력(불가쟁력·불가변력)

행정행위가 행해진 후 제소기간의 경과 등 일정한 사유가 발생하면 상대방 등이 더 이상 그 효력을 다툴 수 없게 되고(불가쟁력), 일정한 행정행위의 경우 그 행위를 한 행정청도 이를 취소·철회할 수 없게 되는 데(불가변력) 이러한 효력을 존속력 또는 확정력이라 한다.

V. 강제력(자력집행력·제재력)

행정행위는 자력집행력과 제재력이라는 강제력을 가진다. 자력집행력은 행정행위에 의해 부과된 의무를 상대방이 불이행하는 경우 행정청이 스스로 강제력을 발동하여 그 내용을 실현시키는 힘을 말하고, 제재력은 행정행위에 의해 부과된 의무를 상대방이 불이행하는 경우 그에 대한 제재로서 행정벌(행정형벌과 행정징서벌)을 부과하는 힘을 말한다.

<p.39 구성요건적 효력과 선결문제-제35회 1-3 기출변형>

03. 乙이 수용재결이라는 행정행위의 취소사유에 해당하는 하자를 이유로 민사소송인 소유권이전등기말소청구소송을 제기한 경우 민사법원은 수용재결의 효력을 부인할 수 있는지 검토하시오.(10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 선결문제의 의의 등 1. 선결문제의 의의 및 근거 (「행정소송법」 제11조) 2. 구성요건적 효력과 선결문제 III. 민사법원의 행정행위 효력 부인 가능성 1. 학설 2. 판례 1) 당연무효인 경우 2) 취소사유인 경우 3. 검토

I. 쟁점의 정리

민사소송인 소유권이전등기말소청구소송에서 행정행위인 수용재결의 효력 부인이 가능한지 선결문제 관련하여 검토한다.

II. 선결문제의 의의 등

1. 선결문제의 의의 및 근거 (「행정소송법」 제11조)

선결문제란 민사·형사법원의 본안판단에 앞서 특정 행정행위의 위법 여부 또는 효력 유무가 먼저 해결되어야 할 문제인 된 경우에 그 특정 행정행위의 위법 여부 등의 문제를 선결문제로 한다.

2. 구성요건적 효력과 선결문제

구성요건적 효력이란 취소할 수 있는 행정행위일지라도 그 행정행위가 유효하게 존재하는 한 다른 행정기관이나 법원은 그 행위와 관련이 있는 자들의 결정에 그 행위의 존재와 법적 효과를 인정해야 하고 그 내용에 구속되는 효력을 말한다. 선결문제를 공정력의 문제로 보는 견해도 있으나(공정력과 구성요건적 효력을 구분하지 않는 견해), 공정력과 구성요건적 효력은 내용, 범위 및 이론적·법적근거를 달리하므로 양자를 구별하는 것이 타당하며, 선결문제를 구성요건적 효력의 문제로 보는 것이 다수의 견해이다.

III. 민사법원의 행정행위 효력 부인 가능성

1. 학설

위법한 행정행위라도 당연무효가 아닌 한 당해 행정행위의 구성요건적 효력으로 인해 유효하므로 그 효력을 부인할 수 없어 선결문제로 심사할 수 없다는 것이 일반적 견해이다.

2. 판례

1) 당연무효인 경우

행정처분이 당연무효임을 전제로 하여 민사소송을 제기한 때에는 그 행정처분의 당연무효인지의 여부가 선결문제이므로, 법원은 이를 심사하여 그 행정처분의 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고 인정될 경우에는 이를 전제로 하여 판단할 수 있으나 그 하자가 단순한 취소사유에 그칠 때에는 법원은 그 효력을 부인할 수 없다 할 것이다.

2) 취소사유인 경우

불복절차를 취하지 않음으로써 그 재결에 대하여 더 이상 다툴 수 없게 된 경우에는 기업자는 그 재결이 당연무효이거나 취소되지 않는 한 재결에서 정한 손실보상금의 산정에 있어서 위 하자가 반영되지 않았다는 이유로 민사소송절차로 토지소유자에게 부당이득의 반환을 구할 수는 없다.

3. 검토

선결문제는 구성요건적 효력의 문제이므로, 행정행위에 단순 취소사유의 하자가 있다면 그 행위는 여전히 유효하게 존재하며, 다른 국가기관은 그 효력을 인정하여야 하므로 그 효력을 부인할 수 없다고 보는 것이 타당하다.

<p.39~p.42 구성요건적 효력과 선결문제 유형별 정리>

법원	유형	행정행위	소송	심리판단	승소/무죄 패소/유죄
민사	효력유무 효력부인	과징금 과세처분	부당이득반환 청구소송	무효(효력유무可)	승소
		수용재결	소유권이전등기말소청구소송	취소사유(효력부인不)	패소
	위법성 여부	계고처분	손해배상청구 (국가배상청구소송)	무효/취소사유 (위법성 여부可)	승소
형사	효력유무 효력부인	등록취소 (무등록)	감정평가법49조	무효(효력유무可)	무죄
		운전면허 (무면허)	도로교통법152조	취소사유(효력부인不)	무죄
	위법성 여부	원상회복명령 (토지 무단형질변경)	국토계획법142조	무효/취소사유 (위법성 여부可)	무죄

목차

I. 쟁점의 정리

II. 행정행위의 위법성정도

※문제에 직접 제시 안 된 경우 취소 혹은 무효 판단 필요

※취소정도 하자일 경우 이하 Ⅲ->IV->V

※무효정도 하자일 경우 이하 Ⅲ(->IV생략가능) -> V

III. 선결문제의 의의 등

1. 선결문제의 의의 및 근거 (「행정소송법」 제11조)
2. 구성요건적 효력과 선결문제

IV. 민사(혹은 형사)법원의 행정행위(취소정도하자) 위법성확인 가능성

1. 학설
2. 판례
3. 검토

V. 민사(혹은 형사)법원의 행정행위 효력부인 가능성

1. 학설
2. 판례
 - 1) 당연무효인 경우
 - 2) 취소사유인 경우
3. 검토

연습문제

1. A법인은 위법한 과징금 처분을 이유로 손해배상청구를 하려한다. 승소가능성은?

(과징금처분의 위법성 정도가 직접 제시되지 않은바, <II취소무효> 확인 후 논의전개)

2. A법인이 받은 과징금 처분에 취소정도의 위법이 있었다. 불가쟁력 발생으로 행정소송을 할 수 없게 되자, 곧바로 부당이득반환청구소송을 제기하려 한다. 승소가능성은?

3. A법인은 등록취소 상태에서 감정평가법 10조 업무를 한 이유로 형사고발되었다. A법인은 당시 등록취소가 위법하다며 무죄를 주장한다. 주장의 타당성을 검토하시오.

(등록취소가 취소정도의 하자->효력부인불가->유죄->주장은 타당하지 않음)

(등록취소가 당연무효의 하자->효력유무 확인가능->무죄->주장은 타당함)

<p.43 행정행위의 무효와 취소>

04. 행정행위 하자란 행정행위가 적법요건(성립 및 효력요건)을 갖추지 못하여 완전한 효력발생에 장애가 되는 사유를 말한다. 한편, 적법요건을 구비하여도 합목적성을 위반한 재량권행사가 있는 행위는 부당한 행위로서 직권취소의 대상이 될 수 있다. 광의의 하자개념에는 위법과 부당이 모두 포함되며, 협의의 하자란 위법한 경우만 의미한다. 이하 행정행위의 무효와 취소의 구별실익과 구별기준에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 의의 1. 무효인 행정행위 2. 취소할 수 있는 행정행위 II. 무효와 취소의 구별실익 1. 효력발생여부 2. 선결문제, 하자치유, 하자승계 3. 쟁송형태, 쟁송기간, 사정판결 III. 무효와 취소의 구별기준 1. 학설 2. 판례 3. 검토

I. 의의

1. 무효인 행정행위

무효인 행정행위란 행정행위의 외형은 갖추고 있으나 처음부터 아무런 효력을 발생시키지 않는 행정행위를 말한다.

2. 취소할 수 있는 행정행위

취소할 수 있는 행정행위란 행정행위의 성립에 하자가 있어 권한 있는 기관이 그 법률상의 효력을 소멸시킬 수 있는 행정행위를 말한다. 취소할 수 있는 행정행위는 일단 유효하게 성립되어 효력을 발생시키고 있으므로 취소하기 전까지는 유효한 행위로 통용된다.

II. 무효와 취소의 구별실익

1. 효력발생여부

무효인 행정행위는 처음부터 아무런 효력이 발생하지 않고, 취소할 수 있는 행정행위는 취소될 때까지 유효하다.

2. 선결문제, 하자치유, 하자승계

① 민·형사법원은 무효인 행정행위의 무효 여부가 선결문제가 될 경우 무효 확인이 가능하나, 취소할 수 있는 행정행위의 효력을 부인할 수 없고, 위법 여부의 판단은 가능하다. ② 하자치유는 무효인 행정행위는 불인정, 취소할 수 있는 행정행위는 인정가능성이 있다. ③ 무효인 선행행위 하자는 후행행위에서도 무효로, 하자승계 논의가 불필요하며, 취소할 수 있는 행정행위는 선행행위가 동일한 법률효과를 목적으로 하거나 일정한 요건 하에 선행행위 하자가 승계된다.

3. 쟁송형태, 쟁송기간, 사정판결

① 쟁송형태는 무효인 행정행위는 무효확인심판이나 무효확인소송을, 취소할 수 있는 행정행위는 취소심판이나 취소소송을 취한다. ② 쟁송기간은 무효인 행정행위는 제한 없고, 취소할 수 있는 행정행위는 제한이 있다. ③ 사정판결은 무효인 행정행위는 불인정하고, 취소할 수 있는 행정행위는 인정가능성이 있다.

III. 무효와 취소의 구별기준

1. 학설

① 하자가 중대하면 무효라는 중대설, ② 하자의 내용이 중대하고, 외관상 객관적으로 명백하면 무효라는 중대명백설, ③ 중대성을 기준으로 하되, 제3자나 공공의 신뢰보호가 필요한 경우 보충적으로 명백성을 요구하는 명백성 보충요건설, ④ 구체적 개별적으로 결정한다는 구체적가치형량설이 있다.

2. 판례

대법원은 중대·명백설의 입장을 취하고 있고, 헌법재판소도 원칙적으로 중대·명백설을 취하고 있지만, 예외를 인정한다. 대법원은 중대명백성 판별기준에 대해 법규의 목적, 의미, 기능 등을 목적론적으로 고찰함과 동시에 구체적 사안의 특수성에 관한 합리적 고찰을 요한다고 판시한 바 있다.

3. 검토

행정의 법적 안정성과 국민의 권리구제의 요청을 적절히 조화시키는 측면에서 통설·판례와 같이 무효와 취소에 대한 객관적인 기준을 정립하여 판별하는 중대·명백설이 타당하다.

<p.45 하자의 유형>

05. 행정행위의 하자의 유형에 대해 설명하시오. (5점)

목차
I. 개요
II. 주체상 하자
III. 절차상 하자
IV. 형식상 하자
V. 내용상 하자

I. 개요

행정행위의 하자의 유형에는 주체에 관한 하자, 절차에 관한 하자, 형식에 관한 하자 및 내용에 관한 하자가 있으며, 내용상 하자를 제외한 주체, 절차, 형식상의 하자를 넓은 의미에서 형식적 하자라고 부르기도 한다.

II. 주체상 하자

행정행위는 정당한 권한이 있는 행정기관에 의해서 행해져야 한다. 따라서 권한이 없는 행정기관에 의한 행위나 합의제 행정기관이나 의결기관 등에 구성원 수 미달, 결격자가 참가한 등 구성상에 하자가 있는 경우를 주체상 하자라고 하고 주체상 하자는 원칙적으로 무효가 된다.

III. 절차상 하자

법률에서 규정된 절차 중 어느 하나를 거치지 않거나 거쳤으나 절차상 하자가 있는

행정행위는 위법한 행정행위가 된다.

IV. 형식상 하자

법령상 문서나 기타 형식을 요구하는 경우에 그에 의하지 않으면 형식상 하자있는 행정행위가 된다. 예로는 서명날인, 이유부기 등을 결한 행위가 있다.

V. 내용상 하자

행정행위는 법령을 위반하지 않아야 하고 실현가능하며 명확하여야 한다. 따라서 그 내용이 법령을 위반한 것이거나 사실상 실현 불가능 하거나 불명확한 행위는 위법한 행위가 된다.

<p.45~p.47 하자의 치유>

부동산 가격공시에 관한 법률 제10조(개별공시지가의 결정·공시 등)

④ 시장·군수 또는 구청장이 개별공시지가를 결정·공시하는 경우에는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 **토지가격비준표**를 사용하여 지가를 산정하되, 해당 토지의 가격과 표준지공시지가가 균형을 유지하도록 하여야 한다.

행정절차법 제21조(처분의 사전통지)

② 행정청은 청문을 하려면 청문이 시작되는 날부터 **10일 전까지** 제1항 각 호의 사항을 당사자들에게 **통지하여야 한다.** (생략)

06. 하자치유에 대해 설명하고 다음 각 경우 하자치유가 가능한지 검토하시오. (10점)

1) 토지가격비준표의 적용오류가 있는 당초 개별공시지가가 토지가격비준표를 제대로 적용하여 정정한 개별공시지와 동일하게 산정된 경우 당초 개별공시지가(※토지가격비준표 적용상 오류는 일반적으로 내용상 하자로 본다.)

2) 국토교통부장관이 甲평가사에게 자격취소처분을 하기 위해 청문을 실시하고 자 청문기일 5일 전 통지했으나 甲평가사가 청문기일에 출석하여 방어의 기회를 충분히 가진 경우

목차

I. 쟁점의 정리

II. 하자치유

1. 의의
2. 인정여부
3. 적용영역
4. 요건 및 한계
5. 효과

III. 사안의 검토

1. 사안1) 하자치유 불가능 검토
2. 사안2) 하자치유 가능 검토

I. 쟁점의 정리

하자치유에 대해 설명하고, 내용상 하자인 토지가격비준표 적용상 오류의 하자치유 여부와 청문기일 오류라는 절차상 하자의 하자치유 여부를 각각 검토한다.

II. 하자치유

1. 의의

하자의 치유란 성립 당시에 하자가 있는 행정행위라 하더라도 사후에 그 하자를 보완하였다는가 또는 그 하자가 취소를 요하지 않을 정도로 경미해진 경우에 그 행위를 적법한 것으로 보아 효력을 유지시키는 것을 말한다.

2. 인정여부

학설은 ① 행정의 능률성 측면에서 하자의 치유를 인정하는 <긍정설>, ② 법치주의 관점에서 원칙적으로 부정하는 <부정설> 및 ③ 국민의 방어권 보장을 침해하지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용해야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다. 판례는 법치주의 관점에서 원칙적으로 허용될 수 없으나 예외적으로 행정행위의 무효한 반박을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 이를 허용할 수 있으나 이 경우에도 국민의 권리나 이익을 침해하지 않아야 한다고 하여 제한적 긍정설의 입장을 취하고 있다. 생각건대, 법치주의의 원칙상 원칙적으로 부정함이 타당하나 행정의 능률성 등을 종합 고려하여 판례와 같이 제한적으로 긍정함이 타당하다.

3. 적용영역

전통적 견해와 판례는 하자의 치유는 취소할 수 있는 행위에만 인정되고, 무효인 행정행위에는 인정하지 않는다고 본다. 또한 내용상 하자도 치유 가능하다고 보는 견해도 있으나 행정의 법률적합성의 원칙을 고려할 때 부정하는 것이 타당하다. 따라서 하자의 치유는 취소할 수 있는 행위와 절차상 하자 또는 형식상 하자에만 가능하다고 보는 것이 일반적이다.

4. 요건 및 한계

①요건의 사후보완만을 엄밀한 의미의 하자의 치유 요건으로 보고, ②제한적 긍정설의 입장에 따라 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 행정행위 하자의 치유를 고려해야하는 실체적 한계가 있다. ③시간적 한계와 관련하여 <쟁송제기이전시설>, <소송제기이전시설>, <쟁송종결이전시설>이 있으나 판례는 이유제시(부기)가 결여된 과세처분의 하자치유와 관련하여 늦어도 처분에 대한 불복여부의 결정 및 불복신청에 편의를 줄 수 있는 상당한 기간 내에 하여야 한다고 하여, 쟁송제기이전시설을 취하고 있다. 행정의 효율성과 공정한 행정 및 사전적 권리구제 기능 등을 종합 고려하여 쟁송제기 전까지 가능하다고 보는 <쟁송제기이전시설>이 타당하다.

5.효과

하자의 치유는 소급효가 있다. 즉, 행정행위의 하자가 치유되면 당해 행정행위는 치유시가 아니라 처음부터 하자가 없는 적법한 행정행위로서 그 효력이 발생한다.

Ⅲ. 사안의 검토

1. 사안1) 하자치유 불가능 검토

①토지가격비준표 적용상 오류는 일반적으로 내용상 하자로 본다. 내용상 하자도 치유 가능하다고 보는 견해도 있으나 행정의 법률적합성의 원칙을 고려할 때 부정하는 것이 타당하다. ②대법원도 “선행처분인 개별공시지가결정이 위법하여 그에 기초한 개발부담금 부과처분도 위법하게 된 경우 하자의 치유를 인정하면 개발부담금 납부의무자로서는 위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로, 그 후 적법한 절차를 거쳐 공시된 개별공시지가결정이 종전의 위법한 공시지가결정과 그 내용이 동일하다는 사정만으로는 위법한 개별공시지가결정에 기초한 개발부담금 부과처분이 적법하게 된다고 볼 수 없다.”고 판시한바 있다. ③행정의 법률적합성 측면과 국민의 방어권보장 측면에서 사안1)의 하자치유는 불가능하다.

2. 사안2) 하자치유 가능 검토

①행정절차법21조2항은 청문기일 10일전까지 통지하도록 하나, 사안2)에서 청문기일 5일전 통지하여 절차상 하자가 있다. ②대법원은 “행정청이 식품위생법상의 청문절차를 이행함에 있어 청문서 도달기간을 다소 어겼지만 영업자가 이의하지 아니한

채 청문일에 출석하여 의견을 진술하고 변명하는 등 방어의 기회를 충분히 가진 경우 하자는 치유되었다고 봄이 상당하다.”판시한바 있다. ③국민의 방어권 보장을 침해하지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용하는 입장에서 보더라도 사안2)는 청문기일을 다소 어겼으나 甲평가사의 방어기회를 충분히 가졌으므로 그 하자는 치유될 수 있다고 본다.

<p.48 하자있는 행정행위의 전환>

07. 하자있는 행정행위의 전환에 대해 설명하시오. (5점)

목차
I. 의의
II. 인정근거 및 인정요건
III. 전환의 성질 및 효과

I. 의의

하자 있는 행정행위의 전환이란 하자가 있는 행정행위가 행정청이 처음에 의도한 행정행위로서는 하자가 있지만 다른 행정행위의 적법요건을 갖춘 경우 다른 행정행위로서 효력발생을 인정하는 것을 말한다. 예를 들면 사망자에게 한 과세처분을 상속자에 인정하는 것을 말한다.

II. 인정근거 및 인정요건

하자 있는 행정행위의 전환은 행정의 법적 안정성을 도모하고 무용한 행정행위의 반복을 피하기 위해 인정된다. 하자있는 행정행위의 전환이 인정되기 위해서는 ① 전환 전 행정행위와 전환 후의 행정행위가 요건, 목적, 효과 등에서 실질적인 공통성이 있어야 하고, ② 전환되는 행정행위는 성립·효력요건을 갖추어야 하며, ③ 상대방 및 제3자의 권익을 침해하지 않아야 하고, ④ 당사자에게 불이익한 법적 효과를 초래하지 않아야 한다.

III. 전환의 성질 및 효과

행정행위의 전환을 하나의 행정행위로 보는 견해가 통설이다. 따라서 전환 행위는 처분성이 인정되어 이해관계인은 전환 행위에 대해 항고소송을 제기할 수 있고, 전환으로 인해 생긴 새로운 행정행위는 종전 행정행위의 발령 당시에 소급하여 효력이 발생한다.

<p.48~p.51 하자의 승계>

08. 甲은 취소정도의 위법한 개별공시지가결정에 대하여 개별통지를 받고도 부동산 가격공시에 관한 법령에 따른 이의신청이나 행정심판법에 따른 행정심판과 행정소송법에 따른 행정소송을 제기하지 않았고, 당해 개별공시지가결정에 불가쟁력이 발생하였다. 그 후 B시장은 이 사건 토지에 대한 개별공시지가를 시가표준액으로 하여 재산세를 부과·처분하였다. 이에 甲은 이 사건 토지에 대한 개별공시지가결정의 하자를 이유로 재산세부과처분에 대하여 취소소송을 제기하였다. 甲의 청구가 인용될 수 있는지에 관하여 설명하시오. (15점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 관련행정작용의 법적성질 (개별공시지가결정과 재산세 부과처분의 처분성)
III. 개별공시지가결정의 위법성 및 정도 (취소정도의 위법성) ※문제에서 제시되지 않은 경우 별도 검토 필요
IV. 청구 인용 가능성 - 소송요건(해당 내용에서 후술) - 하자승계 논의 - 의의 - 전제요건 (1)요건 (2)검토 - 인정범위 (1)학설 (2)판례 (3)검토 - 사안의 경우

I. 쟁점의 정리

사안의 개별공시지가결정의 하자를 이유로 재산세부과처분에 대하여 한 취소소송 청구가 인용될 수 있는지 하자승계논의로 검토한다.

II. 관련행정작용의 법적성질 (개별공시지가결정과 재산세 부과처분의 처

분성)

① 개별공시지가가 시군구청장이 공시기준일 당시 표준지의 공시지가를 기준으로 산정한 개별토지의 단위면적당 가격을 말하며 견해대립이 있으나 국민의 권리의무에 영향을 미치는 권력작용인바 처분이다. ② 재산세 부과처분은 급부하명의로 처분이다.

III. 청구 인용 가능성

1. 소송요건(해당 내용에서 후술)

① 재산세 부과처분은 처분으로 대상적격 인정되고, ② 처분의 당사자인 甲은 법률상 이익이 있어 원고적격 인정되며, ③ 협의 소익, 제소기간, 심판전치, 관할법원, 피고적격 등 다른 소송요건엔 문제없다.

2. 하자승계 논의

1) 의의

행정행위의 하자의 승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 행해지는 경우 일정한 요건 하에서 선행행위의 위법이 후행 행정행위에 승계되어 후행 행정행위를 다룰 수 있게 되는 것을 말한다. 법적안정성과 국민의 권리구제의 조화에 그 취지가 인정된다.

2) 전제요건

(1) 요건

① 선·후행행위 모두 처분일 것 ② 선행행위에 취소사유가 존재하고 불가쟁력이 발생할 것 ③ 후행행위 적법할 것을 요건으로 한다.

(2) 검토

사안의 ① 선·후행행위 모두 처분이고, ② 선행행위에 취소사유가 존재하고 불가쟁력이 발생하였으며, ③ 후행행위는 적법한바, 전제요건을 충족한다.

3) 인정범위

(1) 학설

① 선·후행행위가 결합하여 하나의 법률효과의 발생을 목적으로 하는 경우 하자승계를 인정하는 전통적 하자승계론과 ② 예측 불가능하거나 수인 불가능한 경우 구속력이 배제되어 하자승계가 인정된다는 구속력론이 대립한다.

(2) 판례

판례는 기본적으로 전통적 하자승계론 입장이나 예외적으로 예측불가능이나 수인한도를 이유로 하자승계를 인정한바 있다. 그러나 재조사청구에 따른 조정결정을 통지받고서도 더 이상 다투지 아니한 경우까지 선행처분인 개별공시지가 결정의 불가쟁력이나 구속력이 수인한도를 넘는 가혹한 것이거나 예측불가능하다고 볼 수 없

어, 위 개별공시지가 결정의 위법을 이 사건 과세처분의 위법사유로 주장할 수 없다고 판시한다.

(3) 검토

하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력론은 예측 가능성과 수인가능성을 고려한다는 점에서 구체적 타당성을 기할 수 있으므로 양자 모두 합리성이 인정 된다. 따라서 동일한 법률효과를 목적으로 하는 경우를 기준으로 별개의 법률효과를 목적으로 하는 경우에도 예측 불가능하거나 수인 불가능 한 사정 등을 종합 고려하여 하자 승계를 인정하는 것이 타당하다.

3. 사안의 경우

① 개별공시지가 결정과 재산세 부과처분은 서로 다른 법률효과의 발생을 목적으로 하는 점 ② 사안의 개별공시지가 결정은 개별통지되어 甲이 충분히 다룰 수 있었음에도 불구하고 다투지 않은 경우로 예측불가능하다거나 수인한도를 넘는 가혹한 결정이라고 보기 어려운바 하자승계 인정은 어려울 것이다.

하자승계를 긍정한 판례	하자승계를 부정한 판례
① 행정대집행의 각 단계 [95누12507] ② 표준지공시지가와 수용재결 간 [2007두13845] ③ 개별공시지가와 과세처분(개별통지 안 한 경우) [93누8542]	① 건물 철거명령과 대집행 계고 간 [97누20502] ② 개별공시지가와 과세처분 간(개별통지 한 경우) [96누6059] ③ 표준지공시지가와 개별공시지가 간 [96누6851] ④ 사업인정과 수용재결 간 [2000두5142] ⑤ 사업시행계획과 관리처분계획 간 [2010두13463] ⑥ 도시관리계획과 실시계획인가 간 [2016두49938]

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 기본강의 4회

<p.52~p.54 행정행위의 직권취소>

09. 감정평가법 13조1항1호에 따르면 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우 국토교통부장관은 그 자격을 취소하도록 규정하고 있다. 이하 행정행위의 직권취소에 대해 설명하시오. (10점)

목차

I. 의의

II. 직권취소의 법적근거

III. 직권취소의 제한

IV. 직권취소의 위법성 판단

1. 비례의 원칙 (「행정기본법」 제10조)
2. 신뢰보호의 원칙 (「행정기본법」 제12조 제1항)
3. 실권의 법리 (「행정기본법」 제12조 제2항)

V. 직권취소의 효과

VI. 직권취소의 재취소

I. 의의

행정행위의 취소란 위법 또는 부당한 하자를 이유로 행정행위를 발령한 처분청 등 권한 있는 기관이 행정행위의 효력을 소멸시키는 행위를 말한다. 취소는 처음부터 아무런 효력이 없는 무효나 성립 이후의 하자를 이유로 하는 철회와 구별된다.

II. 직권취소의 법적근거

행정행위를 행한 처분청이 그 행정행위를 취소할 수 있는 권한을 가진다고 보는 것이 통설·판례의 태도이다. 현재는 행정기본법이 규정되어 행정기본법 제18조를 통

해 행정행위의 직권취소를 명확하게 명문화하고 있으며, 기타 개별법률에서도 직권취소에 대해 규정을 두고 있는 경우가 적지 않다.

III. 직권취소의 제한

①침익적 행정행위의 직권취소는 원칙적으로 자유롭다. ②수익적 행정행위의 직권취소는 상대방에게 침익적 행위가 되므로 수익적 행정행위의 취소권 행사는 제한을 받는다. 특히, 비례의 원칙이나 신뢰보호의 원칙에 위배되어서는 안 되고, 취소권 행사에 재량권 일탈·남용이 있으면 위법한 처분이 된다.

IV. 직권취소의 위법성 판단

①비례의 원칙 (「행정기본법」 제10조) ②신뢰보호의 원칙 (「행정기본법」 제12조 제1항) ③실권의 법리 (「행정기본법」 제12조 제2항) 등으로 위법성을 판단한다.

V. 직권취소의 효과

행정청은 위법 또는 부당한 처분을 소급하여 취소하거나 정당한 사유가 있는 경우에 장래를 향하여 취소할 수 있다고 행정기본법 제18조 제1항에서 규정하고 있다. 일반적으로 침익적 행정행위의 취소의 효력은 소급적이라고 보고, 수익적 행정행위의 취소의 효력은 상대방에게 귀책 사유가 없는 한 소급하지 않는다고 본다. 다만, 상대방에게 귀책 사유가 없는 경우에도 소급효를 인정하지 않는 것이 심히 공익에 반하는 경우에는 소급효를 인정하기도 하며, 복효적 행정행위는 상대방과 제3자의 이익을 비교형량하여 취소의 소급 또는 불소급을 개별적으로 결정한다.

VI. 직권취소의 재취소

①직권취소도 하나의 행정행위로서 그 직권취소에 하자가 있는 경우 해당 취소처분을 다투어 취소시킴으로써 원처분(원행정행위)의 효력을 회복시킬 수 있는지가 문제된다. ②견해가 나뉘나, 판례는 수익적 행정행위의 취소의 취소는 긍정하나, 침익적 행정행위의 취소의 취소는 부정한다. 또한 수익적 행정행위의 경우에도 수익적 행정행위가 취소된 후 새롭게 제3자의 권익이 형성되어 재취소시 그 이익이 침해되는 경우에는 취소의 취소가 허용되지 않는다고 판시한 바 있다. ③직권취소는 독립된 행정처분이므로 취소처분에 하자가 있다면 그 하자의 시정을 위해 직권취소의 취소를 인정하여야 한다. 다만, 직권취소 후 새로운 이해관계 등이 있는 경우 취소권 제한 법리인 이익형량으로 해결하는 것이 타당하다.

<p.54 행정행위의 철회>

10. 감정평가법 13조1항2호에 따르면 징계로 인한 자격취소를 규정하고 있다. 이하 행정행위의 철회에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 의의
II. 철회의 법적근거
III. 철회의 사유
IV. 철회의 제한
V. 철회의 효과

I. 의의

행정행위의 철회란 적법하게 성립한 행정행위에 대해 그 효력을 존속시킬 수 없는 새로운 사정이 발생하였음을 이유로 장래에 향하여 그의 효력을 소멸시키는 행위를 말한다.

II. 철회의 법적근거

행정기본법이 제정되기 전에는 철회의 법적근거가 필요한가에 대해 근거필요설, 근거불요설, 절충설이 대립하였는데, 현재는 행정기본법 제19조에서 철회의 근거를 명문화하고 있다.

III. 철회의 사유

행정기본법 제19조 제1항에서 철회의 사유를 명문화 하고 있다. 규정을 살펴보면

① 법률에서 정한 철회 사유에 해당하게 된 경우, ② 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우, ③ 중대한 공익을 위하여 필요한 경우가 있다.

IV. 철회의 제한

① 침익적 행정행위의 철회는 상대방에게 이익을 가져다주므로 별다른 제한을 받지 않고 자유롭게 할 수 있음이 원칙이다. ② 수익적 행정행위의 철회는 상대방의 신뢰와 법적 안정성을 해할 우려가 있으므로 철회사유가 발생한 경우에도 철회를 하여야 하는 공익상의 필요, 상대방의 신뢰, 기득권 보호, 법적 안정성의 유지 등 관련된 모든 이익을 비교·형량하여 철회 여부를 결정하여야 한다. 따라서 직권취소와 마찬가지로 비례의 원칙이나 신뢰보호의 원칙 등을 위배하여 행한 철회는 위법한 처분이 된다.

V. 철회의 효과

행정기본법 제19조 제1항에서 '행정청은 적법한 처분이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다'고 규정하고 있다. 따라서 철회의 효과는 언제나 장래를 향한다 (장래효).

<p.56 행정행위의 실효>

11. 다음은 토지보상법상 실효제도이다. 행정행위의 실효에 대해 설명하시오.
(5점)

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)

제23조(사업인정의 실효) ① 사업시행자가 제22조제1항에 따른 사업인정의 고시(이하 "사업인정고시"라 한다)가 된 날부터 1년 이내에 제28조제1항에 따른 재결신청을 하지 아니한 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.

제24조(사업의 폐지 및 변경) ① 사업인정고시가 된 후 사업의 전부 또는 일부를 폐지하거나 변경함으로써 인하여 토지등의 전부 또는 일부를 수용하거나 사용할 필요가 없게 되었을 때에는 사업시행자는 지체 없이 사업지역을 관할하는 시·도지사에게 신고하고, 토지소유자 및 관계인에게 이를 통지하여야 한다.

② 시·도지사는 제1항에 따른 신고를 받으면 사업의 전부 또는 일부가 폐지되거나 변경된 내용을 관보에 고시하여야 한다.

③ 시·도지사는 제1항에 따른 신고가 없는 경우에도 사업시행자가 사업의 전부 또는 일부를 폐지하거나 변경함으로써 인하여 토지를 수용하거나 사용할 필요가 없게 된 것을 알았을 때에는 미리 사업시행자의 의견을 듣고 제2항에 따른 고시를 하여야 한다.

(중략)

⑥ 제2항 및 제3항에 따른 고시가 된 날부터 그 고시된 내용에 따라 사업인정의 전부 또는 일부는 그 효력을 상실한다.

제42조(재결의 실효) ① 사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하거나 공탁하지 아니하였을 때에는 해당 토지수용위원회의 재결은 효력을 상실한다.

I. 행정행위의 실효

행정행위의 실효란 하자 없이 적법하게 성립한 행정행위가 일정한 사실의 발생에 의하

여 장래를 향하여 그 효력이 소멸되는 것을 말한다. 취소와 철회는 행정청의 의사표시가 필요하나, 실효는 행정청의 의사표시와 무관하게 당연히 효력이 소멸한다는 점에서 차이가 있다. 실효사유가 발생하면, 그 행정행위는 행정청의 특별한 의사표시 없이 장래를 향해 당연히 소멸 된다.

II. 토지보상법상 실효제도

1. 사업인정의 실효(토지보상법 23조)

사업시행자가 제22조제1항에 따른 사업인정의 고시가 된 날부터 1년 이내에 제28조제1항에 따른 재결신청을 하지 아니한 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.

2. 사업의 폐지 및 변경으로 인한 실효(토지보상법 24조)

사업인정고시가 된 후 사업의 전부 또는 일부의 폐지·변경으로 토지등의 전부 또는 일부를 수용·사용할 필요가 없게 된 때 사업시행자의 신고로 시도지사의 고시가 된 날부터 그 고시된 내용에 따라 사업인정의 전부 또는 일부는 그 효력을 상실한다. 사업시행자의 신고없이 그 사실을 시도지사가 알게 된 경우도 마찬가지이다.

3. 재결의 실효

사업시행자가 수용 또는 사용의 개시일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하거나 공탁하지 아니하였을 때에는 해당 토지수용위원

<p.57~64 행정행위의 부관>기출13회 1번형

01. p.57~p.58 행정행위의 부관의 의의, 근거, 종류

택지조성사업을 하고자 하는 기업자 甲은 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하였다. 甲의 사업인정신청에 대해 국토교통부장관은 택지조성사업 면적의 50%를 택지 이외의 다른 목적을 가진 공공용지로 조성하여 기부채납할 것을 조건으로 사업인정을 하였다. 甲은 해당 부관의 내용이 너무 과다하여 수익성을 도저히 맞출 수 없다고 판단하여 취소소송을 제기하려 한다.

※사업인정은 공익사업을 토지 등을 수용·사용할 사업으로 결정하는 것으로 판례는 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 형성행위라 판시한 바 있다. 법문언상 불분명하나 토지보상법의 입법목적, 취지, 행위의 성질, 공익 관련성 등을 종합적으로 판단할 때 재량행위로 봄이 타당하다.

이하 행정행위의 부관의 의의, 근거, 종류를 설명하고, 사안의 기부채납 조건의 법적성질을 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 행정행위의 부관
1. 의의 및 구별개념
2. 법적근거
3. 부관의 종류
4. 부담과 조건의 구별
III. 사안 검토(기부채납 조건의 법적성질)

I. 쟁점의 정리

행정행위의 부관에 대해 설명하고, 사안의 기부채납이 부담인지 검토한다.

II. 행정행위의 부관

1. 의의 및 구별개념

부관은 주된 행정행위의 효과를 제한하거나 의무를 부과하기 위해 부가된 종된 규율을

말한다. 주된 행정행위에 부가 되는 부관은 종속적인 지위를 가지고 주된 행정행위에 의존하는 부종성을 가지므로 명문의 규정이나 약정이 없는 한 주된 행정행위가 효력을 상실하면 부관도 효력을 상실한다. 행정행위의 부관은 법령이 직접 행정행위의 조건, 기한 등을 정하는 법정부관과 구별된다. 법정부관은 법령의 규정에 의한 것으로 행정행위의 부관에 적용되는 부관의 한계 등이 적용되지 않아 양자를 구별함이 필요하다.

2. 법적근거

행정기본법 제17조가 행정행위의 부관에 대한 일반법적 근거가 되며 부관의 요건 및 한계를 명문화하고 있다.

3. 부관의 종류

①<조건>이란 행정행위의 효력의 발생·소멸을 장래에 발생 여부가 불확실한 사실에 의존시키는 부관을 말한다. ②<기한>이란 행정행위의 효력 발생·소멸을 장래 도래할 것이 확실한 사실에 의존시키는 부관을 말한다. ③<부담>이란 행정행위의 주된 내용에 부가하여 상대방에게 작위·부작위·급부·수인 등의 의무를 부과하는 부관을 말한다. ④<철회권 유보>란 일정한 경우에 행정행위를 철회하여 행정행위의 효력을 소멸시킬 수 있음을 정한 부관을 말한다.

4. 부담과 조건의 구별

①부담은 다른 부관과 달리 그 자체를 하나의 행정행위로 보아 독립하여 강제집행의 대상이 되고, 행정쟁송의 대상이 될 수 있으나 조건은 그러하지 않아 <구별에 실익>이 있다. 실무적으로 부담을 조건이라고 부르기도 하므로 일정한 기준으로 양자를 구별함이 필요하다. ②부담과 조건의 구별은 표현된 용어보다 <행정청의 객관적인 의사>를 고려하여 판단하여야 한다. 행정청이 행정행위의 효력 자체를 그 조건에 의존시키려는 의사였을 경우에는 조건으로 보고 그렇지 않은 경우에는 부담으로 볼 수 있다. 또한 행정청의 의사가 불분명한 경우에는 <최소침해의 원칙>에 따라 상대방에게 유리하게 부담으로 추정하여야 한다.

III. 사안 검토(기부채납 조건의 법적성질)

①국토교통부장관이 사업인정의 효력 자체를 기부채납에 의존시킬 의사는 아닌 것으로 보이나, ②그 의사가 불분명하다 할지라도 최소침해 원칙에 따라 상대방에게 유리하게 부담으로 추정할 수 있을 것이다.

<p.57~64 행정행위의 부관>기출13회 1번형

02. p.61~p.62 부관의 독립쟁송가능성과 쟁송형태(소송요건)

택지조성사업을 하고자 하는 기업자 甲은 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하였다. 甲의 사업인정신청에 대해 국토교통부장관은 택지조성사업 면적의 50%를 택지 이외의 다른 목적을 가진 공공용지로 조성하여 기부채납할 것을 조건으로 사업인정을 하였다. 甲은 해당 부관의 내용이 너무 과다하여 수익성을 도저히 맞출 수 없다고 판단하여 취소소송을 제기하려 한다.

※사업인정은 공익사업을 토지 등을 수용·사용할 사업으로 결정하는 것으로 판례는 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 형성행위라 판시한 바 있다. 법문언상 불분명하나 토지보상법의 입법목적, 취지, 행위의 성질, 공익 관련성 등을 종합적으로 판단할 때 재량행위로 봄이 타당하다.

사안의 기부채납조건의 독립쟁송가능성과 쟁송형태에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 부관의 독립쟁송 가능성(소송요건) 1. 학설 2. 판례 3. 검토 III. 쟁송형태 1. 부관에 대한 쟁송형태 2. 견해별 쟁송형태 및 사안 검토 IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

소송요건의 문제로서 주된 행정행위와 분리하여 부관만을 소송대상으로 삼을 수 있는지와 이때, 소송형태는 무엇인가가 문제 된다.

II. 부관의 독립쟁송 가능성(소송요건)

1. 학설
- ① '처분의 일부취소'가 가능한 만큼 소의 이익이 있다면 모든 위법한 부관에 대해 독립하여 행정쟁송을 제기할 수 있다고 보는 <모든부관가능성설>, ② 독립쟁송가능의 문제

는 부관의 독립 취소가능성 문제의 전제조건이므로 독립취소가 인정될 수 있을 정도의 독자성(주된 행정행위와의 분리가능성)이 있다면 부관만 독립하여 행정쟁송으로 다룰 수 있다고 보는 <분리가능성설> 및 ③ 부담은 그 자체가 독립된 행정행위이므로 부담만이 독립적으로 행정쟁송 제기가 가능하고 이외의 부관은 부관부행정행위 전체를 소의 대상으로 삼아야 한다고 보는 <부담·기타부관 구별설>이 있다.

2. 판례

대법원은 일관되게 부담만이 항고소송의 대상이 될 수 있다고 보며, 기타 부관은 독립하여 항고소송의 대상이 될 수 없다는 입장이다. 또한 부담을 제외한 기타 부관만의 취소를 구하는 소송에 대하여는 각하판결을 하여야 한다고 본다.

3. 검토

<모든부관가능성설>은 부담 이외의 기타 부관은 처분성이 인정되지 않는다는 점을 간과한다는 문제가 있고, <분리가능성설>은 분리가능성이라는 본안문제를 소송요건 단계에서 고려한다는 문제가 있다. 생각건대, 부관의 독립쟁송가능성은 부관의 독립취소가 성립의 전제조건으로 파악하여 처분성이 인정되는 부담만이 독립쟁송가능하다고 보는 <부담·기타부관구별설>이 타당하다. 사안의 기부채납조건은 부담인바 독립쟁송가능하다.

III. 쟁송형태

1. 부관에 대한 쟁송형태

위법한 부관을 다루는 쟁송형태로는 학설상 논의되고 있는 것은 부관 그 자체에 대해 소를 제기하고 부관만의 위법성을 소송물로 보고 심리하는 진정일부취소소송, 부관부행정행위 전체를 소의 대상으로 하고 부관 자체의 위법만을 소송물로 보고 심리하는 부진정일부취소소송, 부관부 행정행위 전체를 소의 대상으로 하고 본안에서 부관부 행정행위 전체의 위법성을 소송물로 하는 전체 취소소송이 있다.

2. 견해별 쟁송형태 및 사안 검토

①<모든부관가능성설>은 부담은 진정일부취소소송, 기타부관은 부진정일부취소소송 형태를, ②<분리가능성설>은 분리가능성이 없다면 부진정일부취소소송으로, 분리가능하다면 처분성이 있는 부담은 진정일부취소소송, 처분성 없는 기타 부관은 전체 행정행위를 대상으로 부진정일부취소소송 형태를 취한다. ③<부담·기타부관구별설>은 부담은 진정일부취소소송, 기타부관은 부진정일부취소소송 형태를 취한다. ④<판례>는 부진정일부취소소송을 인정하지 않으므로, 부담만이 독립쟁송가능하며 진정일부취소소송으로 다룰 수 있다고 본다. 또한 기타부관은 부관부 행정행위 전체의 취소를 구하거나 행정청에 부관이 없는 처분으로 변경을 청구한 후 그것이 거부된 경우 비로소 거부처분취소소송을 제기하여야 한다는 입장이다. ⑤사안은 <진정일부취소소송> 형태를 취할 것이다.

IV. 사안의 해결

사안의 기부채납조건은 부담으로 독립쟁송이 가능하고, 진정일부취소소송 형태를 취할 것이다.

<p.57~64 행정행위의 부관>기출13회 1번형

03. p.58 부관의 가능성, p.59 부관의 한계 등 부관의 위법성 검토(본안판단)

택지조성사업을 하고자 하는 기업자 甲은 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하였다. 甲의 사업인정신청에 대해 국토교통부장관은 택지조성사업 면적의 50%를 택지 이외의 다른 목적을 가진 공공용지로 조성하여 기부채납할 것을 조건으로 사업인정을 하였다. 甲은 해당 부관의 내용이 너무 과다하여 수익성을 도저히 맞출 수 없다고 판단하여 취소소송을 제기하려 한다.

※사업인정은 공익사업을 토지 등을 수용·사용할 사업으로 결정하는 것으로 판례는 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 형성행위라 판시한 바 있다. 법문언상 불분명하나 토지보상법의 입법목적, 취지, 행위의 성질, 공익 관련성 등을 종합적으로 판단할 때 재량행위로 봄이 타당하다.

사안의 기부채납조건의 위법성을 검토하시오. (15점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 부관의 가능성(본안판단)
III. 부관의 내용상 한계
1. 적법성(행정기본법 제17조 제4항)
2. 비례원칙 위반여부(행정기본법 제10조)
3. 부당결부금지원칙 위반여부(행정기본법 제13조)
IV. 관련판례
V. 사안 검토(기부채납조건의 위법성)

I. 쟁점의 정리

기부채납조건의 위법성을 부관의 가능성과 행정기본법 17조4항 및 비례원칙, 부당결부금지원칙 등에 비추어 검토한다.

II. 부관의 가능성(본안판단)

종래에는 견해대립이 있었으나 최근에는 준법률행위적 행정행위나 기속행위의 경우에도

일정한 경우 부관이 부착 가능한 경우가 있고, 재량행위도 부관의 부착이 불가능한 경우가 있으므로 개별적으로 검토 하여야 한다고 보는 것이 일반적인 견해이다. 또한 행정기본법이 제정되었으므로 행정기본법 제17조 제1항 및 제2항에 규정된 바에 따라 재량행위와 기속행위에 부관이 부착될 수 있으며 특히, 기속행위의 경우 법률에 근거가 있는 경우에만 가능하며 판례도 동일한 입장이다.

III. 부관의 내용상 한계

1. 적법성

1) 행정기본법 제17조 제4항

①부관은 행정행위에 부가되는 종된 규율로서 행정행위의 한 구성부분이 된다. 따라서 행정행위와 마찬가지로 행정행위로서 법령에 위반되어서는 안 되고 헌법에 보장된 기본권을 침해하여서는 안 된다. ② 이에 행정기본법 제17조 제4항에 따라 해당 처분의 목적에 위배되지 아니할 것, ③해당 처분과 실질적인 관련이 있을 것, ④해당 처분의 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 범위일 것의 요건에 적합해야 한다.

2) 사안검토

①사안의 기부채납조건은 택지조성사업과 다른 목적을 가진 공공용지 조성 목적으로 해당 택지조성사업인정이라는 처분의 목적에 위배되며, ②이에 실질적 관련성이 없고, ③택지조성사업 면적의 50%라는 최소범위도 벗어난바 행정기본법 17조4항에 위반된다.

2. 비례원칙 위반여부

1) 행정기본법 제10조

행정목적과 행정수단 사이에 합리적 비례관계가 있어야 한다는 원칙으로 ①행정목적 달성에 데 유효하고 적절할 것 ②행정목적 달성에 데 필요한 최소한도에 그칠 것, ③행정작용으로 인한 국민의 이익 침해가 그 행정작용이 의도하는 공익보다 크지 아니할 것의 단계적 심사를 통한다.

2) 사안검토

사안의 기부채납조건은 택지조성사업과 다른 목적의 공공용지 조성 목적으로 해당사업의 목적을 달성하는 데 유효·적절하지 않고, 사업 면적의 50%로 너무 과다하며, 택지조성사업으로 인한 공익목적보다 사업의 수익성을 맞출 수 없는 甲의 이익 침해가 과도한바 비례원칙에 위반된다.

3. 부당결부금지원칙 위반여부

1) 행정기본법 제13조

행정기관이 행정작용을 함에 있어 상대방에게 그것과 실질적인 관련이 없는 반대급부를 결부시켜서는 안 된다는 원칙으로 ① 행정청의 공권력 행사가 있을 것, ② 공권력의 행사가 상대방의 반대급부와 결부되어 있을 것, ③ 공권력의 행사와 반대급부 사이에 실질적 관련성이 없을 것을 요건으로 한다.

2) 사안검토

국토교통부장관의 택지조성사업인정이라는 공권력 행사가 있었고, 사업인정에 기업자 甲의 기부채납조건이라는 반대급부와 결부되어 있으며 사업인정과 기부채납조건 사이에 직접적인 인과관계도 없고, 택지조성사업이라는 동일한 행정목적도 추구하지 않고 있는 바, 실질적 관련성이 없다. 따라서 사안의 기부채납조건은 부당결부금지원칙에 위반된다.

IV. 관련판례

소외 인천 시장은 원고에게 주택사업계획승인을 하게 됨을 기회로 그 주택사업과는 아무런 관련이 없는 토지인 위 2,791㎡를 기부채납하도록 하는 부관을 위 주택사업계획승인에 붙인 사실이 인정되므로, 위 부관은 부당결부금지의 원칙에 위반되어 위법하다고 할 것이다.

V. 사안 검토(기부채납조건의 위법성)

사안의 사업인정은 재량행위로 행정기본법 17조 1항에 따라 부관을 붙일 수 있으나, 해당 기부채납조건은 행정기본법 17조 4항, 비례원칙, 부당결부금지원칙 등에 위배되어 위법성이 인정된다.

<p.57~64 행정행위의 부관>기출13회 1변형

04. 본안판단(p.63부관의 독립취소 가능성/p.60행정행위 효력)

택지조성사업을 하고자 하는 기업자 甲은 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하였다. 甲의 사업인정신청에 대해 국토교통부장관은 택지조성사업 면적의 50%를 택지 이외의 다른 목적을 가진 공공용지로 조성하여 기부채납할 것을 조건으로 사업인정을 하였다. 甲은 해당 부관의 내용이 너무 과다하여 수익성을 도저히 맞출 수 없다고 판단하여 취소소송을 제기하려 한다.

※사업인정은 공익사업을 토지 등을 수용·사용할 사업으로 결정하는 것으로 판례는 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정하는 형성행위라 판시한 바 있다. 법문언상 불분명하나 토지보상법의 입법목적, 취지, 행위의 성질, 공익 관련성 등을 종합적으로 판단할 때 재량행위로 봄이 타당하다.

사안의 기부채납조건의 독립취소가능성 및 당해 사업인정의 효력을 검토하시오. (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 부관의 독립취소가능성

1. 학설
2. 판례
3. 검토

III. 위법한 부관과 행정행위의 효력

1. 학설
2. 판례
3. 검토

IV. 사안의 해결(기부채납조건의 독립취소가능성 및 사업인정의 효력)

I. 쟁점의 정리

원고가 부관만의 취소를 구하는 경우에 법원이 그 부관이 위법하다고 판단하여 부관만을 독립하여 취소할 수 있는지 아니면 부관부 행정행위 전체를 취소해야 하는지 검토한 뒤, 부관의 효력이 상실될 경우 위법한 부관이 부착된 행정행위의 효력에 대해 검토한다.

II. 부관의 독립취소가능성

1. 학설

① 기속행위는 법령의 근거 없이 행정청이 임의로 부관을 부가할 수 없으므로 위법한 부관만의 취소가 가능하나(단, 요건충족적 부관 제외), 재량행위의 경우에는 부관이 주된 행정행위의 본질적 요소이므로 부관의 독립 취소를 인정하지 않는 <기속·재량 구별설>, ② 부관이 주된 행정행위의 중요한 요소인지를 기준으로 중요한 요소가 아닌 경우에만 부관의 독립취소를 인정하는 <중요성 기준설> 및 ③ 취소소송의 소송물은 부관의 위법성 그 자체이므로 위법한 부관은 독립 취소 가능하다고 보는 <위법성 기준설> 등이 있다.

2. 판례

판례는 일관되게 부담만이 독립하여 소의 대상이 된다고 보고, 본안에서는 부담만이 소송물이므로 부담만 취소판결 할 수 있다고 본다. 이외의 기타 부관의 경우에는 독립 쟁송가능성을 부정하므로 부관부 행정행위 전체가 소의 대상이 되고, 본안에서는 기속행위에 부가된 부관은 당연무효이므로, 부관만에 대한 무효선언을 하고 본체인 행정행위는 존속시키고, 재량행위의 경우에는 부관이 위법하고 중요한 요소인 경우 법원은 부관부 행정행위 전체를 취소판결하게 된다. 그러나 중요한 요소가 아닌 경우의 법원의 태도는 불명확하다.

3. 검토

부관은 주로 재량행위에 부가되므로 기속·재량 구별설은 부관에 대한 행정소송을 유명무실하게 한다는 문제가 있고, 위법성 기준설은 행정청이 부가한 부관을 법원이 취소하는 것으로 행정청의 의사에 반하게 되어 권력분립의 문제가 발생할 우려가 있다. 따라서 주된 행정행위의 본질적인 요소인지에 따라 판단하는 <중요성 기준설>이 타당하다.

III. 위법한 부관과 행정행위의 효력

1. 학설

위법한 부관이 부착된 행정행위의 효력에 대하여 ① 부관만 무효가 되고, 행정행위에는 아무런 영향을 미칠 수 없다는 견해, ② 부관부 행정행위 전부가 무효가 된다는 견해 및 ③ 원칙적으로 부관이 없는 단순한 행정행위가 되나 예외적으로 부관이 없었다면 주된 행정행위를 하지 않았을 것이라고 인정되는 경우에는 전체 행정행위가 무효가 된다는 견해가 있다.

2. 판례

판례는 기부채납 받은 행정재산에 대한 사용·수익허가에서 허가기간은 행정행위의 본질

적 요소에 해당하므로 허가기간에 위법사유가 있다면 이로써 허가 전부가 위법하게 된다고 본다.

3. 검토

행정청은 수익적 행정행위를 발령할 때 부관을 부착하여 주된 행정행위를 제한하거나 의무를 부과하려는 목적이 있으므로 위법한 부관만을 무효로 보고 부관이 없는 단순한 행정행위로 보는 것은 행정청의 의사에 반하여 타당하지 않다. 따라서 부관과 주된 행정행위의 성질과 관계를 종합 고려하여 판단하는 ③설 타당하다.

IV. 사안의 해결(기부채납조건의 독립취소가능성 및 사업인정의 효력)

①사안의 기부채납조건은 부담으로 독립하여 소의 대상이 되고, 본안에서 독립하여 취소판결이 가능하다. ②이때 기부채납조건이 사안의 택지조성사업인정의 본질적인 요소인지가 중요하데, 당해 기부채납조건의 성질과 사업인정과 관계 등을 따졌을 때 해당 기부채납조건이 없었다면 당해 택지조성사업인정을 하지 않았을 것이라고 보기 어려운바, 해당 조건이 본 처분의 본질적 요소로 보기는 어렵다. ③따라서 사안의 기부채납조건은 독립하여 취소가 가능하며, 당해 택지조성사업인정의 효력은 유지될 것이다.

<p.65 ~ p.66 확약과 사전결정>기출 17회 1-1 변형

05.

甲은 세계품물 야외전시장을 포함하는 미술품 전시시설을 건립하고자 한다. 甲은 자신이 계획하고 있는 시설이 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '토지보상법') 제4조 제4호의 '미술관'에 해당하는지에 관하여 국토교통부장관에게 서면으로 질의하였다. 이에 대하여 국토교통부장관은 甲의 시설이 토지보상법 제4조 제4호에 열거된 '미술관'에 속한다고 서면으로 통보하였다. 그 후 甲은 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하였다.

확약의 의의, 법적성질, 요건 및 효과에 대해 설명하고, 사안에서 국토교통부장관의 서면통보가 확약인지 사전결정인지 검토하십시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 확약 1. 의의 및 근거 2. 법적성질 3. 요건 및 효과 4. 실효 III. 사전결정 IV. 사안 검토(사전결정여부)

I. 쟁점의 정리

확약에 대해 검토하고, 사안의 사업인정 요건 중 일부에 대한 국토교통부장관의 요건 해당 서면 통보가 사전결정인지 검토한다.

II. 확약

1. 의의 및 근거(「행정절차법」 제40조의2)

① 행정청이 사안에 대해 장래에 일정한 행정작용을 하거나 하지 않을 것을 내용으로 하는 의사표시를 말한다. ② 행정절차법 제40조의2 제1항에서는 법령등에서 당사자가 신청할 수 있는 처분을 규정하고 있는 경우 행정청은 당사자의 신청에 따라 장래에 어떤 처분을 하거나 하지 아니할 것을 내용으로 하는 의사표시(이하 "확약"이라 한다)를 할 수

있다고 규정하고 있다. 즉, 확약은 본 행정처분권한에 포함되어 있으므로 별도의 명문의 규정이 없는 경우에도 허용될 수 있다.

2. 법적성질

확약이 그 자체로 행정행위인가에 대하여 ① 확약은 행정청에 대해 장래에 확약의 내용을 이행 하여야 할 법적의무를 발생시킨다고 보아 확약의 처분성을 긍정하는 <긍정설>과 ② 사정변경에 의해 변경될 수 있어 종국적 규율성이 없다는 점에서 처분성을 부정하는 <부정설>이 대립한다. ③ <판례>는 어업권 우선순위결정에 관한 사건에서 어업권 우선순위결정을 확약으로 보면서 이는 행정처분이 아니므로 공정력, 불가쟁력 등과 같은 효력이 인정되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다. ④ <생각건대>, 확약은 종국적인 행위는 아니지만 행정청은 확약을 준수하여야 할 의무가 있으므로 확약의 처분성을 긍정하여 사전적 권리구제가 가능하게 하는 것이 타당하다.

3. 요건 및 효과

확약은 요건으로는 ① (주체) 본 행정처분을 할 수 있는 권한을 가진 행정청이 권한 범위 내에서 할 것, ② (형식) 문서로 할 것, ③ (내용) 법령 등에서 당사자가 신청할 수 있는 처분을 대상으로 그 내용은 법의 일반원칙에 부합하고, 실현가능한 내용일 것, ④ (절차) 일정한 절차가 필요한 경우 그 절차를 거칠 것이 있다. ④(효과) 확약을 발령한 행정기관은 자기구속의 의무를 지게 되어 확약 상대방에게 그 내용에 따른 행정행위를 해야 할 의무를 부담하며, 상대방에게는 행정기관에 대해 확약의 내용을 이행할 것을 청구할 수 있는 권리가 인정된다.

4. 실효

확약이 있는 후에 사실적·법률적 상태의 변경이 있는 경우 행정청의 별다른 의사표시가 없더라도 확약은 실효된다는 것이 통설·판례의 태도이다.

III. 사전결정

사전결정이란 종국적인 행정결정을 내리기 전에 사전적인 단계로서 여러 요건 중 하나 또는 일부에 대해 우선적으로 심사하여 내린 결정을 말한다. 사전결정은 그 자체로 하나의 완결된 행정행위라고 보는 것이 통설·판례의 태도이다.

IV. 사안 검토(사전결정여부)

국토교통부장관의 회신행위는 토지보상법 제4조의 미술관에 해당하는 공익사업임을 확인해준 것으로 사업인정결정 요건 중 일부를 사전에 결정한 사전결정에 해당한다. 또한 특별한 사정이 없는 한 해당결정은 후속되는 사업인정결정에 구속력을 미치게 된다.

<p.67~p.72 행정계획>기출24회 1-1 변형

06. p.67~68 법적성질

甲은 S시에 600㎡의 토지를 소유하고 있다. S시장 乙은 2001년 5월 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거하여 수립한 도시관리계획으로 甲의 토지가 포함된 일대에 대해 공원구역으로 지정하였다가 2006년 5월 민원에 따라 甲의 토지를 주거지역으로 변경지정하였다. 乙은 2010년 3월 정부의 녹색도시조성 정책에 부응하여 도시근린공원을 조성하고자 甲의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정하였다.

행정계획의 법적성질을 논하고, 사안의 녹지지역 재지정의 법적성질을 검토하시오. (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 행정계획의 개념

III. 행정계획의 법적성질

1. 학설
2. 판례
 - 1) 처분성 긍정(도시계획, 관리처분계획)
 - 2) 처분성 부정(도시기본계획, 환지계획)
3. 검토

IV. 사안의 해결(녹지지역 재지정의 처분성 긍정)

I. 쟁점의 정리

행정계획이 특정한 행위형식을 취하지 않는 경우 그 법적성질에 대해 권리구제 방법 등과 관련이 있어 문제 되는바, 사안의 녹지지역 재지정의 법적성질을 검토한다.

II. 행정계획의 개념

행정계획이란 행정주체가 일정한 행정활동을 위해 목표를 설정하고 그 목표를 달성하기 위해 행정수단을 선정하고 조정·종합화 하는 활동기준 또는 설정행위를 말한다. 행정계

획의 예로는 처분적 성질을 가지는 도시·군관리계획, 관리처분계획이 있고, 처분성이 없는 광역도시계획, 도시·군기본계획 등이 있다.

III. 행정계획의 법적성질

1. 학설

행정계획의 법적성질에 대하여 ① 행정계획은 일반적·추상적 규율로서 처분이 아니라 입법의 성질을 가진다고 보는 <입법행위설>, ② 특정인의 권리나 법률상 이익에 개별적이고 구체적인 변동을 초래하므로 행정행위의 성질을 가진다고 보는 <행정행위설>, ③ 행정계획은 그 종류가 다양하고 형태도 여러 가지이므로 개별적으로 검토하여야 한다고 보는 <개별검토설>, ④ 행정계획은 규범도 아니고 행정행위도 아닌 독자적인 성질을 가진다고 보는 <독자성설>이 있다.

2. 판례

헌법재판소는 '일반적으로 국민적 구속력을 갖는 행정계획은 행정행위에 해당되지만, 구속력을 갖지 않고 행정기관 내부의 행동지침에 지나지 않는 행정계획은 행정행위가 될 수 없다'고 하여 <개별검토설>의 입장을 취하며[전원재판부 2011헌마291, 2014. 3. 27.], 대법원도 개별적으로 행정계획의 성질 등을 고려하여 판단하는 입장이다. 구체적으로 도시(관리)계획, 관리처분계획은 처분성을 긍정, 도시기본계획, 환지계획 등은 처분성을 부정한다.

3. 검토

국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 행정계획은 처분성이 긍정되므로 신속한 국민의 권리구제를 위해 행정행위로 보아야 하고, 직접적으로 국민의 권리·의무에 변동을 초래하지 않는 행정계획의 경우는 처분성이 없다고 봄이 타당하다. 즉, 행정계획을 개별적으로 검토하는 <개별적 검토설>이 타당하다.

IV. 사안의 해결(녹지지역 재지정의 처분성 긍정)

사안의 녹지지역 재지정은 도시관리계획으로 그 결정고시로 건축이 제한되는 등 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는바, 강학상 행정행위이자 행정쟁송법상 처분에 해당한다.

<p.67~p.72 행정계획>기출24회 1-1 변형

07. p.69~70 계획재량의 통제

甲은 S시에 600㎡의 토지를 소유하고 있다. S시장 乙은 2001년 5월 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거하여 수립한 도시관리계획으로 甲의 토지가 포함된 일대에 대해 공원구역으로 지정하였다가 2006년 5월 민원에 따라 甲의 토지를 주거지역으로 변경지정하였다. 乙은 2010년 3월 정부의 녹색도시조성 정책에 부응하여 도시근린공원을 조성하고자 甲의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정하였다.

甲은 乙이 2010년 3월 그의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정한 것은 당해 토지 일대의 객관적 이용상황을 고려하지 아니한 결정이었다고 주장하였다. 계획재량에 대해 설명하고, 사안의 녹지지역 재지정에 형량하자가 있는지 검토하시오. (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 계획재량

1. 의의
2. 행정재량과의 구분
 - 1) 학설
 - 2) 판례
 - 3) 검토

III. 계획재량의 통제

1. 계획재량의 한계
2. 형량명령의 준수
3. 형량하자 검토

IV. 사안의 해결(형량하자 없음)

I. 쟁점의 정리

계획재량에 대해 설명하고, 광범위한 형성의 자유를 고려할 때 사안의 녹지지역 재지정에 형량하자가 있는지 검토한다.

II. 계획재량

1. 의의

계획재량이란 계획청이 행정계획을 수립함에 있어서 인정되는 광범위한 형성의 자유를 말한다. 통상 계획법률은 추상적인 목표와 절차만을 규정하고 있을 뿐 행정계획의 내용에 대하여는 별다른 규정을 두고 있지 않는데, 이러한 계획법률의 특성에 기인하여 계획청에게 재량이 인정된다.

2. 행정재량과의 구분

1) 학설

① 계획재량은 목적과 수단으로 구성되었으나 재량행위는 요건과 효과로 구성되어 양자는 규범구조가 서로 다르고, 계획재량에는 형량명령이라는 고유한 하자이론이 존재하여 질적 차이가 있다고 보는 <질적 차이 긍정설>과, ② 규범구조의 차이는 본질적인 것이 아니고 형량명령도 비례의 원칙의 내용에 해당하는 법원리라고 보아 질적 차이를 부정하고 양적 차이만을 인정하는 <질적 차이 부정설>이 대립한다.

2) 판례

종래에는 계획재량에 하자과 관련하여 재량권의 일탈·남용으로 사안을 해결하였는데, 최근에는 재량의 일탈·남용이라는 용어 대신 형량에 하자가 있다고 하여 계획재량의 고유한 하자론을 인정하여 계획재량의 독자성을 긍정하는 입장에 있다.

3) 검토

계획재량은 행정재량에 비해 비교적 광범위한 형성의 자유가 인정된다고 보는 것이 일반적이다. 그러나 이는 양적인 차이로 이해하여야 하며, 양자 모두 행정청의 선택의 자유를 인정하는 것이므로 본질적으로 차이가 있다고 보기는 어렵다.

III. 계획재량의 통제

1. 계획재량의 한계

① 행정계획은 근거 법령의 목적에 부합하는 것이어야 하며, ② 행정계획은 그 목적 달성에 필요한 수단이어야 한다. ③ 필요한 수단이라 하더라도 관련된 이익을 정당하게

형량하여야 한다(형량명령)는 한계가 있다.

2. 형량명령의 준수

형량명령이란 행정계획을 입안·결정함에 있어서 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다는 원칙을 말한다. 형량명령의 준수는 ① 조사단계(비교형량하여야 할 모든 관련이익을 조사), ② 평가단계(관련이익을 중요도에 따라 평가), ③ 비교·형량단계(협의의 비교형량)를 거쳐 행해진다.

3. 형량하자 검토

형량하자의 종류로는 ① 형량을 전혀 하지 않은 <형량의 해태>, ② 형량에 반드시 포함되어야 할 특정이익을 형량하지 않은 <형량의 흠결>, ③ 형량을 하기는 하였으나 객관성과 비례성을 결여한 <오형량>이 있다.

IV. 사안의 해결(형량하자 없음)

①사안의 녹지지역 재지정은 도시근린공원 조성이라는 목적에 부합하며 그 목적 달성에 필요한 수단이다. ②녹지지역 재지정은 개별 계획법률에 근거한 결정으로 조사, 평가, 비교형량단계를 거쳐 형량명령을 준수했을 것으로 유추되며, 형량의 해태, 형량의 흠결, 오형량이 있었다고 판단할 근거가 부족하므로 계획재량의 광범위한 형성의 자유를 고려할 때 형량하자가 있다고 보기 어렵다.

<p.67~p.72 행정계획>기출24회 1-1 변형

08. p.71~72 계획보장청구권

甲은 S시에 600㎡의 토지를 소유하고 있다. S시장 乙은 2001년 5월 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거하여 수립한 도시관리계획으로 甲의 토지가 포함된 일대에 대해 공원구역으로 지정하였다가 2006년 5월 민원에 따라 甲의 토지를 주거지역으로 변경지정하였다. 乙은 2010년 3월 정부의 녹색도시조성 정책에 부응하여 도시근린공원을 조성하고자 甲의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정하였다.

甲은 乙이 2010년3월 그의 토지에 한 녹지지역 지정을 해제할 것을 요구하고자 한다. 甲의 요구가 법적으로 관철될 수 있는지 논하시오. (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 계획보장청구권

1. 의의
2. 내용
 - 1) 계획존속청구권
 - 2) 계획이행청구권
 - 3) 경과조치청구권
 - 4) 손해전보청구권
3. 인정여부
4. 계획변경청구권

III. 사안의 해결(甲요구 관철 불가)

I. 쟁점의 정리

甲이 녹지지역 지정 해제를 요구할 수 있는지 계획변경청구권 인정여부를 검토한다.

II. 계획보장청구권

1. 의의
행정계획은 장래 여건의 변화 등으로 인해 변경 또는 폐지 될 수 있는데, 계획보장청구

권이란 그러한 경우에 행정계획은 존속을 청구하거나 변경으로 인한 손실의 보상을 청구할 수 있는 권리 등을 말한다.

2. 내용

1) 계획존속청구권

계획존속청구권이란 행정계획의 변경 또는 폐지에 대해 계획의 존속을 주장하는 권리이다. 행정계획은 유연성과 가변성이 있어 원칙적으로 인정될 수 없으나, 예외적으로 취소와 철회의 제한의 원칙에 의해 개인의 신뢰를 보호할 수 있는 경우에는 인정될 수 있다.

2) 계획이행청구권

계획이행청구권이란 확정된 계획을 행정주체로 하여금 이행하도록 요구하는 권리를 말한다. 계획존속청구권에서와 마찬가지로 원칙적으로 인정되지 않는다.

3) 경과조치청구권

경과조치청구권이란 행정계획의 변경 또는 폐지로 인하여 불이익을 받는 것을 방지하기 위해 행정청에 경과조치나 적응조치를 요구할 수 있는 권리를 말한다. 이는 명시적인 법률의 근거가 있는 경우에만 인정될 수 있다.

4) 손해전보청구권

손해전보청구권이란 행정계획의 변경 및 폐지로 인해 가해진 개인의 손해가 보호할 가치가 있는 신뢰인 경우에 손실보상이나 손해배상을 주장할 수 있는 청구권을 말한다.

3. 인정여부

행정계획은 유연성·가변성이라는 성질을 가지고 있고 행정계획의 근거 법률인 계획법률은 일차적으로 공익 보호를 목적으로 하고, 사익보호를 목적으로 하는 것이 아니므로 행정의 효율성 측면에서 계획보장청구권은 인정되기 어렵다. 다만, 예외적으로 법규상 조리상 청구권이 인정되는 경우가 있으며 이러한 경우에는 행정계획의 존속 등을 청구할 수 있다.

4. 계획변경청구권

① 계획변경청구권이란 기존 행정계획의 변경을 청구할 수 있는 권리를 말한다. ② 인정요건으로 행정주체에게 일정한 의무를 부과하는 강행법규가 존재하고 강행법규가 공익의 실현뿐 아니라 개인의 사익보호도 목적으로 하여야 한다. 또한 계획의 변경으로 공익보다 상대방의 신뢰보호이익이 커야한다. ③ 판례는 계획변경청구권을 원칙적으로 부정하지만 계획변경신청을 거부하는 것이 실질적으로 당해 처분 자체를 거부하는 결과가

되는 경우에는 예외적으로 인정(법규상·조리상 신청권 인정)한 바 있다.

Ⅲ. 사안의 해결(甲요구 관철 불가)

S시장 乙에게 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 녹지지역 지정을 해제하거나, 주거지역으로 변경해야 할 작위의무가 인정되지 않고, 위 법률은 특정 개인의 사익보호가 아닌 국토의 계획 및 이용이라는 공익을 위한 것이다. 따라서 甲의 요구는 법적으로 관철되기 어렵다.

<p.72 그 외 행정작용>보충

09. 공법상 계약, 행정조사, 공법상 사실행위, 행정지도의 개념에 대해 설명하시오.(5점)

은 행정지도의 상대방이 행정지도에 따르지 아니하였다는 것을 이유로 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

목차
I. 공법상 계약
II. 행정조사
III. 공법상 사실행위
IV. 행정지도

I. 공법상 계약

공법적 효과의 발생을 목적으로 행정주체를 한쪽 당사자로 하는 계약을 말한다. 분쟁 발생 시 공법상 당사자소송으로 권리구제 받을 수 있다.

II. 행정조사(행정조사기본법 제2조 제1호)

① 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 조사 대상자에게 보고요구·자료제출요구 및 출석·진술을 요구하는 활동을 말한다. ② 원칙은 사실행위로 행정쟁송의 대상이 아니나, 예외적으로 토지보상법 9조의 타인토지출입 등과 같이 사실행위와 수인의무가 결합하면 권력적 사실행위로 행정쟁송의 대상이 될 수 있다.

III. 공법상 사실행위

일정한 법적 효과의 발생을 목적으로 하는 것이 아니라, 사실상의 효과나 결과의 실현을 목적으로 하는 행정작용을 말한다. 예컨대, 교량의 건설이나 도로의 청소 등이 있다.

IV. 행정지도(행정절차법 제2조 제3호)

행정기관이 그 소관사무의 범위 안에서 행정목적을 실현하기 위해 특정인에게 지도·권고·조언 등을 하는 행정작용을 말한다. 행정절차법 48조 2항에 따라 행정기관

<p.73~p.76 인허가의제>

10.

건축법에서 인허가의제 제도를 둔 취지는, 인허가의제사항과 관련하여 건축허가의 관할 행정청으로 창구를 단일화하고 절차를 간소화하며 비용과 시간을 절감함으로써 국민의 권익을 보호하려는 것이지, 인허가의제사항 관련 법률에 따른 각각의 인허가 요건에 관한 일체의 심사를 배제하려는 것으로 보기는 어려우므로(중략)

인허가의제제도에 대해 설명하고, 집중효의 정도에 대해 논하시오. (10점)

목차
I. 의의 및 취지. 법적근거(행정기본법 제24조) II. 집중효의 정도 1. 절차의 집중 2. 실체의 집중 III. 인허가의제의 효과

I. 의의 및 취지. 법적근거(행정기본법 제24조)

인·허가의제 제도란 하나의 인·허가를 받으면 법률에서 정하는 바에 따라 그와 관련된 다른 인·허가를 받은 것으로 보는 것을 말한다. 무용한 행정절차의 반복을 피하고 절차를 간소화하여 신속하고 편리한 사무처리를 할 수 있도록 함에 그 취지가 있다. 행정기본법 제24조에 근거가 있으며, 행정계획의 방식을 통하지 않고 사업의 시행을 위한 인·허가 등을 의제하는 제도라는 점에서 일정한 절차를 거쳐 행정계획이 확정되면 다른 법규에서 규정된 승인 또는 허가 등을 받은 것으로 보는 효과인 집중효와 구별된다.

II. 집중효의 정도

1. 절차의 집중

주무행정청이 인·허가의제가 되는 주된 행정행위를 발령하는 경우 의제되는 행위에서 요구되는 절차적 요건에 얼마나 구속되는지의 문제로 ①주된 인허가 절차만 거치면 된다는 <절차집중설>, 이해관계인 권익보호와 같은 중요한 절차적 요건엔 구속된다는 <제한적 절차집중설>, 모든 절차적 요건에 구속된다는 <절차집중 부정설>이 있다. ②

판례는 행정청이 관계기관의 장과의 협의를 거쳐 사업계획승인을 한 이상 해당 법령에 따른 허가·인가·결정·승인 등이 있는 것으로 보아, 그 절차와 별도로 법령에서 정하는 절차를 거칠 필요는 없다고 하여 <절차집중설>의 입장을 취한다. ③의제되는 행위의 모든 절차적 요건에 구속되도록 하여 해당 절차를 모두 거치도록 하는 것은 절차의 간소화라는 인·허가의제 제도의 취지를 고려할 때 부당하다. 따라서 이해관계 있는 제3자의 권익보호의 존중을 위해 중요한 절차는 거쳐야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 타당하다.

2. 실체의 집중

주무행정청이 집중효의 대상이 되는 인·허가의 실체적 요건에 합치되는지 여부를 심사하여야 하는지와 관련하여 ①의제되는 인허가의 실체적 요건에 구속되지 않는다는 <실체집중설>, 이익형량 등 종합고려 한다는 <제한적 실체집중설>, 모두 충족되어야 주된 인허가를 할 수 있다는 <실체집중 부정설>이 있다. ②판례는 도시계획시설인 주차장에 대한 건축허가신청을 받은 행정청은 건축법상 허가 요건뿐 아니라 국토계획법상의 실시계획인가 요건도 충족하는지를 심사하여야 한다고 하여 <실체집중 부정설>의 입장을 취한 바 있다. ③절차의 간소화라는 인·허가 의제 제도의 취지를 고려하더라도 법치행정의 원칙상 의제되는 인·허가도 그 내용상 요건은 모두 충족되어야 하므로 판례와 같이 <실체집중 부정설>이 타당하다.

III. 인허가의제의 효과

행정기본법 제25조에서 인·허가 의제의 효과에 대해 주무행정청의 주된 행정행위에 대한 인·허가가 있게 되면 ① 협의가 된 사항에 관해서는 주된 인·허가를 받았을 때, 의제되는 인·허가를 받은 것으로 보고, ② 인·허가 의제의 효과는 주된 인·허가의 해당 법률에 규정된 관련 인·허가에 한정된다고 규정하고 있다. 또한, 인·허가 의제의 효력은 주된 사업을 시행하는 데 ③ 필요한 범위 내에서만 그 효력이 유지된다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 기본강의 5회

<p.79~p.80 거부처분의 사전통지 및 생략사유>기출22회 2-2 변형

01. 감정평가사 乙은 국토교통부장관에게 감정평가사 갱신등록을 신청하였으나 거부당하였다. 그런데 乙은 갱신등록거부처분에 앞서 거부사유와 법적 근거, 의견 제출의 가능성 등을 통지받지 못하였다. 사안의 거부처분은 사전통지 대상이 되는지 논하고, 절차상 하자가 존재하는지 검토하시오. (10점) (단, 당해 거부처분은 처분으로 보며 거부가 처분이 되기 위한 요건 검토는 생략할 것)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 사전통지의 의의 및 취지(행정절차법 제21조)
III. 거부처분의 사전통지 대상 여부
1. 학설
2. 판례
3. 검토
IV. 생략사유(행정절차법 제21조 제4항)
V. 사안의 해결(절차하자 존재)

I. 쟁점의 정리

행정절차법 제21조 제1항에서는 당사자에게 침익적 처분 시 사전통지를 하도록 규정하고 있다. 이에 수익적 행정처분의 신청을 거부하는 것이 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분인지가 문제 된다. 사전통지 대상이 된다면 생략사유에 해당하는지 검토하여 절차상 하자 여부를 검토한다.

II. 사전통지의 의의 및 취지(행정절차법 제21조)

사전통지란 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에 미리 처분의 제목, 당사자의 성명 또는 명칭과 주소, 처분의 원인이 되는 사실과 처

분의 내용 및 법적근거 등을 통지하는 것을 말한다. 행정절차법 제 21조에 근거가 있으며, 사전통지는 신중하고 공정한 행정을 도모하고, 상대방에게 쟁송제기 여부의 판단 등에 편의를 제공함에 그 취지가 인정된다.

III. 거부처분의 사전통지 대상 여부

1. 학설

① 수익적 행정처분의 신청만으로는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부여되지 않았으므로, 사전통지가 불필요 하다고 보는 <불요설>, ② 신청을 한 당사자는 긍정적인 처분을 기대하므로 그 거부는 권익을 제한하는 처분에 해당하여 사전통지가 필요하다고 보는 <필요설> 및 ③ 원칙적으로는 부정하나, 갱신허가의 거부 등 신청인의 권익이 보호될 필요가 있는 경우에는 사전통지를 하여야 한다고 보는 <절충설>이 있다.

2. 판례

판례는 신청에 따른 처분이 이루어지지 않은 경우에는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부과되어 있지 않으므로 그거부가 권익을 제한하는 처분에 해당하지 않고 이에 사전통지의 대상이 되지 않는다고 하여 <불요설>의 입장을 취한다.

3. 검토

행정절차법 제21조에서 사전통지의 적용 대상을 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우라고 규정하고 있으므로 원칙적으로 거부처분의 사전통지는 불필요하다고 볼 수 있다. 다만, 갱신허가의 거부의 경우 신청의 당사자는 침익적 처분과 마찬가지로 권익의 침해 또는 제한을 받게 되므로, 이러한 경우에는 사전통지를 하도록 하여 당사자의 권익을 보호할 필요가 있다.

IV. 생략사유(행정절차법 제21조 제4항)

① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우, ② 법령 등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우, ③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 처분의 사전통지를 하지 않을 수 있다.

V. 사안의 해결(절차하자 존재)

① 사안의 갱신등록거부처분은 乙에게 침익적 처분과 마찬가지로 권익의 침해·제한이 있는바, 사전통지 대상이 된다. ② 사안에서 공공을 위한 긴급성이나 일정한 사실이 법원에 의해 증명됐거나, 성질상 곤란하다는 등 사전통지를 생략할 사유가 없는바, 절차상 하자가 존재한다.

<p.81~p.82 청문 실시 사유와 생략 사유>기출33회 3변형

02. 감정평가법 45조 청문사유에 규정이 없으나 감정평가법 39조 명의대여로 인한 감정평가사 자격취소의 경우 청문을 실시하여야 하는지, 감정평가법 45조에 청문사유 규정이 없다는 이유로 청문을 생략할 경우 절차하자에 해당하는지 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 청문의 의의 및 취지(행정절차법 제22조)
III. 청문 사유(행정절차법 제22조)
IV. 청문의 생략사유(행정절차법 제22조 제4항)
V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

행정절차법 22조 1항 청문 사유를 중심으로 사안의 자격취소의 경우 청문 사유가 되는지 검토하고, 동조 4항을 중심으로 청문의 생략사유를 검토하여 감정평가법 45조 청문 사유 규정이 없다는 이유로 청문 생략 시 절차하자에 해당하는지 검토한다.

II. 청문의 의의 및 취지(행정절차법 제22조)

행정절차법 제22조에는 의견청취의 절차로서 청문, 공청회, 의견제출을 규정하고 있다. 청문은 행정청이 어떠한 처분을 하기 전에 당사자 등의 의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차를 의미한다. 당사자의 절차적 참여를 보장하고, 의견제출의 기회를 부여하여 국민의 방어권을 보호함에 그 취지가 인정된다.

III. 청문 사유(행정절차법 제22조)

① 다른 법령 등에 청문 규정이 있거나 ② 행정청이 필요하다 인정하거나 ③ '인허가 등의 취소, 신분·자격의 박탈, 법인·조합 등의 설립허가의 취소' 처분 시 청문을 한다.

IV. 청문의 생략사유(행정절차법 제22조 제4항)

① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우, ② 법령 등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우, ③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우, ④ 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에 의견청취를 생략할 수 있다.

V. 사안의 해결

① 감정평가법 39조 명의대여로 인한 감정평가사 자격취소의 경우 감정평가법 45조에는 청문 규정이 없으나 사안의 자격취소는 "신분·자격의 박탈"의 경우로 행정절차법 22조 1항에 따라 청문을 실시해야 하는 사유에 해당한다. ② 감정평가법 45조에 청문규정이 없다는 점은 공공의 안전 등을 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있거나 법원의 재판 등으로 일정한 사실이 증명된 경우 혹은 성질상 의견청취가 곤란한 경우 등의 사유에 해당하지 않는바, 당사자가 청문 포기의 뜻을 명백히 표시한 경우가 아닌 한 청문을 실시하여야 하며 생략 시 절차하자에 해당한다.

<p.83~p.84 이유제시>기출27회 1-1 변형

03.

「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함)의 적용을 받는 공익사업으로 인하여 甲은 사업시행자인 한국철도시설공단 乙에게 협의절차를 통해 자신이 거주하고 있던 주거용 건축물을 제공하여 생활의 근거를 상실하게 되었다고 주장하면서 토지보상법 제78조제1항에 따른 이주대책의 수립을 신청하였다. 이에 대해 乙은 "위 공익사업은 선형사업으로서 철도건설에 꼭 필요한 최소한의 토지만 보상하므로 사실상 이주택지공급이 불가능하고 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자의 가구수가 7호(戶)에 그치는 등 위 공익사업은 토지 보상법 시행령 제40조제2항에서 규정하고 있는 이주대책을 수립하여야 하는 사유에 해당되지 아니한다"는 이유를 들어 甲의 신청을 거부하였다.

乙이 甲에 대한 거부처분을 하기에 앞서 행정절차법상 이유제시를 하지 않은 경우 절차하자에 해당하는지 검토하시오. (10점) (단, 당해 거부처분은 처분으로 보며 거부가 처분이 되기 위한 요건 검토는 생략함)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 이유제시 의의 및 취지(행정절차법 제23조)
III. 이유제시 요건
IV. 생략사유
V. 사안의 해결(절차하자)

I. 쟁점의 정리

거부처분 시 이유제시 의무가 있는지, 예외사유에 해당하는지 검토한다.

II. 이유제시 의의 및 취지(행정절차법 제23조)

이유제시란 행정청이 처분을 할 때에 당사자에게 그 근거와 이유를 제시하는 것을 말한다. 행정절차법 제23조에 근거가 있으며, 신중하고 공정한 행정을 도모하고, 상대방의 쟁송제기에 편의를 제공함에 그 취지가 인정된다.

행정청은 수직적·침익적 처분을 분문하고 모든 행정처분을 할 때 이유제시를 하여야 한다.

III. 이유제시 요건

1. 정도, 방식, 시점

이유제시는 ① 당사자가 그 처분 사유를 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 하여야 하며, ② 처분 시 고려되었던 사실상·법률상 근거를 제시하여야 한다. ③ 행정절차법 제24조 제1항에 의거 이유제시는 원칙적으로 문서로 하여야 하며, ④ 처분 시 하여야 한다.

2. 요건의 완화

판례는 ① 당사자가 근거규정 등을 명시하여 신청하는 인·허가 등을 거부하는 처분에 함에 있어, 당사자가 그 근거를 알 수 있을 정도로 상당한 이유를 제시한 경우에는 구체적 조항 및 내용까지 명시하지 않더라도 그 처분이 위법한 것이 된다고 할 수 없다 하였고, ② 당사자가 어떠한 근거와 이유로 처분이 이루어진 것인지를 충분히 알 수 있어서 그에 불복하여 행정구제절차로 나아가는 데에 별다른 지장이 없었던 것으로 인정되는 경우도 이유제시의 정도가 완화된다고 보았다.

IV. 생략사유(「행정절차법」 제23조 제2항)

① 신청내용을 모두 그대로 인정하는 처분인 경우, ② 단순·반복적인 처분 또는 경미한 처분으로서 당사자가 그 이유를 명백히 알 수 있는 경우, ③ 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우에는 이유제시를 하지 않아도 된다. 다만, ②, ③의 경우 처분 후 당사자가 요청하는 경우에는 그 근거와 이유를 제시하여야 한다.

V. 사안의 해결(절차하자)

甲의 이주대책 수립 신청에 대해 乙이 거부처분을 할 때에는 이유제시를 하여야 하며 생략사유에 해당하지 않음에도 불구하고 이유제시를 생략한 乙의 거부처분에는 절차상 하자가 존재한다.

<p.85~p.86 절차하자>

04. 내용상 하자 없이 절차상 하자만 존재할 경우 그 독자적 위법성을 인정할 수 있는지 검토하고, 위법성 정도 및 기속력을 설명하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 학설
1. 적극설
2. 소극설
3. 절충설
III. 판례
IV. 검토(독자적 위법성 인정)
V. 위법성 정도 및 기속력

I. 쟁점의 정리

행정절차법에는 절차상 하자의 효과에 대한 규정을 두고 있지 않다. 따라서 절차상 하자 있는 행정행위의 위법성과 관련하여 그 행정행위가 실체법상 적법함에도 불구하고 절차상 하자만으로 취소할 수 있는지가 문제가 된다. 기속행위의 경우에는 적법한 절차를 거쳐 동일한 처분을 발령할 수 있으므로 특히 기속행위에서 절차상 하자의 독자적 위법성 인정 여부가 문제가 된다.

II. 학설

1. 적극설

적법절차의 원칙에 비추어 행정행위는 적정한 절차를 거쳐야 하고, 행정소송법 제30조 제3항에서 절차의 하자를 이유로 취소하는 경우에도 기속력을 인정하고 있다는 점 등에 비추어 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정한다.

2. 소극설

행정절차는 적정한 행정결정을 위한 수단에 불과하고, 절차상 하자를 이유로 취소하더라도 행정청을 그 적정한 절차를 거쳐 동일한 처분을 할 수 있으므로 행정능률과 소송경제상 부정한다.

3. 절충설

재량행위와 기속행위를 나누어 재량행위의 경우는 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하나, 기속행위의 경우는 내용상 하자가 없는 한 절차상 하자만으로 그 행정행위가 위법한 것은 아니라고 본다.

III. 판례

판례는 재량행위인 영업정지처분에서 청문절차를 거치지 않은 경우 위법하다고 하였을 뿐만 아니라, 기속행위인 과세처분에서 고지 절차에 하자가 있는 경우에 과세처분이 위법하여 취소대상이 된다고 하여 <적극설>의 입장을 취한다.

IV. 검토(독자적 위법성 인정)

행정작용은 법률적합의 원칙에 따라 그 내용(실체)뿐 아니라 절차도 적법하여야 한다. 또한, 행정소송법 제30조 제3항에서 취소소송 등의 기속력이 절차의 위법을 이유로 하는 경우에도 준용되므로 판례와 같이 적극설이 타당하다.

V. 위법성 정도 및 기속력

①통설·판례와 같이 절차상 하자의 독자적 위법성을 인정하는 입장에 절차상 하자가 있는 행정행위의 효력이 문제 된다. 행정행위의 무효와 취소를 구별하는 일반적 기준인 중대·명백성설에 따라 절차상 하자가 중대하고 명백하면 무효인 행정행위가 되고, 중대성과 명백성 중에 어느 하나를 결한 경우는 취소할 수 있는 행정행위가 되며, 판례도 동지의 입장이다. ②절차상 하자를 이유로 취소판결이 선고된 후 처분청이 절차상 하자를 보완하여 다시 동일한 처분을 하는 것이 판결의 기속력(「행정소송법」 제30조 제3항)에 반하는 것인지가 문제 된다. 이에 대해 통설·판례는 종전 처분과 동일한 처분을 하여도 이는 취소된 종전 처분과 별개의 처분에 해당하므로 판결의 기속력에 반하지 않는 적법한 처분이라고 본다.

<p.90 대집행 요건 중 공법상 의무의 불이행>기출22회3 변형

05. A시는 시가지 철도시설사업을 시행하기 위하여 토지보상법 제16조에 따라 주택용지를 협의취득하면서 그에 따른 일체의 보상금을 B에게 지급하였고, B는 해당 주택을 자진철거하겠다고 약정하였다. B가 자진철거를 하지 않을 경우 B의 주택에 대하여 대집행(행정대집행법상 요건만 검토할 것)을 할 수 있는지 판단하십시오. 단, 토지보상법 제16조에 따른 협의취득은 사법상 매매의 성질을 갖는다고 본다. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 대집행 의의 III. 대집행 요건 1. 공법상 의무의 불이행 2. 대체적 작위의무의 불이행 3. 다른 수단으로 그 이행을 확보하기가 곤란할 것 (보충성) 4. 불이행을 방지함이 심히 공익을 해할 것 IV. 사안의 해결(대집행 불가)

I. 쟁점의 정리

B의 자진철거 약정이 공법상 의무로 볼 수 있는지 행정대집행법 2조 요건을 중심으로 검토한다.

II. 대집행 의의 및 근거

대체적 작위의무(타인이 대신하여 이행할 수 있는 의무)의 불이행이 있는 경우 행정청이 그 의무를 스스로 행하거나 제3자로 하여금 이를 이행하게 하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 것을 말한다. 대집행의 일반법으로 행정 대집행법이 있으며 토지보상법 제89조에도 대집행에 대한 규정이 있다.

III. 대집행 요건

1. 공법상 의무의 불이행

대집행의 대상이 되는 의무는 공법상의 의무이다. 사법상의 의무는 법령에 특별한 규정이 없는 한 대집행의 대상이 되지 않는다. 대집행의 대상이 되는 공법상 의무는 법령에 의해 직접 명해지는 것도 있고(「토지보상법」 제43조), 법률에 의한 행정행위에 의해 명해질 수도 있다(철거명령, 위험물 제거명령).

2. 대체적 작위의무의 불이행

대집행의 대상이 되는 의무는 공법상 의무로서 대체적 작위의무이어야 한다. 대체적 작위의무란 누구나 이행이 가능 하여 타인이 대신 행할 수 있는 의무를 말한다.

3. 다른 수단으로 그 이행을 확보하기가 곤란할 것 (보충성)

행정지도 등 의무이행을 확보할 수 있는 다른 수단이 있는 경우에는 대집행이 허용되지 않는다. 여기에서 다른 수단이란 비례의 원칙이 적용되는 것으로 대집행 보다 경미한 수단을 의미한다.

4. 불이행을 방지함이 심히 공익을 해할 것

이는 비례의 원칙 중 협의의 비례의 원칙을 의미하는 것으로, 의무불이행의 정도가 경미한 경우에는 상대방의 권익보호를 위해 대집행을 할 수 없다.

IV. 관련 판례

토지 등의 협의취득은 공공사업에 필요한 토지 등을 그 소유자와의 협의에 의하여 취득하는 것으로서 공공기관이 사경 제주체로서 행하는 사법상 매매 내지 사법상 계약의 실질을 가지는 것이므로, 그 협의취득시 건물소유자가 매매대상 건물에 대한 철거의무를 부담하겠다는 취지의 약정을 하였다고 하더라도 이러한 철거의무는 공법상의 의무가 될 수 없고, 이 경우에도 행정대집행법을 준용하여 대집행을 허용하는 별도의 규정이 없는 한 위와 같은 철거의무는 행정대집행법에 의한 대집행의 대상이 되지 않는다.

V. 사안의 해결(대집행 불가)

사안의 경우 토지보상법 16조에 따른 협의취득은 사법상 매매로 B의 자진철거 약정은 사법상 계약이므로, 공법상 의무 불이행 요건을 충족하지 않는다. 따라서 B가 자진철거를 하지 않을 경우 B의 주택에 대해 대집행을 할 수 없다.

<p.91~p.95 대집행에 대한 권리구제>

06. 대집행 각 절차의 법적성질을 설명하고, 하자승계 가능성 및 대집행에 대한 권리구제 방법을 검토하시오. (10점)

목차
I. 대집행 II. 대집행 절차의 법적성질 1. 계고 2. 대집행 영장에 의한 통지 3. 대집행의 실행 4. 비용징수 III. 하자승계 가능성 IV. 대집행에 대한 권리구제 1. 행정쟁송 및 집행정지 2. 손해배상 및 결과제거청구

I. 대집행

대집행이란 대체적 작위의무(타인이 대신하여 이행할 수 있는 의무)의 불이행이 있는 경우 행정청이 그 의무를 스스로 행하거나 제3자로 하여금 이를 이행하게 하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 것을 말한다. 대집행은 계고 → 대집행영장에 의한 통지 → 대집행의 실행 → 대집행의 비용징수의 4단계 절차를 거치며, 각 단계는 하자의 승계가 인정된다.

II. 대집행 절차의 법적성질

1. 계고

계고는 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 한다는 뜻을 문서로써 알리는 행위를 말한다. 상당한 기간이란 사회통념상 의무 이행에 필요한 기간을 말하는데, 의무의 성질·내용 등을 고려하여야 하며, 계고는 문서에 의하여야 한다. 계고는 준법률행위적 행정행위로서 통지에 해당하며 항고소송의 대상이 된다.

2. 대집행 영장에 의한 통지

대집행영장에 의한 통지란 의무자가 계고를 받고도 지정된 기한까지 그 의무를 이행하지 않을 때, 당해 행정청이 대집행영장으로써 대집행을 할 시기, 대집행책임자의 성명 및 대집행비용의 개산액을 의무자에게 알리는 것을 말한다. 이는 준법률행위적 행정행위인 통지로서 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당한다.

3. 대집행의 실행

대집행의 실행이란 의무자가 지정된 기한까지 의무를 이행하지 않는 경우에 당해 행정청 스스로 또는 제3자로 하여금 그 의무를 이행시키는 물리력의 행사를 말한다. 이는 수인하명(건물철거행위를 참고 받아 들여야 하는 의무를 부과)과 사실행위(철거행위)가 결합된 합성행위의 성질을 가지는 권력적 사실행위로서 행정처분에 해당한다.

4. 비용징수

대집행에 소요된 비용은 원칙적으로 의무자가 부담한다. 따라서 대집행 이후 이에 소요된 비용을 의무자에게 명령 하여 징수하는 절차로서 비용납부명령은 하명이며 처분에 해당하여 항고소송의 대상이 된다. 의무자가 비용을 납부 하지 않는 경우에는 국세징수법에 따라 강제징수 할 수 있다.

III. 하자승계 가능성

건축법상 철거명령과 행정대집행법상 대집행의 절차상 행위는 별개의 법적효과를 목적으로 하므로 하자의 승계가 부정된다. 반면에 대집행 절차인 계고, 통지, 실행 및 비용징수는 하나의 법적효과를 목적으로 하여 각각 하자의 승계가 인정된다는 것이 통설·판례의 태도이다. 다만, 철거명령이 무효인 경우에는 이를 근거한 대집행의 절차상 행위도 무효이다.

IV. 대집행에 대한 권리구제

1. 행정쟁송 및 집행정지

대집행의 절차상 모든 행위는 처분성이 인정되므로, 행정심판 또는 행정소송의 제기가 가능하다. 다만, 대집행 실행이 완료된 경우에는 소의 이익이 없어 항고소송을 제기할 수 없으므로, 항고소송을 제기하면서 집행정지를 신청하여 대집행의 실행을 정지시킬 필요가 있다.

2. 손해배상 및 결과제거청구

위법한 대집행에 의하여 손해를 입은 자는 국가나 지방자치단체를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다. 또한 대집행 이후에 위법의 상태가 계속된다면 결과제거 청구를 주장할 수도 있다.

<p.96 토지보상법 인도이전의무의 대집행 가능성>

07.

토지보상법 제43조(토지 또는 물건의 인도 등) 토지소유자 및 관계인과 그 밖에 토지소유자나 관계인에 포함되지 아니하는 자로서 수용하거나 사용할 토지나 그 토지에 있는 물건에 관한 권리를 가진 자는 수용 또는 사용의 개시일까지 그 토지나 물건을 사업시행자에게 인도하거나 이전하여야 한다.

토지보상법의 인도·이전의무의 대집행 가능성에 대해 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 토지보상법 89조
III. 학설
IV. 판례
V. 검토

I. 쟁점의 정리

인도란 물건에 대한 점유를 이전시키는 것을 의미하므로, 점유자의 퇴거가 요구되고, 퇴거는 대체적 작위의무라 할 수 없으므로 대집행의 대상이 될 수 없다. 그런데 토지보상법 제89조에서는 대집행을 규정하고 있어, 해당 규정을 토지 또는 물건의 인도·이전에 대해 대집행을 인정하는 특별규정으로 보아야 하는지 견해가 대립한다.

II. 토지보상법 89조

①이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여야 할 자가 그 정하여진 기간 이내에 의무를 이행하지 아니하거나 완료하기 어려운 경우 또는 그로 하여금 그 의무를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는 사유가 있는 경우에는 사업

시행자는 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장에게 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다. 이 경우 신청을 받은 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ②사업시행자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 제1항에도 불구하고 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 직접 대집행을 할 수 있다. ③사업시행자가 제1항에 따라 대집행을 신청하거나 제2항에 따라 직접 대집행을 하려는 경우에는 국가나 지방자치단체는 의무를 이행하여야 할 자를 보호하기 위하여 노력하여야 한다.

III. 학설

① 대집행이 불가능하다고 보는 것은 토지보상법 제89조를 무의미 하게 하는 것이므로 해당 규정을 합리적·합목적적으로 해석하여 대집행이 가능하다고 보는 <긍정설>과 ② 인도·이전은 실력으로 점유를 배제시키는 직접강제에 해당한다고 보아 대집행을 부정하는 <부정설>이 대립한다.

IV. 판례

인도의무는 그것을 강제적으로 실현하면서 직접적인 실력행사가 필요한 것이지 대체적 작위의무라고 볼 수 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 대집행의 대상이 될 수 있는 것은 아니라고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

V. 검토

「토지보상법」 제89조 제1항에서는 ‘~「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다’고 규정 하고 있다. 이에 해당 규정을 행정대집행법의 특례 규정으로 보기 어렵고, 인도 의무는 직접적인 실력행사가 필요하므로, 특별한 사정이 없는 한 대집행의 대상이 될 수 없다고 보는 <부정설>이 타당하다.

<p.97~p.98 과징금 일부취소 가능성>

08. 과징금의 법적성질에 대해 설명하고 위법한 과징금 부과 처분의 일부취소 가능성에 대해 검토하시오. (10점)

목차
I. 의의 및 근거 II. 종류 1. 본래적 과징금 2. 변형된 과징금 III. 법적성질(처분, 재량행위) IV. 위법한 과징금 부과 처분(일부취소 불가)

I. 의의 및 근거

과징금이란 행정법규의 위반이나 법령 등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 그 위반행위로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우 그러한 경제적 이익의 박탈을 위하여 부과·징수하는 금전을 말한다. 행정기본법 제28조에 근거가 있으며, 감정평가법 제41조 내지 제44조 등 개별법에서 그 근거를 두고 있다.

II. 종류

1. 본래적 과징금

본래적 의미의 과징금은 행정법상의 의무위반으로 인하여 얻은 경제적 이익을 박탈하는 금전적 제재를 말한다. 따라서 과징금 액수는 이득액의 규모 등과 상호 균형을 이룰 것이 요구된다는 것이 판례의 입장이다.

2. 변형된 과징금

변형된 과징금이란 영업정지 등에 갈음하여 과징금을 부과하는 것을 말한다. 즉, 의무위반행위가 사업의 인·허가 등을 철회하거나 정지시킬 사유에 해당하지만 그 사업을 철회·

정지시킬 경우 초래되는 공익 또는 사익의 침해를 이유로 정지 등의 처분 대신에 과징금을 부과하는 것을 말한다. 감정평가법 제41조의 과징금이 여기에 해당한다.

III. 법적성질(처분, 재량행위)

과징금부과행위는 행정행위로서 급부하명의 성격을 가지며 행정소송의 대상이 되는 처분이다. 또한 통상 영업정지처분을 할 것인지 과징금을 부과할 것인지는 행정청의 재량에 속하는 것으로 본다. 감정평가법 제41조 제1항에서도 ‘~부과할 수 있다’고 규정하여 문언상 재량행위로 볼 수 있다.

IV. 위법한 과징금 부과 처분(일부취소 불가)

과징금 부과처분은 행정청에 재량이 인정되는 재량행위이다. 따라서 위법한 과징금 부과처분을 한 경우 해당 과징금 부과 처분을 전부 취소하여야 하는지, 아니면 법상 한도를 초과한 부분만을 취소할 수 있는지가(일부취소) 문제 된다. 이에 대하여 법원은 재량행위인 과징금의 경우 초과한 과징금 부분만을 취소할 수는 없고 그 전부를 취소하여야 한다고 판시한 바 있다.

<p.98 이중벌과 가능성>기출 21회 3번 변형

09. 과징금과 벌금의 중복부과가 가능한지 검토하시오. (10점)

목차
I. 과징금
II. 벌금
III. 과징금과 벌금의 중복부과 가능성
1. 문제점
2. 학설
3. 판례
4. 검토

I. 과징금

①행정법규의 위반이나 법령등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 그 위반행위로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우 그러한 경제적 이익의 박탈을 위하여 부과·징수하는 금전을 말한다. (「행정기본법」 제28조 제1항) ②본래적 과징금은 경제적 이익 박탈의 목적이 있으나, 감정평가법 41조의 변형된 과징금은 업무정지에 갈음하는 과징금으로, 감정평가법인등이 업무정지처분을 받을 경우 공익과 관련성이 큰 감정평가에 지장이 있게 되므로, 시민의 불편 및 국민경제에 줄 공익침해 등을 방지하기 위한 목적이다.

II. 벌금

①행정형벌 중 하나로 행정형벌이란 행정법규를 위반한 경우 형법에 정해져 있는 벌을 과하는 것을 말한다. 사형·징역·금고·자격상실·자격정지·벌금 등이 있으며 형벌이므로 형법과 형사소송법이 적용된다. ②행정형벌은 과거 의무위반에 대한 제재로서, 처벌을 내용으로 하여 행정규범의 실효성 확보에 취지가 있다.

III. 과징금과 벌금의 중복부과 가능성

1. 문제점

헌법 제13조 제1항에서는 ‘~동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다’고 규정하고 있다. 따라서 동일한 위반행위에 대해 행정벌과 과징금을 병과하는 것이 이중처벌금지 원칙에 반하는 것이 아닌지가 문제 된다.

2. 학설

① 행정벌과 과징금은 그 성질과 목적에 차이가 있어 병과가 이중처벌금지 원칙에 반하는 것은 아니라고 보는 견해와 ② 동일한 위반행위에 대한 과징금 등이 다른 법적 형식을 취하고 있더라도 본질적으로 형사처벌에 해당하면 처벌로 보아 병과가 불가능하다고 보는 견해가 있다.

3. 판례(소극)

과징금은 그 취지와 기능, 부과 주체와 절차 등을 종합할 때 부당지원행위의 억지(抑止)라는 행정목적 실현하기 위한 입법자의 정책적 판단에 기하여 그 위반행위에 대하여 제재를 가하는 행정상의 제재금으로서의 기본적 성격에 부당이득환수적 요소도 부가되어 있는 것이라고 할 것이어서 그것이 헌법 제13조 제1항에서 금지하는 국가형벌권 행사로서의 처벌에 해당한다고 할 수 없으므로 구 독점규제및공정거래에관한법률에서 형사처벌과 아울러 과징금의 부과처분을 할 수 있도록 규정하고 있다 하더라도 이중처벌금지원칙이나 무죄추정원칙에 위반된다거나 사법권이나 재판청구권을 침해한다고 볼 수 없다.

4. 검토

과징금과 벌금은 목적과 성질이 다르므로 동일한 법규 위반에 대하여 중복부과할 수 있다고 봄이 타당하다.

<p.87~p.89 행정의 실효성 확보수단>

10. 행정의 실효성 확보수단에 대해 개념 중심으로 설명하시오. (10점)

목차
I. 개념
II. 행정강제
1. 개요
2. 행정상 강제집행
1)의의
2)대집행
3)이행강제금(집행벌)
4)직접강제
5)강제징수
3. 행정상 즉시강제
III. 행정벌
1. 개요
2. 행정형벌
3. 행정질서벌
IV. 새로운 수단
1. 과징금
2. 가산세
3. 명단의 공표
4. 공급거부
5. 관허사업제한

<p.101~p.102 행정조사>

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법)
제9조(사업 준비를 위한 출입의 허가 등) ① 사업시행자는 공익사업을 준비하기 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다.
제11조(토지점유자의 인용의무) 토지점유자는 정당한 사유 없이 사업시행자가 제10조에 따라 통지하고 출입·측량 또는 조사하는 행위를 방해하지 못한다.

11. 공익사업의 준비절차로 토지보상법은 사업시행자가 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량·조사를 할 수 있는 규정을 두고 있다. 이때 토지점유자는 수인의무가 있다. ①토지보상법 9조의 타인점유 토지에 출입하여 측량·조사 행위의 법적성질과 ②토지점유자가 조사를 거부하거나 방해할 경우 실력으로 강제 조사를 할 수 있는지 ③위 조사행위가 위법할 경우 이에 근거한 사업인정도 위법한지 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리(토지보상법9조와 행정조사) II. 행정조사의 법적성질 III. 행정조사 시 실력행사 가능성 1. 학설 2. 검토 IV. 위법한 조사와 사업인정의 효력 1. 학설 2. 판례 3. 검토 V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리(토지보상법9조와 행정조사)

토지보상법 9조의 타인토지출입은 공익사업의 준비를 목적으로 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량 또는 조사하는 행위로 행정조사이다. 행정조사의 법적성질과 실력행사가 능성 및 위법한 행정조사에 기한 행정행위의 효력에 대해 검토한다.

II. 행정조사의 법적성질

①행정조사는 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 조사대상자에게 보고요구·자료제출요구 및 출석·진술요구를 행하는 활동으로 「행정조사기본법」 제2조에서 정의하고 있다. ②행정조사는 비권력적 조사와 권력적 조사로 구별되고 그 형식은 사실행위의 형식을 취한다. 토지보상법 9조의 조사는 동법11조에 토지점유자의 수인의무를 규정하는 바, 수인하명과 결합된 사실행위인 행정상 <권력적 사실행위>로서 처분성이 인정된다.

III. 행정조사 시 실력행사 가능성

1. 학설

① 조사의 거부·방해가 있는 경우에 대한 제재 규정이 있는 것은 거부·방해 등이 위법하다는 것을 전제한 것이므로 비례의 원칙 내에서 실력행사가 가능하다고 보는 <긍정설>, ② 제재규정은 간접적인 실효성 확보 수단에 불과하므로 실력행사는 허용되지 않는다고 보는 <부정설> 및 ③ 원칙적으로는 허용되지 않으나 예외적으로 행정조사의 필요성이 긴급하고, 다른 수단이 없는 경우에 한하여 허용된다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

2. 검토

국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 것은 법치주의 관점에서 인정될 수 없으므로 명문의 근거가 없는 한 실력행사를 할 수 없다고 보는 <부정설>이 타당하다.

IV. 위법한 조사와 사업인정의 효력

1. 학설

① 적법절차의 원칙에 비취 위법한 행정조사에 기초한 행정행위는 위법하다고 보는 <적극설>, ② 법령에서 행정행위의 전제요건으로서 행정조사를 규정하고 있는 경우를 제외하고는 양자는 일용 별개의 제도이므로 조사의 위법이 행정행위를 위법하게 만들지는 않는다고 보는 <소극설>, ③ 행정조사와 행정결정이 하나의 과정을 구성하고 있는 경우로서 행정조사에 중대한 위법사유가 있다면 행정행위도 위법하다고 보는 <절충설>이 있다.

2. 판례

판례는 위법한 세무조사에 기한 과세처분은 위법하다고 하였으나, 행정조사의 하자가 경미한 경우에는 그에 기초한 행정행위가 위법하다고 까지는 할 수 없다고 판시한 바 있다.

3. 검토

적법절차의 원칙에 따라 행정결정은 적법하고 정당한 절차를 거쳐야 한다. 따라서 위법한 행정조사에 기초한 행정결정은 위법하다고 보는 <적극설>이 타당하다. 이는 행정조사가 단지 예비적인 작용으로서 행해지는 경우에도 마찬가지이다.

V. 사안의 해결

- ① 토지보상법9조의 타인토지출입 및 측량조사는 행정조사로 토지보상법11조의 수인의무를 수반하는 권력적 사실행위로 처분이다.
- ② 토지점유자가 조사를 거부하거나 방해할 경우 토지보상법상 실력행사의 명문규정이 없는바, 법치주의 관점에서 실력행사를 할 수 없다.
- ③ 적법절차의 원칙에 따라 토지보상법9조의 타인토지출입 및 측량조사가 위법할 경우 이에 근거한 사업인정도 위법하다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 기본강의 6회

<p.106~p.108 행정심판과 이의신청>

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법) 제83조(이의의 신청) ① 중앙토지수용위원회의 제34조에 따른 재결에 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다. 제86조(이의신청에 대한 재결의 효력) ① 제85조제1항에 따른 기간 이내에 소송이 제기되지 아니하거나 그 밖의 사유로 이의신청에 대한 재결이 확정된 때에는 「민사소송법」상의 확정판결이 있는 것으로 보며, 재결서 정본은 집행력 있는 판결의 정본과 동일한 효력을 가진다. 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 (약칭: 감정평가법) 제42조(이의신청) ① 제41조에 따른 과징금의 부과에 이의가 있는 자는 이를 통보 받은 날부터 30일 이내에 사유서를 갖추어 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다. ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청에 대하여 30일 이내에 결정을 하여야 한다(중략) ③ 제2항에 따른 결정에 이의가 있는 자는 「행정심판법」에 따라 행정심판을 청구할 수 있다.

01. 행정심판과 이의신청의 개념에 대해 설명하고, 토지보상법상 이의신청과 감정평가법상 이의신청이 특별법상 행정심판인지, 강학상 이의신청인지 각각 검토하시오. (10점)

목차

I. 쟁점의 정리(행정심판과 이의신청의 구별실익)

II. 행정심판과 이의신청 개념 및 근거

1. 행정심판(행정심판법)
2. 이의신청(행정기본법36조)

III. 행정심판과 이의신청의 구별기준

1. 학설
2. 판례
3. 검토

IV. 토지보상법상 이의신청과 감정평가법상 이의신청 검토

1. 토지보상법상 이의신청
2. 감정평가법상 이의신청

I. 쟁점의 정리(행정심판과 이의신청의 구별실익)

행정심판의 성격을 갖는 이의신청은 이의신청을 거친 후에 다시 「행정심판법」상 행정심판을 청구하는 것은 허용되지 않으나(「행정심판법」 제51조), 행정심판의 성격을 갖지 않는 이의신청은 이를 거친 후 다시 「행정심판법」상 행정심판을 청구할 수 있다(「행정기본법」 제36조 제3항). 이에 양자를 구별하는 실익이 있는바, 사안의 이의신청을 검토한다.

II. 행정심판과 이의신청 개념 및 근거

1. 행정심판(행정심판법)

행정심판이란 행정청의 위법 또는 부당한 처분 또는 부작위로 인해 권리나 이익을 침해당한 자가 행정심판위원회에 그 시정을 구하고, 행정심판위원회가 재결을 행하는 절차를 말한다. 행정심판에 대한 일반법으로는 「행정심판법」이 있고, 개별법률에서 행정심판에 대한 특별 규정을 두기도 한다.

2. 이의신청(행정기본법36조)

이의신청은 행정청의 위법·부당한 처분으로 인해 권리나 이익이 침해된 자가 통상 처분에 제기하는 처분에 대한 불복절차를 말한다. 이의신청에 대한 일반법으로 「행정기본법」 제36조가 있고, 그 밖의 개별법령에서 이의신청에 관해 규정하고 있는 경우도 있다. 「행정기본법」 제36조에서는 「행정심판법」상 처분을 이의신청의 대상으로 한다고 규정하고 있으며, 개별법률에 다른 규정이 있는 경우는 처분 이외의 행정작용에 대한 이의신청도 인정될 수 있다.

III. 행정심판과 이의신청의 구별기준

1. 학설

① 심판기관을 기준으로 이의신청을 제기하는 기관이 처분청인 경우에는 단순 이의신청으로 보고, 처분청이 아닌 상급행정청이나 행정심판위원회에 제기하는 이의신청은 행정심판의 성격을 갖는 이의신청으로 보는 <심판기관기준설>과 ② 헌법 제107조 제3항에 의거 개별법률에서 준사법절차가 보장되는 것은 행정심판의 성격을 갖는 이의신청으로 보고, 그렇지 않은 경우는 단순 이의신청으로 보는 <불복절차기준설> 등이 있다.

2. 판례

판례는 단순 이의신청과 행정심판을 구별하는 기준으로 절차 및 담당기관에 차이가 있다는 점을 고려하여 판단한 바 있다.

3. 검토

헌법 제107조 제3항에서 행정심판은 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있는 점 등에 비춰 불복절차를 기준으로 양자를 구별하는 <불복절차기준설>이 타당하다.

IV. 토지보상법상 이의신청과 감정평가법상 이의신청 검토

1. 토지보상법상 이의신청

헌법107조③항에서 행정심판의 사법절차 준용을 규정하고 있다. 토지보상법 86조에서 이의신청에 대한 재결이 확정된 때에는 「민사소송법」상의 확정판결이 있는 것으로 보는 등 사법절차가 준용되고 있고, 상급기관인 중앙토지수용위원회에 불복하는 점, 동법 85조에서 이의신청 재결에 대해 행정소송을 제기할 수 있다는 점에서 <특별행정심판>으로 보는 것이 타당하다. 판례도 특별행정심판으로 본다. 따라서 토지보상법에 없는 규정은 행정심판법을 따르며 토지보상법상 이의신청을 거친 후 다시 행정심판법상 행정심판을 청구할 수 없다.

2. 감정평가법상 이의신청

감정평가법 42조 3항에서 동조 이의신청 결정에 이의가 있는 자는 행정심판법에 따라 행정심판을 청구할 수 있다고 규정한다. 이는 행정심판법 51조와의 균형을 고려할 때 감정평가법 42조 이의신청은 강학상 이의신청으로 봄이 타당하다.

<p.109~p.110 행정심판의 종류>

02. 감정평가사A는 감정평가법 17조에 따라 국토교통부장관에게 갱신등록신청을 하였으나 국토교통부장관은 갱신등록거부처분을 하였다. 감정평가사A는 갱신등록거부처분을 행정심판으로 다투려고 한다. 행정심판의 종류를 설명하고, 사안의 갱신등록거부처분을 다룰 수 있는 행정심판의 종류를 검토하시오. (10점)

목차
I.쟁점의 정리 II. 행정심판의 종류 1. 취소심판 (「행정심판법」 제5조 제1호) 2. 무효등확인심판 (「행정심판법」 제5조 제2호) 3. 의무이행심판 (「행정심판법」 제5조 제3호) III. 거부처분취소심판의 가능성 1. 학설 2. 판례 3. 검토 IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

행정심판법 5조에서 거부처분은 의무이행심판을 거치도록 규정한다. 사안의 갱신등록거부처분을 의무이행심판 외 거부처분취소심판의 청구가 인정될 수 있는지 검토한다.

II. 행정심판의 종류

1. 취소심판 (「행정심판법」 제5조 제1호)

취소심판은 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 행정심판을 말한다. 행정심판의 중심을 이루는 것으로, 「행정심판법」은 취소심판을 중심으로 구성되어 있다. 취소심판에서의 '변경'은 적극적 변경(영업취소처분을 영업정지처분으로 변경)을 의미한다.

2. 무효등확인심판 (「행정심판법」 제5조 제2호)

무효등확인심판은 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 행정심판을 말한다. 무효등에는 무효, 유효, 실효, 존재 및 부존재가 모두 포함된다. 무효등확인심판에는 무효확인심판, 유효확인심판, 실효확인심판, 존재확인심판 및 부존재확인심판이 있다.

3. 의무이행심판 (「행정심판법」 제5조 제3호)

의무이행심판이란 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 말한다. 거부나 부작위와 같은 행정청의 소극적 행위에 대한 실효적인 국민의 권리구제 수단이다.

III. 거부처분취소심판의 가능성

1. 학설

① 「행정심판법」 제5조 제3호를 근거로 거부처분은 의무이행심판의 대상이라고 보아 부정하는 견해가 있으나, ② 「행정심판법」 제2조 제1호의 처분에 거부도 포함되므로 거부처분취소심판도 가능하다고 보는 견해가 통설이다.

2. 판례

판례는 '당사자의 신청을 거부하는 처분을 취소하는 재결이 있는 경우'라고 하여 거부처분취소심판을 긍정하는 입장이다.

3. 검토

「행정심판법」 제49조 제2항에서 거부처분을 취소하는 재결을 하는 경우 처분청은 재결의 취지에 따라 다시 처분을 할 의무가 있다고 규정하고 있으므로, 당사자의 효율적 권리구제를 위해 통설·판례와 같이 거부처분취소심판을 인정하는 것이 타당하다.

IV. 사안의 해결

① 사안의 갱신등록거부처분은 행정심판법 5조 3호에 따라 의무이행심판으로 다룰 수 있고, ② 행정심판법 49조 2항에 따라 거부처분을 취소하는 재결을 하는 경우 처분청은 재결의 취지에 따라 다시 처분을 할 의무가 있는바, 거부처분취소심판으로 다룰 수 있다.

<p.111~p.112 행정심판의 청구기간>

개별토지가격결정은 그 처분의 고지방법에 있어 행정편의상 일단의 각 개별토지에 대한 가격결정을 일괄하여 읍면동의 게시판에 공고하는 것일 뿐 그 처분의 효력은 각각의 토지 또는 각각의 소유자에 대하여 각별로 효력을 발생하는 것이므로, **개별 토지가격결정의 공고로 그 효력은 발생하지만 처분의 상대방인 토지소유자 및 이해 관계인이 공고일에 개별토지가격결정처분이 있음을 알았다고 할 수는 없으므로** 개별토지가격결정을 알았다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 처분이 있는 날로부터 1년 이내에 취소소송(행정심판은 처분이 있는 날로부터 180일 이내)을 제기하면 된다. [대판 1993.12.24.92누17204참조]

03. D시의 개별공시지가는 2024년 1월1일 기준으로 하여 2024년4월30일 결정·공고되었다. 당해 개별공시지가결정에 불만이 있던 甲은 행정심판을 청구하려고 한다. 행정심판의 청구기간에 대해 설명하고, 사안의 개별공시지가결정의 행정심판청구기간에 대해 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 행정심판의 청구기간 1. 원칙 2. 예외
III. 사안의 해결 1. 처분이 있었던 날의 의미 2. 판례 3. 검토

I. 쟁점의 정리

개별공시지가결정·공고일을 처분이 있었던 날로 보아 행정심판청구기간을 기산할지 검토한다.

II. 행정심판의 청구기간

1. 원칙(행정심판법 27조)
행정심판의 청구기간은 원칙적으로 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 청구하여야 한다. 두 기간 중 어느 하나라도 먼저 경과하면 당해 행정심판청구는 부적법한 것이 되어 각하 결정된다. ①‘처분이 있음을 알게 된 날’은 처분이 있었음을 현실적으로 알게 된 날을 의미한다. ②‘처분이 있었던 날’이란 처분이 고지되어 효력이 발생한 날을 의미한다.

2. 예외

①청구인이 천재지변, 전쟁, 사변(事變), 그 밖의 불가항력으로 인하여 제1항에서 정한 기간에 심판청구를 할 수 없었을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다. ②행정심판법 제27조 제3항 단서에 따라 정당한 사유가 있는 경우에는 처분이 있었던 날부터 180일이 지난 이후에도 심판청구가 가능하다. 여기에서 정당한 사유란 사회통념에 의해 판단되어야 한다. ③오고지의 경우 잘못 알린 기간에 심판청구 할 수 있고, 불고지의 경우 처분이 있었던 날부터 180일 내에 청구할 수 있다. ④토지보상법 83조 이의신청은 재결서 정본을 받은 날부터 30일 내 할 수 있도록 규정된바, 행정심판법에 우선하여 적용된다.

III. 사안의 해결

1. 처분이 있었던 날의 의미
‘처분이 있었던 날’이란 처분이 고지되어 효력이 발생한 날을 의미한다. 상대방이 불특정 다수인이며, 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 일률적으로 처분의 효력이 적용되어야 한다.

2. 판례

개별토지가격결정의 공고로 그 효력은 발생하지만 처분의 상대방인 토지소유자 및 이해관계인이 공고일에 개별토지가격결정처분이 있음을 알았다고 할 수는 없으므로 처분이 있는 날로부터 180일 이내 심판청구하면 된다고 판시한다.

3. 검토

개별공시지가결정이 개별적으로 통지되지 않는 한 현실적으로 알았다고 보기 어려운바, 甲은 개별공시지가결정공고일인 2024년4월30일을 기준으로 180일 이내에 행정심판을 청구해야 할 것이다.

<p.115~p.118 재결의 효력-기속력>

04. 국토교통부장관은 감정평가사A에게 감정평가법 27조 자격증의 부당행사를 이유로 자격취소처분을 하였다. 이에 A는 행정심판을 청구하였고, 인용재결을 받았다. 그 후 A는 감정평가법 27조를 위반하여 자신의 자격증을 타인에게 대여하였고, 국토교통부장관은 감정평가법 39조에 따라 A에게 자격취소처분을 하였다. 행정심판 재결의 기속력의 범위에 대해 설명하고, 사안에서 국토교통부장관이 인용재결 이후 다시 A에게 자격취소처분을 한 것이 기속력에 반하는지 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 행정심판 재결의 기속력의 의의
III. 행정심판 재결의 기속력의 범위
1. 주관적 범위
2. 시간적 범위
3. 객관적 범위
IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

처분 이후 발생한 새로운 사유로 동일한 처분을 하는 경우 기속력에 반하는지 기속력의 시간적 범위를 검토한다.

II. 행정심판 재결의 기속력의 의의

심판청구를 인용하는 재결이 피청구인(처분청)과 그 밖의 관계 행정청이 재결의 취지에 따르도록 구속하는 효력을 재결의 기속력이라 한다. 「행정심판법」 제49조 제1항에서 재결의 기속력에 관한 명문 규정을 두고 있다. 재결의 기속력은 인용재결에서만 인정되며, 각하재결·기각재결에서는 인정되지 않는다.

III. 행정심판 재결의 기속력의 범위

1. 주관적 범위

기속력은 피청구인(처분청)과 그 밖의 모든 관계 행정청에 대하여 미친다. 여기에서 관계 행정청이란 심판의 대상이 되는 처분(거부 또는 부작위) 등과 관련된 처분이나 부수적 행위를 할 수 있는 행정청을 말한다.

2. 시간적 범위

처분의 위법성 판단기준시점에 대해 통설·판례는 처분시점의 입장을 취하는바, 처분시점에 따라 기속력은 처분시점까지의 사유를 판단의 대상으로 한다. 따라서, 기속력은 처분시에 존재했던 사유에만 미치고, 처분 이후의 새로운 법률관계나 사실관계에는 기속력이 미치지 않는다.

3. 객관적 범위

기속력은 재결의 주문 및 그 전제가 된 요건사실의 인정과 판단, 즉 처분 등의 구체적 위법사유에 관한 판단에만 미친다.

IV. 사안의 해결

A의 행정심판청구 이전 국토교통부장관은 A의 자격증 부당행사를 이유로 자격취소처분을 하였고, 인용재결 이후에 A의 자격증 대여라는 새로운 사실로 인해 다시 자격취소처분을 하였다. 인용재결의 기속력은 처음 자격취소처분 당시의 사유인 자격증 부당행사에만 미치며 처분 이후 발생한 새로운 사실관계 등에는 미치지 않는다. 따라서 국토교통부장관이 인용재결 이후 다시 A에게 자격취소처분을 한 것은 기속력에 반하지 않는다.

<p.115~p.118 재결의 효력-기속력>

05. 국토교통부장관은 감정평가사A에게 감정평가법 39조 2항 1호의 자격취소 처분을 하였고, A는 사전통지서에 기재된 의견제출 기한 내에 청문을 신청하였으나, 국토교통부장관은 감정평가법 45조에 청문규정이 없다는 이유로 청문을 실시하지 않았다. 이에 A는 행정심판을 청구하였고, 절차하자를 이유로 취소재결을 받았다. 행정심판 재결의 기속력의 내용에 대해 설명하고, 국토교통부장관은 A에게 어떠한 처분을 하여야 하는지 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 행정심판 재결의 기속력의 의의
III. 행정심판 재결의 기속력의 내용
1. 반복금지의무
2. 절차의 하자를 이유로 한 취소재결에 따른 재처분의무
3. 결과제거의무
IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

사안은 절차하자를 이유로 취소재결을 받은 경우로 기속력의 내용 중 재처분의무를 검토한다.

II. 행정심판 재결의 기속력의 의의

심판청구를 인용하는 재결이 피청구인(처분청)과 그 밖의 관계 행정청이 재결의 취지에 따르도록 구속하는 효력을 재결의 기속력이라 한다. 「행정심판법」 제49조 제1항에서 재결의 기속력에 관한 명문 규정을 두고 있다. 재결의 기속력은 인용재결에서만 인정되며, 각하재결·기각재결에서는 인정되지 않는다.

III. 행정심판 재결의 기속력의 내용

1. 반복금지의무

반복금지의무란 위원회가 청구인용재결을 하면 처분청(피청구인)과 관계 행정청은 동일한 사실관계 하에서 동일한 내용의 처분을 할 수 없도록 하는 의무를 말한다. 반복금지의무는 「행정심판법」 제49조 제1항의 해석에 의해 인정되며, 일종의 부작위의무로서 소극적 의무에 해당한다.

2. 절차의 하자를 이유로 한 취소재결에 따른 재처분의무

신청에 따른 처분이 절차의 위법 또는 부당을 이유로 재결로써 취소된 경우에는 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다. 이는 「행정심판법」 제49조 제4항에 근거한다.

3. 결과제거의무

재결의 기속력에는 원상회복의무가 포함되는 것으로 보는 것이 타당하며, 이는 「행정심판법」 제49조 제1항의 해석에 의해 인정된다. 즉, 취소재결 무효등확인재결이 확정되면 행정청은 해당 처분에 의해 야기된 위법상태를 제거할 의무를 부담하게 된다.

IV. 사안의 해결

사안의 경우 절차하자를 이유로 취소재결을 받은 경우로 국토교통부장관은 A에게 청문을 실시하여 하자 없는 징계처분을 하여야 할 것이다.

<p.115~p.118 재결의 효력-기속력>

06. 기속력의 실효성을 확보하기 위한 제도적 장치에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 개설 II. 직접처분(행정심판법 50조1항) 1. 의의 및 성질 2. 요건 3. 후속조치 III. 간접강제(행정심판법 50조의2) 1. 의의 2. 요건 3. 내용 4. 불복과 효력

I. 개설

심판청구를 인용하는 재결이 피청구인(처분청)과 그 밖의 관계 행정청이 재결의 취지에 따르도록 구속하는 효력을 재결의 기속력이라 한다. 기속력은 반복금지의무와 재처분의무를 내용으로 하는데, 반복금지의무를 위반하여 동일한 내용의 처분을 다시 한 경우 그 처분은 하자가 중대하고 명백하여 무효이고, 재처분의무를 위반한 경우에는 그 실효성을 확보하기 위해 직접처분(행정심판법 제50조)과 간접강제(행정심판법 제50조의2)가 규정되어 있다.

II. 직접처분(행정심판법 50조1항)

1. 의의 및 성질

직접처분이란 행정심판위원회가 이행명령재결을 하였음에도 불구하고 피청구인(처분청)이 재처분의무를 이행하지 않는 경우, 청구인의 신청에 의하여 위원회가 직접 처분을 하는 것을 말한다. 직접처분은 이행명령재결의 실효성 확보에 그 취지가 인정되며, 위원회가 하는 행정심판작용이자 행정처분으로서의 성질을 갖는다.

2. 요건

위원회가 직접처분을 하기 위한 요건으로는 ① 위원회의 이행명령재결에도 불구하고 피청구인(처분청)이 처분을 하지 아니할 것, ② 청구인의 신청이 있을 것, ③ 위원회가 시정기간을 정하여 서면으로 시정을 명할 것 및 ④ 시정명령기간이 경과할 것이 있다. 또한 소극적 요건으로 ⑤ 처분의 성질이나 그 밖의 불가피한 사유로 위원회가 직접 처분을 할 수 없는 경우에 해당하지 않아야 한다.

3. 후속조치

위원회는 직접처분을 하였을 때에는 그 사실을 해당 행정청에 통보하여야 하며, 통보를 받은 행정청은 위원회가한 처분을 자기가 한 처분으로 보아 관리·감독 등 필요한 조치를 하여야 한다(행정심판법 제50조 제2항).

III. 간접강제(행정심판법 50조의2)

1. 의의

간접강제란 행정심판의 인용재결(거부처분취소재결, 처분이행명령재결 등)에 따라 재처분의무가 있음에도 불구하고 피청구인(처분청)이 처분을 하지 않는 경우에 청구인의 신청에 의하여 위원회가 피청구인(처분청)에게 일정한 배상을 하도록 명하는 것을 말한다.

2. 요건

간접강제의 요건으로는 ① 피청구인이 「행정심판법」 제49조 제2항(4항에서 준용하는 경우 포함) 및 제3항에 따른 재처분을 하지 않을 것, ② 당사자의 신청이 있을 것, ③ 위원회가 결정으로 상당한 기한을 정하고, 피청구인이 그 기간 내에 이행하지 않을 것이 있다. 또한, ④ 위원회는 제1항에 따른 간접강제나 제2항에 따른 결정의 변경을 하는 경우에는 미리 신청 상대방의 의견을 들어야 한다.

3. 내용

간접강제 요건이 충족되면 위원회는 ① 지연기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명하거나, ② 즉시 배상을 할 것을 명할 수 있다.

4. 불복과 효력

청구인은 간접강제 결정에 불복하는 경우 행정소송을 제기 할 수 있다(행정심판법 제50조의2 제4항).

또한, 간접강제의 효력은 피청구인인 행정청이 소속된 국가·지방자치단체 또는 공공단체에 미치며, 결정서 정본은 행정소송제기와 관계없이 「민사집행법」에 따른 강제집행에 관하여는 집행권원과 같은 효력을 가진다(동조 제5항).

<p.119 재결의 불복>

07. 국토교통부장관은 감정평가사A에게 감정평가법 27조 자격증의 부당행사를 이유로 자격취소처분을 하였다. 이에 A는 행정심판을 청구하였고, 인용재결을 받았다. 국토교통부장관은 인용재결에 불복하여 행정쟁송을 할 수 있는지 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 재심판청구금지 및 행정소송
III. 피청구인의 행정소송 가능성 1. 학설 2. 판례 3. 검토
IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

행정심판에서 인용재결이 있는 경우 피청구인(행정청)이 이에 불복하여 행정소송을 제기할 수 있는지가 문제 된다.

II. 재심판청구금지 및 행정소송

「행정심판법」 제51조에 따라 심판청구에 대한 재결이 있으면 그 재결 및 같은 처분 또는 부작위에 대하여 다시 행정 심판을 청구할 수 없다. 따라서 재결에 불복하는 경우에는 행정소송을 제기하여야 한다.

III. 피청구인의 행정소송 가능성

1. 학설

① 「행정심판법」 제49조 제1항은 재결의 기속력을 규정하고 있으며, 이를 근거로 피청구인과 관계 행정청은 재결에 기속 되어 재결에 불복할 수 없다고 보는 <부정설>과

② 재결의 기속력에 의해 원칙적으로는 부정하나, 자치권은 지방자치단체의 주관적 공권이므로 재결로 인해 자치권이 침해된 경우에는 지방자치단체장이 행정소송을 제기할 수 있다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

2. 판례

판례는 인용재결이 있으면 처분청은 그러한 재결에 기속되므로 피청구인인 처분청은 이에 불복하여 취소소송을 제기할 수 없다고 판시하여 <부정설>의 입장을 취한다.

3. 검토

항고소송은 국민의 권리구제에 그 목적이 있으며, 「행정심판법」 제49조 제1항을 근거로 피청구인의 불복 가능성을 부정함이 타당하다. 또한, 피청구인의 불복을 긍정하면 국민의 권리구제가 어려워질 수 있으므로 판례와 같이 <부정설>이 타당하다 판단된다.

IV. 사안의 해결

행정심판법 51조 재심판청구금지에 따라 국토교통부장관은 인용재결에 불복하여 행정심판을 청구할 수 없고, 해당 인용재결을 다룰 수 있게 하면 기속력을 무력화시킬 수 있는바, 행정소송도 할 수 없다.

<p.120 행정심판법상 가구제>

08. 감정평가사A는 등록일부터 5년이 되는 날의 60일 전에 국토교통부장관에게 갱신등록 신청을 하였다. 그러나 국토교통부장관은 40일이 지나도록 갱신등록을 해주지 않았다. 갱신등록이 되지 않을 경우 감정평가사A는 업무를 수행할 수 없어 중대한 경영상 위기 등 중대한 불이익이 예상된다. A는 의무이행심판을 제기하면서 어떠한 구제수단을 신청할 수 있는지 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 집행정지(행정심판법 30조) 1. 집행부정지원칙과 집행정지 2. 집행정지 요건(행정심판법 30조) 3. 검토 III. 임시처분 (행정심판법 31조) 1. 의의 2. 요건 3. 검토 IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

A는 중대한 불이익이 예상되는 상황으로 행정심판법상 가구제 수단을 검토하고, 임시처분 가능성을 검토한다.

II. 집행정지(행정심판법 30조)

1. 집행부정지원칙과 집행정지

심판청구가 있더라도 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 않는 것을 집행부정지라고 한다. 「행정심판법」 제30조에 따라 집행부정지가 원칙이지만, 중대한 손해의 예방 등을 위해 일정한 요건을 갖추는 경우에는 집행정지를 인정하고 있다. 집행정지는 직권 또는 당사자의 신청에 의해 위원회가 결정한다.

2. 집행정지 요건(행정심판법 30조)

적극적 요건으로 ① 심판청구가 계속되고 있을 것, ② 집행정지 대상인 처분이 존재할 것, ③ 집행 부정지시 중대한 손해가 발생할 것 및 ④ 긴급한 필요성이 있다. 소극적 요건으로 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있을 때에는 허용되지 아니한다(제3항).

3. 검토

사안의 경우 국토교통부장관은 어떠한 처분도 하지 않고 부작위 상태가 지속되는 경우로 집행정지 대상인 처분이 존재하지 않는바, A가 집행정지 신청을 하더라도 받아들여지지 않을 것이다.

III. 임시처분 (행정심판법 31조)

1. 의의

임시처분이란 처분 또는 부작위가 위법·부당하다고 상당히 의심되는 경우 처분 또는 부작위로 당사자에게 중대한 불이익 등이 발생할 위험을 막기 위해 임시지위를 정할 필요가 있을 때 발하는 가구제이다. 「행정심판법」 제31조에 근거가 있으며, 임시처분은 직권 또는 당사자의 신청에 의해 위원회가 결정한다.

2. 요건

임시처분의 요건으로는 ① 심판청구가 계속되고 있을 것(통설은 의무이행심판만 인정), ② 처분 등이 위법 부당하다고 상당히 의심될 것, ③ 당사자가 받을 우려 있는 중대한 불이익이나 급박한 위험이 있을 것, ④ 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것, ⑤ 집행정지로 목적을 달성할 수 없을 것(보충성 요건)이 있다.

3. 검토

A는 의무이행심판을 제기하여 심판청구가 계속되고 있고, 국토교통부장관의 부작위가 위법 부당하다고 상당히 의심되며 A에게 중대한 경영상 위기 등 불이익이나 급박한 위험이 예상되고, 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없다. 특히 사안은 집행정지로 목적을 달성할 수 없는바, 임시처분이 가능할 것이다.

IV. 사안의 해결

A는 집행정지 요건은 충족하지 않으나 임시처분의 요건은 충족하는바, 의무이행심판을 제기하면서 임시처분을 신청할 수 있다.

<p.121 고지제도>

09. 국토교통부장관은 A감정평가법인에 과징금부과처분을 하면서 사전통지로 처분이 있음을 알게 된 날부터 180일 이내 행정심판 청구가 가능하다고 고지하였다. 행정심판법상 고지제도에 대해 설명하고, 사안의 행정심판 청구기간을 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 고지제도 의의 및 법적성질(행정심판법 58조) III. 고지제도의 종류 1. 직권에 의한 고지 (제1항) 2. 신청에 의한 고지 (제2항) IV. 고지의무 위반의 효과 1. 처분의 효력 2. 심판청구서의 제출 3. 심판청구기간 V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

행정심판법상 고지제도에 대해 설명하고, 오고지의 경우 행정심판 청구기간을 검토한다.

II. 고지제도 의의 및 법적성질(행정심판법 58조)

고지제이란 행정청이 처분을 할 때에 처분의 상대방에게 행정심판을 청구할 수 있는지와 청구 절차 및 청구기간을 알리 도록 하는 제도를 말한다. 고지제도는 국민이 불복여부를 결정하고 불복신청에 편의를 제공하도록 함에 그 취지가 인정되며, 「행정심판법」 제58조에 근거가 있다. 또한 「행정절차법」도 제26조에도 고지의무에 관한 규정이 있다. 고지는 불복청구에 필요한 사항을 통지하는 비권력적 사실행위로서, 그 자체로는 아무런 법적 효과를 발생시키지 않는다.

III. 고지제도의 종류

1. 직권에 의한 고지 (제1항)

행정청은 처분을 할 때에는 처분의 상대방에게 ① 해당 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지와 ② 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구 기간을 알려야 한다.

2. 신청에 의한 고지 (제2항)

행정청은 이해관계인이 요구하면 ① 해당 처분이 행정심판의 대상이 되는 처분인지와 ② 행정심판의 대상이 되는 경우 소관 위원회 및 심판청구 기간을 지체 없이 알려주어야 한다. 또한, 서면으로 알려 줄 것을 요구 받으면 서면으로 알려주어야 한다.

IV. 고지의무 위반의 효과

1. 처분의 효력

불고지나 오고지가 처분을 위법하게 만드는지와 관련하여 판례는 고지절차는 행정심판 절차를 밟는 데 편의를 제공하려는 것이어서 처분청이 위 규정에 따른 고지의무를 이행하지 않았다고 하더라도 경우에 따라 행정심판의 제기기간이 연장될 수 있음에 그칠 뿐, 그 때문에 심판의 대상이 되는 행정처분이 위법하다고 할 수는 없다고 판시한 바 있다. 즉, 고지의무 위반은 처분의 효력에 직접적인 영향을 미치지 않는다.

2. 심판청구서의 제출

행정청이 고지를 하지 않거나(불고지), 잘못 고지(오고지)하여 청구인이 심판청구서를 다른 행정기관에 제출한 경우 에는 그 행정기관은 그 심판청구서를 지체 없이 정당한 권한이 있는 피청구인에게 보내야 한다(행정심판법 제23조 제2항). 이 경우 심판청구서를 보낸 행정기관은 지체 없이 그 사실을 청구인에게 알려야 하고(제3항), 심판청구기간의 계산은 제1항에 따른 피청구인이나 위원회 또는 제2항에 따른 행정기관에 심판청구서가 제출되었을 때에 행정심 판이 청구된 것으로 본다(제4항).

3. 심판청구기간

행정청이 심판청구 기간을 「행정심판법」 제27조 제1항(처분이 있음을 알게 된 날부터 90일)에 규정된 기간보다 긴기간으로 잘못 알린 경우 그 잘못 알린 기간에 심판청구가 있으면 그 행정심판은 제1항에 규정된 기간에 청구된 것으로 본다(행정심판법 제27조 제5항). 또한, 행정청이 심판청구 기간을 알리지 아니한 경우에는 제3항에 규정된 기간(처분이 있었던 날부터 180일)에 심판청구를 할 수 있다(제6항).

V. 사안의 해결

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 기본강의 7회

<p.125 취소소송의 소송요건-거부처분>

cf. 소송요건만 검토하는 물음의 형태:

소송은 적법한가? 취소소송으로 다룰 수 있는가? 본안심리를 할 수 있는가?

01. 감정평가사 乙은 국토교통부장관에게 감정평가사 갱신등록을 신청하였으나 거부당하였다. 乙은 국토교통부장관의 거부를 취소소송으로 다룰 수 있는지 검토하시오. (10점)

감정평가법 제17조(등록 및 갱신등록) ① 제11조에 따른 감정평가사 자격이 있는 사람이 제10조에 따른 업무를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 실무수습 또는 교육연수를 마치고 국토교통부장관에게 등록하여야 한다. <개정 2021. 7. 20.>

② 제1항에 따라 등록한 감정평가사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록을 갱신하여야 한다. 이 경우 갱신기간은 3년 이상으로 한다.

③ 제1항에 따른 실무수습 또는 교육연수는 제33조에 따른 한국감정평가사협회가 국토교통부장관의 승인을 받아 실시·관리한다. <개정 2021. 7. 20.>

④ 제1항에 따른 실무수습·교육연수의 대상·방법·기간 등과 제1항에 따른 등록 및 제2항에 따른 갱신등록을 위하여 필요한 신청절차, 구비서류 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

목차

I. 쟁점의 정리

II. 거부가 처분이 되기 위한 요건

1. 공권력 행사의 거부
2. 신청인의 법률관계에 영향을 미칠 것
3. 법규상·조리상 신청권이 있을 것

III. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

대상적격(행정소송법19조), 원고적격(12조 전문), 협의 소익(12조 후문), 행정심판 임의전치(18조), 제소기간(20조), 관할법원(9조), 피고적격(13조)은 취소소송의 소송요건으로 사안에서 특히 대상적격이 문제되는데 거부가 처분이 되기 위한 요건 중심으로 검토한다.

II. 거부가 처분이 되기 위한 요건

1. 공권력 행사의 거부

거부가 처분이 되려면 신청의 내용(행위)이 공권력 행사 또는 그에 준하는 행정작용이어야 한다. 공권력 행사란 행정청이 행하는 구체적 사실에 대한 법집행 행위로서 우월한 지위에서 일방적으로 행하는 행정작용을 말한다.

2. 신청인의 법률관계에 영향을 미칠 것

거부가 처분이 되려면 그 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것이어야 한다. 판례는 신청인의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키는 것은 물론, 그렇지 않다 하더라도 신청인이 실체상의 권리자로서 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래하는 것도 포함한다고 본다.

3. 법규상·조리상 신청권이 있을 것

①신청권이 필요한지에 대해서는 견해가 대립하는데, 판례는 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정 처분에 해당하려면 국민에게 그 행위발동을 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다고 본다. ②신청권의 존부를 원고적격문제로 보는 견해와 대상적격으로 보는 견해, 본안판단으로 보는 견해가 있으나 신청인이 누구인가를 고려하지 않고, 단순한 응답받을 권리를 의미하므로, 판례와 같이 신청권의 존부를 거부처분의 요건으로 보는 <대상적격설>이 타당하다.

III. 사안의 해결

①사안의 갱신등록은 행정청의 우월적 지위에서 행하는 공권력 행사로 ②국토교통부장관의 갱신등록 거부로 乙은 감정평가 업무를 못하게 되는 등 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으킨다. ③감정평가법 17조 및 시행령 18조에서 감정평가사가 갱신등록을 신청할 수 있도록 규정하는바, 법규상·조리상 신청권이 존재한다. ④따라서 국토교통부장관의 거부는 처분이며 취소소송으로 다룰 수 있다.

<p.128 취소소송의 소송요건-변경처분>기출32회3-1변형

02. 감정평가사 甲은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가준칙을 위반하여 감정평가를 하였음을 이유로 업무정지처분을 받게 되었으나, 국토교통부장관은 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준공시지가 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래할 우려가 있음을 들어, 2021. 4. 1. 甲에게 업무정지처분을 갈음하여 3천만원의 과징금을 부과하였다. 甲은 부과된 과징금이 지나치게 과중하다는 이유로 국토교통부장관에게 이의신청을 하였고, 이에 대해서 국토교통부장관은 2021. 4. 30. 甲에 대하여 과징금을 2천만원으로 감액하는 결정을 하였다. 甲은 감액된 2천만원의 과징금도 과중하다고 생각하여 과징금부과처분의 취소를 구하는 소를 제기하고자 한다. 이 경우 甲이 취소를 구하여야 하는 대상은 무엇인지 검토하시오.(10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 과징금처분 및 이의신청 1. 과징금(급부하명) 2. 이의신청(강학상 이의신청) III. 감액처분 시 취소소송의 대상 1. 학설 2. 판례 3. 검토 IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

강학상 이의신청에 따른 처분으로 감액처분 시 취소소송 대상을 검토한다.

II. 과징금처분 및 이의신청

1. 과징금(급부하명)

과징금은 행정법상 의무위반 행위로 얻은 경제적 이익을 박탈하기 위한 금전상 제재금을 말하나, 사안은 업무정지에 갈음하는 변형된 과징금이다(감정평가법 41조). 급부하명의로 행정소송법 2조의 처분이다.

2. 이의신청(강학상 이의신청)

감정평가법 42조 3항에서 동조 이의신청 결정에 이의가 있는 자는 행정심판법에 따라 행정심판을 청구할 수 있다고 규정한다. 이는 행정심판법 51조와의 균형을 고려할 때 감정평가법 42조 이의신청은 강학상 이의신청으로 봄이 타당하다. 따라서 사안의 이의신청에 따른 국토교통부장관의 과징금 감액결정은 변경처분이다.

III. 감액처분 시 취소소송의 대상

1. 학설

① 변경처분과 원처분은 각각 독립된 처분이므로 양자 모두 소의 대상이라고 보는 <병존설>, ② 변경처분으로 원처분은 취소되어 변경처분으로 대체 되므로 변경처분이 소의 대상으로 보는 <흡수설>, ③ 변경처분은 원처분의 일부취소로 원처분은 변경된 원처분으로 존재하게 되어 이를 소의 대상으로 삼아야 한다고 보는 <역흡수설> 등이 있다.

2. 판례

행정청이 과세처분을 한 뒤에 이를 감액하는 경정처분을 한 경우에 그 경정처분은 감소된 부분에만 법적효과를 미치는 것이므로 이러한 경정처분은 독립한 과세처분이 아니고, 당초 부과처분(원처분)의 일부취소로서 납세자에게 유리한 효과를 가져오므로, 항고소송의 대상은 당초 부과처분 중 경정처분에 의해 취소되지 않고 남은 부분이라고 판시한 바 있다. 증액처분 시 증액처분만이 소의 대상이라고 판시한다.

3. 검토

당초 처분을 당사자에게 유리하게 변경하는 경우에는 변경되고 남은 원처분을 소의 대상으로 하는 것이 원처분의 연속성 측면에서 타당하고, 증액경정처분의 경우에는 국민의 재판청구권을 보장하기 위해 증액처분인 변경처분을 소의 대상으로 삼는 것이 타당하다.

IV. 사안의 해결

甲이 취소를 구하여야 할 대상은 감액되고 남은 2천만 원 과징금 부과처분이다.

<p.132 취소소송의 소송요건-변경재결>기출31회2-2변형

03. A시의 시장 甲은 2018.5.31. 乙소유 토지에 대해 2018.1.1. 기준 개별공시지가를 m^2 당 2,780,000원으로 결정·고시하였다. 乙은 2018.6.20. 이 사건 토지의 개별공시지가를 m^2 당 1,790,000원으로 수정해달라는 취지의 행정심판을 청구하였고, B행정심판위원회는 2018.8.27. 이 사건 토지의 개별공시지가를 m^2 당 2,000,000원으로 하는 변경재결을 하였다. 乙이 취소소송을 제기하려고 할 때, 소의 대상에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 일부인용재결과 변경재결 1. 학설 2. 판례 3. 검토 III. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

B행정심판위원회의 변경재결이 있는 경우 소의 대상을 검토한다.

II. 일부인용재결과 변경재결

1. 학설

① 일부취소(변경)재결은 원처분의 일부취소이므로 일부 취소되고 남은 원처분(변경된 원처분)이 소의 대상이 된다고 보는 견해, ② 일부취소(변경)재결은 원처분을 전부 취소하고 원처분을 대체하는 새로운 처분이므로 일부취소(변경)재결이 소의 대상이 된다고 보는 견해 및 ③ 일부취소재결과 변경재결을 구분 하여 일부취소재결은 양적 변경으로 남은 원처분이 소의 대상이 되고, 변경재결은 질적 변경으로 변경재결이 소의 대상이 된다고 보는 견해 등이 있다.

2. 판례

서울고등법원은 감봉 3월의 징계처분을 소청심사위원회가 감봉 1월로 감경한 사안에서 원처분을 피고로 감봉 1월의 처분에 대해 본안판단을 하였다. 이는 일부 취소되고 남은 원처분을 취소소송의 대상으로 인정한 것이며, 변경재결의 경우 대법원은 소청심사위원회가 감봉 1월의 징계처분을 견책으로 변경한 소청결정은 재결 자체에 고유한 위법을 주장하는 것으로 볼 수 없다고 하여 변경되고 남은 원처분을 대상으로 처분청을 피고로 하여 소송을 제기하여 한다고 판시한바 있다.

3. 검토

「행정소송법」 제19조에 의해 재결 자체에 고유한 위법이 없는 한 원처분을 소송의 대상으로 하여야 하는데, 일부인용재결의 내용상 하자는 재결의 고유한 위법이 아니다. 또한 일부취소재결과 변경재결을 구별하는 것은 일관성이 결여되어 타당하지 않고, 일부취소(변경)재결이 있으면 원처분 일부취소(변경)되고 남은 원처분으로 존재하므로 판례와 같이 이를 소의 대상으로 삼는 것이 타당하다.

III. 사안의 해결

乙의 경우 일부인용되고 남은 원처분(2,000,000원/ m^2)이 소송의 대상이 된다.

<p.130 취소소송의 소송요건-원처분주의>기출34회1-2번형

04. X공사는 토지보상법상 절차를 거쳐 공익사업을 진행하게 되었다. X공사는 사업구역 내 토지를 소유한 甲과 토지수용을 위한 협의가 성립되지 않아 관할 지방토지수용위원회에 토지수용의 재결을 신청하였다. 甲은 수용 자체가 위법이라고 주장하면서 관할 지방토지수용위원회의 수용재결과 중앙토지수요위원회의 이의재결을 거친 후 취소소송을 제기하였다. 취소소송의 대상적격에 관하여 설명하시오. (10점) (단, 수용재결은 사업시행자에게 부여된 수용권의 구체적 내용을 결정하고, 그 실행을 완성시키는 공용수용·사용의 종국적 절차로 행정소송법상 처분이다.)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 관련 행정작용의 법적성질
III. 원처분주의와 재결주의
1. 원처분주의와 재결주의
2. 재결의 고유한 위법이 있는 경우 구체적 검토
IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

이의재결이 특별법상 행정심판의 성질을 가지는바, 이를 거친 경우 취소소송의 대상이 무엇인지 원처분주의 논의를 통해 검토한다.

II. 관련 행정작용의 법적성질

①수용재결은 사업시행자에게 부여된 수용권의 구체적 내용을 결정하고, 그 실행을 완성시키는 공용수용·사용의 종국적 절차로 행정소송법상 처분이다. ②사법절차가 준용되고, 상급기관이 중앙토지수용위원회에 불복하는 점 등에 비추어 토지보상법상 이의재결은 특별행정심판청구에 대한 판단이다.

III. 원처분주의와 재결주의

1. 원처분주의와 재결주의

원처분주의란 원칙적으로는 원처분을 소의 대상으로 하고, 예외적으로 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 재결을 소의 대상으로 삼는 것을 말한다. 이에 반해 재결주의란 재결에 대해서만 취소소송을 제기할 수 있도록 하는 것을 말한다. 양자 중 어느 것을 취할지는 입법정책의 문제이며, 「행정소송법 19조」는 원처분주의를 취하고 있다. 「토지보상법」은 제85조 제1항에서 수용재결(원처분)과 이의재결(재결)을 모두 소의 대상으로 삼을 수 있다고 규정하여 원처분주의를 취한다.

2. 재결의 고유한 위법이 있는 경우 구체적 검토

①행정심판청구가 적법함에도 불구하고 본안심리를 하지 않고 각하재결을 한 경우, 이러한 각하재결은 원처분에 없는 고유한 하지가 있는 것이므로 재결취소소송의 대상이 된다. ②기각재결은 원처분이 정당하다고 인정하여 원처분을 유지하겠다는 내용의 재결이므로 원칙적으로는 재결 자체에 고유한 하자가 없어 재결취소소송을 제기할 수 없다. 그러나, 심판청구요건을 구비하지 않아 각하재결을 하여야 함에도 기각재결을 한 경우이거나 사정재결(행정심판법 제44조)을 하여야 함에도 기각재결을 한 경우 등은 재결이 소의 대상이 될 수 있다. ③행정심판청구인은 인용재결이 내려졌다면 목적을 달성한 것이므로 원칙적으로는 그 인용재결에 불복할 필요성이 없다. 다만, 제3자요 행정행위에서 제3자의 심판청구에 대해 인용재결이 내려진 경우라면 처분의 상대방은 그 인용재결을 다룰 필요가 있고, 이는 원처분에는 없는 재결 자체의 고유한 위법을 주장 하는 것으로 재결이 항고소송의 대상이 된다.

IV. 사안의 해결

이의재결을 거쳐 취소소송을 제기한 점에서, 이의재결은 기각재결로 보인다. 판례에 따르면 기각재결은 재결에 고유한 위법이 없으므로, 토지보상법 85조 1항에 의거 원처분인 수용재결이 취소소송의 대상이 된다. 만약, 이의재결에 고유한 위법이 있다면 이의재결은 취소소송 대상이 될 수 있다.

<p.134 취소소송의 소송요건-원고적격>기출25회2-1변형

05. 甲은 A시의 시외로 나가는 일반도로에 접한 자신 소유의 X토지에 교통로를 개설하고 대형음식점을 운용하고 있다. A시에서는 X토지와 이에 접하여 연결된 Y·W토지의 소유권을 취득하여 혼잡한 교통량을 분산할 목적으로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거하여 우회도로를 설치한다는 방침을 결정하고, A시의 시장은 X·Y·W토지의 개별공시지가 및 이 개별공시지가 산정의 기초가 된 P토지의 표준지공시지가와 도매물가상승률 등을 반영하여 산정한 보상기준가격을 내부적으로 결정하고 예산확보를 위해 중앙부처와 협의 중이다. 甲은 보상이 있을 것을 예상하여 더 많은 보상금을 받기 위해 부동산 가격공시에 관한 법률에 의거하여 감정평가사를 통해 산정된 P토지의 표준지공시지가에 불복하여 취소소송을 제기하려고 한다. 이 경우 甲에게 원고적격이 있는지를 검토하시오. (10점)

부동산 가격공시에 관한 법률 (약칭: 부동산공시법)

제8조(표준지공시지가의 적용) 제1호 각 목의 자가 제2호 각 목의 목적을 위하여 지가를 산정할 때에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 직접 산정하거나 감정평가법인등에 감정평가를 의뢰하여 산정할 수 있다. 다만, 필요하다고 인정할 때에는 산정된 지가를 제2호 각 목의 목적에 따라 가감(加減) 조정하여 적용할 수 있다. <개정 2020. 4. 7.>

(중략)

2. 지가 산정의 목적

가. 공공용지의 매수 및 토지의 수용·사용에 대한 보상

(이하 생략)

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법)

제70조(취득하는 토지의 보상) ① 협의나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다)과 그 밖에 그 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다. <개정 2016.

1. 19.>(이하 생략)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 행정소송법 12조 원고적격 의의

III. 법률상 이익의 의미

1. 학설
2. 판례
3. 검토

IV. 법률의 범위

V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

원고적격 관련하여 甲이 자신의 토지가 아닌 P토지의 표준지공시지가의 위법을 다룰 법률상 이익이 있는지 문제된다.

II. 행정소송법 12조 원고적격 의의

원고적격이란 행정소송에서 원고가 되어 본안판결을 받을 자격을 말한다. 「행정소송법」 제12조에서 원고적격과 관련하여 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

III. 법률상 이익의 의미

1. 학설

① 취소소송은 침해된 개인의 권리 회복을 목적으로 하므로, 권리가 침해된 자가 원고적격을 가진다고 보는 <권리구제설>, ② 항고소송의 기능을 법에 의하여 보호되는 이익을 구제하는 것으로 보아, 처분에 의해 권리가 침해된 자뿐만 아니라 법에 의해 보호되고 있는 이익을 가진 자도 원고적격이 있다고 보는 <법률상 이익구제설>, ③ 침해된 이익이 법률상 이익이든 사실상 이익이든 간에 실질적으로 재판상 보호할 가치 있는 이익이 침해된 자는 원고적격이 있다고 보는 <보호가치 있는 이익설> 및 ④ 취소소송의 기능을 개인의 권리구제보다 행정행위의 적법성 통제에 있다고 보아, 처분의 적법성 확보와 가장 밀접한 이익을 가진 자가 원고적격을 가진다고 보는 <적법성 보장설>이 있다.

2. 판례

판례는 법률상 보호되는 이익은 당해 처분의 근거법규 및 관련법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익이 있는 경우를 말한다고 하여 <법률상 이익구제설>의 입장을 취한다.

3. 검토

행정소송법은 취소소송을 주관적 소송으로 보아 개인의 권익구제를 주된 기능으로 규정하고 있으며, 동법 제12조의 원고적격의 해석상 <법률상 보호이익설>이 타당하다.

IV. 법률의 범위

법률상 보호되는 이익에서 '법률'의 범위가 문제 된다. 종래에는 당해 처분의 근거법규만을 고려 하였지만 오늘날에는 근거법규 뿐만아니라 관련법규까지 고려하며, 헌법상의 기본권도 법률상 이익으로 인정하는 듯한 판례도 있다. 근거법규와 관련법규를 기본으로 하여 보충적으로 헌법상 기본권도 고려하여야 한다고 보는 것이 일반적인 견해이다.

V. 사안의 해결

1. 토지보상법 70조 및 부동산공시법 8조

토지보상법 70조 1항에서 표준지공시지가를 기초로 한 공시지가기준법을 사용하여 보상액을 산정하도록 하고 있다. 부동산공시법 8조에서 토지의 수용·사용에 대한 보상 시 표준지공시지가를 기준으로 하도록 규정한다.

2. 사안의 해결

甲은 헌법 23조 3항에 따라 자신의 재산권에 대한 수용에 대하여 정당한 보상을 구할 수 있고 P토지의 공시지가는 X토지의 보상액 산정의 기초가 되는바, 관련규정을 종합하면 甲은 정당한 보상금을 받을 권리실현을 위한 법률상 이익이 인정된다. 즉, 취소소송을 구할 원고적격이 있다.

<p.136 취소소송의 소송요건-협의의 소익>기출27회4번형

06. 국토교통부장관은 감정평가업자 甲이「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 '감정평가법'이라 함) 제39조제1항제1호에 따른 감정평가기준을 위반하여 업무를 행하였다는 이유로 甲에게 1개월 업무정지처분을 하였다. 甲은 이러한 처분에 불복하여 취소소송을 제기하였으나 소송계속 중 1개월의 정지기간이 경과되었다. 감정평가법 시행령 제29조 [별표 3] '감정평가업자의 설립인가 취소와 업무정지의 기준'에 따르면, 위 위반행위의 경우 위반횟수에 따라 가중처분을 하도록 규정하고 있다(1차 위반 시 업무정지 1개월, 2차 위반 시 업무정지 3개월, 3차 위반 시 업무정지 6개월). 甲은 업무정지처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는가? (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 협의의 소익(행정소송법 제12조 후문)

1. 의의 및 회복되는 법률상 이익의 범위
2. 협의의 소익이 부정되는 경우
3. 협의의 소익이 긍정되는 경우

III. 감정평가법 시행령 29조 별표3의 법적성질

IV. 제재적 처분기준이 법령에 있는 경우 협의의 소익 논의

1. 학설
2. 판례
3. 검토

V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

법규명령형식의 행정규칙이 가중처분 규정을 두고 있는 경우, 그 전제가 되는 처분 종료 후에도 협의의 소익을 인정할 수 있는지 검토한다.

II. 협의의 소익(행정소송법 제12조 후문)

1. 의의 및 회복되는 법률상 이익의 범위

①협의를 소익이란 원고가 소송을 청구하여 본안판결을 구할 현실적 필요성을 말하며, 소권남용을 방지하여 법원의 부담을 경감하는데 그 취지가 인정된다. 「행정소송법」 제 12조 후단에서는 처분 등의 효력이 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자는 소송을 제기할 수 있도록 규정하고 있는데, 이를 협의의 소익의 근거로 보는 것이 일반적이다. ②회복되는 법률상 이익에 대해 견해가 나뉘나, 판례는 동조 전단의 법률상 이익과 동일하게 법률에 의해 보호되는 직접적이고 구체적인 이익으로 본다.

2. 협의의 소익이 부정되는 경우

①처분의 효력이 소멸한 경우 ②원상회복이 불가능한 경우 ③처분후의 사정에 의해 이익 침해가 해소된 경우 ④보다 실효적인 권리구제 수단이 있는 경우 소의 이익이 없는 것으로 본다.

3. 협의의 소익이 긍정되는 경우

①가중적 제재처분이 있는 경우 ②부수적 이익이 있는 경우 ③침해 해소가 완전하지 않은 경우 ④취소를 구할 현실적인 이익이 있는 경우 협의소익이 부정되는 경우에 해당되더라도 협의소익이 인정될 수 있다.

Ⅲ. 감정평가법 시행령 29조 별표3의 법적성질

법규명령형식의 행정규칙에 해당한다. 견해대립이 있으나 판례는 청소년보호법 시행령이 법규명령의 성질을 가진다고 판시하여 대통령령 형식일 경우 대외적 구속력을 긍정한다.

Ⅳ. 제재적 처분기준이 법령에 있는 경우 협의의 소익 논의

1. 학설

① 가중요건등이 법률이나 법규명령의 효력을 갖는 행정입법에 의해 규정되어 있다면 가중된 제재적 처분을 받을 불이익은 현실적이므로 협의의 소익이 인정되지만, 행정규칙으로 규정되어 있는 경우에는 불이익을 받을 현실적 위험이 불확실하여 협의의 소익을 부정하는 <법령설>과 ② 제재적 처분기준이 행정규칙의 형식으로 규정된 경우에도 행정청이나 담당공무원은 행정규칙에 따라 가중된 제재적 처분을 행할 것이므로 장래 불이익을 받을 위험이 있다고 보아 긍정하는 <규정설>등이 있다.

2. 판례

종래에는 제재적 처분기준이 법률 또는 법규명령인 경우에만 소의 이익을 긍정했다. 그러나 최근 대법원은 판례를 변경하여 제재적 처분기준에서 가중사유나 전제요건을 규정하고 있다면, 그 기준의 법적성질이 법규명령인지 행정규칙인지와 상관없이 행정청은 이를 준수할 의무가 있으므로 선행처분을 받은 상대방이 장래에 불이익한 후행처분을 받을 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로 협의의 소익을 긍정하는 입장이다.

3. 검토

가중요건이 규정된 제재적 처분기준이 행정규칙의 형식으로 규정되어 있더라도, 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있다. 따라서, 제재적 처분의 상대방은 그 처분의 효력이 소멸한 이후에도 당초 처분의 취소를 통해 장래 가중된 처분을 받을 불이익을 제거할 소의 이익이 인정되므로 <긍정설>이 타당하다. 이는 제재적 처분 기준이 법규명령형식의 행정규칙으로 규정되어 있는 경우도 마찬가지이다.

V. 사안의 해결

甲은 감정평가법 시행령 29조 별표3에 의해 장래에 가중처분을 받을 지위에 있는바 종전의 업무정지 기간이 경과하였음에도 불구하고 이를 취소할 법률상 이익이 인정될 것이다.

<p.138 취소소송의 소송요건-제소기간>

07. A시의 시장은 甲소유의 토지에 대해 2023.1.1.기준으로 한 개별공시지가를 2023.5.31.에 결정·고시하면서 별도로 개별통지하지 않았고, B시의 시장은 乙소유의 토지와 丙소유 토지에 대해 2023.1.1. 기준으로 한 개별공시지가를 2023.5.31.에 결정·고시하면서 乙과 丙에게 각각 개별통지 하였다. 한편, 丙은 당해 개별공시지가에 이의가 있어 2023.6.5. 이의신청을 하였고, 2023.7.1.이의 신청에 대한 결과를 통지받았다. 甲, 乙, 丙이 취소소송을 제기한다고 할 때 각각의 제소기간을 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 제소기간 1. 의의 2. 행정심판이나 이의신청을 거치지 않은 경우 3. 행정심판이나 이의신청을 거친 경우 III. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

개별공시지가 결정·고시의 제소기간을 개별통지를 받지 못한 경우와 받은 경우, 이의신청을 거친 경우로 나누어 검토한다.

II. 제소기간(행정소송법 제20조)

1. 의의

제소기간이란 소송을 제기할 수 있는 시간적 간격을 말한다. 제소기간은 행정의 안정성과 국민의 재판청구권의 조화를 고려해 입법 정책적으로 규정하며, 제소기간의 준수 여부는 법원의 직권조사사항이다.

2. 행정심판이나 이의신청을 거치지 않은 경우

①취소소송은 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하는데, '처분 등이 있음을 안 날'이란 통지, 공고, 기타의 방법에 의하여 당해 처분 등이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미한다. ②처분이 있음을 모르는 경우 처분 등이 있는 날로부터 1년 내에 취소소송을 제기하여야 한다. '처분이 있는 날'이란 행정처분이 상대방에게 도달되어 효력이 발생한 날이라는 것이 통설·판례의 입장이다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우 1년이 경과하더라도 소송을 제기할 수 있다. ③위 두 기간 중 어느 하나의 기간이라도 먼저 경과하면 취소소송을 제기할 수 없다.

3. 행정심판이나 이의신청을 거친 경우

①행정심판을 거쳐 취소소송을 제기하는 경우 취소소송은 재결서의 정본을 송달받은 날로부터 90일 내에 제기하여야 한다. 재결서 정본을 송달받지 못한 경우에는 재결이 있는 날부터 1년 내에 제기하여야 한다. ②처분에 이의가 있는 당사자는 처분을 받을 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의를 신청할 수 있고(행정기 본법 제36조 제1항), 이러한 이의신청을 거친 경우에는 행정기본법 제36조 제4항이 적용되어 이의신청에 대한 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

III. 사안의 해결

①<판례>에 의하면 개별토지가격결정의 처분의 효력은 공고일부터 발생하지만 처분의 상대방인 토지소유자 및 이해관계인이 공고일에 개별토지가격결정처분이 있음을 알았다 고까지 의제할 수는 없어 별도의 고지절차를 취하지 않는 이상 처분이 있는 날부터 180일 이내 행정심판청구를 하면 된다고 판시한바 있다. ②<甲>은 개별통지를 받지 않았으므로, 개별공시지가 결정고시일인 2023.5.31.로부터 1년 이내에 취소소송을 제기하면 된다. ③<乙>은 개별통지를 받았으므로 2023.5.31.이 처분 등이 있음을 안 날이 되고, 이 날로 90일 내에 취소소송을 제기하여야 한다. ④<丙>은 행정기본법 36조 4항에 따라 이의신청에 대한 결과를 통지받은 날인 2023.7.1.로부터 90일 이내 취소소송을 제기하면 된다.

<p.142 취소소송의 소송요건-피고적격과 행정심판 전치>기출34회1-2번형
08. X공사는 토지보상법상 절차를 거쳐 공익사업을 진행하게 되었다. X공사는 사업구역 내 토지를 소유한 甲과 토지수용을 위한 협의가 성립되지 않아 관할 지방토지수용위원회에 토지수용의 재결을 신청하였다. 甲은 수용 자체가 위법이라고 주장하면서 관할 지방토지수용위원회의 수용재결과 중앙토지수요위원회의 이의재결을 거친 후 취소소송을 제기하였다. 취소소송의 피고적격과 행정심판전치주의에 관해 설명하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 피고적격
1. 의의 및 근거
2. 판례
3. 사안의 경우
III. 행정심판 임의적 전치주의(행정소송법 18조 및 토지보상법 83조)
IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

토지보상법상 이의재결이 특별법상 행정심판의 성질을 가지는바, 이를 거친 경우 피고적격에 대해 설명하고, 행정심판전치주의에 대해 설명한다.

II. 피고적격(행정소송법 제13조)

1. 의의 및 근거

피고적격을 가진 자는 처분 등을 행한 행정청, 즉 처분청이 됨이 원칙이다(행정소송법 제13조). 처분청이라 함은 국가 또는 공공단체 등의 의사를 결정하여 외부적으로 표시할 수 있는 기관을 의미한다. 또한, 피고를 잘못 지정한 경우 피고경정을 통해 피고를 변경할 수 있다.

2. 판례

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제85조 제1항 전문의 문언 내용과 같은 법 제83조, 제85조가 중앙토지수용위원회에 대한 이의신청을 임의적 절차로 규정하고 있는 점, 행정소송법 제19조 단서가 행정심판에 대한 재결은 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한하여 취소소송의 대상으로 삼을 수 있도록 규정하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 경우에도 수용재결을 한 중앙토지수용위원회 또는 지방토지수용위원회를 피고로 하여 수용재결의 취소를 구하여야 하고, 다만 이의신청에 대한 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에는 그 이의재결을 한 중앙토지수용위원회를 피고로 하여 이의재결의 취소를 구할 수 있다고 보아야 한다.

3. 사안의 경우

취소소송의 대상인 수용재결을 행한 관할 지방토지수용위원회가 피고적격을 가진다. 만약, 이의재결에 고유한 위법이 있는 경우라면 중앙토지수용위원회가 피고적격을 가질 수 있다.

III. 행정심판 임의적 전치주의(행정소송법 18조 및 토지보상법 83조)

① 행정심판의 전치란 행정소송을 제기하기 전에 행정청에 먼저 행정심판을 청구하여 처분의 시정을 구하고, 그에 불복하는 경우에 비로소 소송을 제기하는 것을 말한다. 행정소송법은 행정심판 임의주의를 취하고 있다. 따라서 처분에 대해 행정심판을 거쳐서 취소소송을 제기할 수도 있고, 곧바로 취소소송을 제기할 수도 있다. 만일 개별법에서 행정심판 전치주의를 규정하고 있다면, 행정소송을 제기하기 전에 반드시 행정심판을 거친 후 행정소송을 제기할 수 있다. ② 토지보상법 83조 1항은 재결에 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다고 하여 임의적 절차로 규정한다.

IV. 사안의 해결

① 이의재결에 고유한 위법이 없는 한 수용재결을 행한 관할 지방토지수용위원회가 피고적격을 가진다. ② 토지보상법은 행정심판 임의적 전치주의를 취한다.

<p.142 가구제-집행정지>기출34회3 변형

09. A감정평가법인(이하 'A법인'이라 함)에 근무하는 B감정평가사(이하 'B'라 함)는 2020. 4.경 甲소유의 토지(이하 '甲토지'라 함)를 감정평가하면서 甲토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 부동산 가격공시에 관한 법률에 따른 표준지공시지가를 기준으로 감정평가를 하지도 않았고 적정한 실거래가보다 3배 이상 차이가 나는 금액으로 甲토지를 감정평가하였다. 그러나 그 사실은 3년여가 지난 후 발견되었고 이에 따라 국토교통부장관은 감정평가관리·징계위원회(이하 '위원회'라 함)에 징계요구를 요구하였으며 위원회는 3개월의 업무정지를 의결하였고, 국토교통부장관은 위원회의 의결에 따라 2023. 7. 10. B에 대해서 3개월의 업무정지처분(2023. 8. 1.부터)을 결정하였으며 A법인과 B에게 2023. 7. 10. 위 징계사실을 통보하였다. 이에 B는 위 징계가 위법하다는 이유로 2023. 7. 14. 취소소송을 제기하면서 집행정지를 신청하였다. 집행정지의 인용가능성을 검토하시오. (10점) (업무정지처분은 부작위하명으로 처분이다.)

<감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행령>

제29조(인가취소 등의 기준) 법 제32조제1항에 따른 감정평가업자의 설립인가 취소와 업무정지의 기준은 별표 3과 같다.

[별표 3] 감정평가업자의 설립인가 취소와 업무정지의 기준(제29조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간(제2호하목의 경우에는 최근 3년간을 말한다) 같은 위반행위(근거 법조문 내에서 위반행위가 구분되어 있는 경우에는 그 구분된 위반행위를 말한다)로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반횟수는 같은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후에 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 각각 기준으로 하여 계산한다.

<생략>

다. 국토교통부장관은 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등을 고려하여 처분기준의 2분의 1 범위에서 그 기간을 늘릴 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 총 업무정지기간은 2년을 넘을 수 없다.

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차이상 위반
라. 법 제3조제1항을 위반하여 감정평가를 한 경우	법 제32조 제1항제4호	업무정지1개월	업무정지3개월	업무정지6개월
마. 법 제3조제3항에 따른 원칙과 기준을 위반하여 감정평가를 한 경우	법 제32조 제1항제5호	업무정지1개월	업무정지2개월	업무정지4개월

목차

I. 쟁점의 정리

II. 집행부정지 원칙과 집행정지(예외)(행정소송법 23조)

III. 집행정지 요건

1. 적극적 요건(신청인에게 입증책임 있음)
 - 1) 적법한 본안소송의 계속
 - 2) 처분 등의 존재
 - 3) 회복하기 어려운 손해발생의 우려
 - 4) 긴급한 필요
2. 소극적 요건(행정청에게 입증책임 있음)
 - 1) 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없을 것
 - 2) 본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것

IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

행정소송법 23조 1항의 집행부정지원칙의 예외로서 집행정지 요건을 검토한다.

II. 집행부정지 원칙과 집행정지(예외)(행정소송법 23조)

행정소송법 제23조 제1항은 '취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다'고 하여 집행부정지를 원칙으로 규정하고 있다. 또한, 동조 제2항에서는 예외 규정으로 일정한 요건 하에서 처분의 효력등을 정지시키는 집행정지를 인정하고 있다. 소송의 과정은 장기간 소요되기도 하는데, 소송이 길어지면 승소 판결이 있다고 하더라도 당사자에게 회복되기 어려운 손해가 발생하는 등 실익이 없는 경우가 있을 수 있다. 따라서 예외적으로 집행정지를 인정하여 효과적인 권리보호를 실현하는데 그 취지가 인정된다.

III. 집행정지 요건

1. 적극적 요건(신청인에게 입증책임 있음)

1) 적법한 본안소송의 계속

민사소송법상의 가구제와는 다르게 행정소송법상 집행정지를 신청하기 위해서는 적법한 본안소송이 계속 중일 것을 요한다. 따라서 본안소송이 취하되면 집행정지결정의 효력도 소멸한다.

2) 처분 등의 존재

집행정지의 대상이 되는 처분 등이 존재하여야 한다. 따라서 부작위에 대해서는 집행정지가 허용되지 않고, 처분의 효력이 발생하기 전이나 처분의 효력이 소멸된 후에도 집행정지가 허용되지 않는다.

3) 회복하기 어려운 손해발생의 우려

처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어야 한다. '회복하기 어려운 손해'란 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 이는 금전보상이 불능인 경우 또는 금전보상으로는 사회관념상 당사자가 참고 견딜수 없거나 또는 참고 견디기가 현저히 곤란한 경우의 유형, 무형의 손해를 말한다. 특히, 기업의 경우 기업 이미지 및 신용의 훼손으로 인하여 사업 자체를 계속할 수 없거나 중대한 경영상의 위기를 맞게 될 것으로 보이는 등의 사정이 이에 해당될 수 있다.

4) 긴급한 필요

회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정되어야 한다. '긴급한 필요'란 본안판결을 기다릴 여유가 없는 것을 의미한다. 판례는 처분의 성질과 내용,

처분상대방이 입는 손해, 원상회복·금전배 상의 방법 및 난이 등은 물론 본안청구의 승소가능성의 정도 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다고 본다.

2. 소극적 요건(행정청에게 입증책임 있음)

1) 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없을 것

행정소송법 제23조 제3항에 의거 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 허용되지 않는다. 여기서의 '공공복리'는 그 처분의 집행과 관련된 구체적이고도 개별적인 공익을 말하는 것이라고 보는 것이 판례의 입장이며, 비례의 원칙에 의해 집행정지가 공공복리에 미치는 영향과 집행부정지를 통해 당사자가 입는 손해를 비교·형량하여 결정한다.

2) 본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것

행정소송법상 명문으로 규정된 요건은 아니지만 '본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것'이 집행정지의 소극적 요건인지에 대해 견해 대립이 있다. 이에 대해 처분의 취소 가능성이 없음에도 집행정지를 인정하는 것은 집행정지제도의 취지에 반하며, 집행정지신청의 남용을 방지할 필요도 있으므로 '본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것'을 집행정지의 소극적 요건으로 보는 것이 일반적 견해이다.

IV. 사안의 해결

①B는 023. 7. 14. 취소소송을 제기하였고, 별도로 취하되지 않은바, 적법한 본안소송이 계속 중이다. ②집행정지의 대상이 되는 업무정지처분이 존재하고, ③감정평가업무의 특성상 업무정지로 업무가 단절될 경우 거래처 상실 등 중대한 경영상 위기를 맞게 될 것으로 보이는바, 회복하기 어려운 손해발생이 예상된다. ④처분의 효력 발생일을 고려할 때 긴급한 필요가 있다고 보인다. ⑤소극적 요건으로 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 있다고 판단할 근거가 미약하고, 감정평가법 시행령 별표3의 행정처분기준을 고려 시 본안청구가 이유 없음이 명백하다고 판단하기 어렵다. ⑥집행정지 요건을 충족하는바, 사안의 집행정지는 인용 가능할 것이다.

<p.145 가구제-가처분>기출23회3 변형

10. 20년 이상 감정평가업에 종사하고 있는 감정평가사 甲은 2년 전에 국토교통부장관 乙의 인가를 받아 50명 이상의 종업원을 고용하는 감정평가법인을 설립하였다. 그 후 乙은 甲이 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 감정평가법인의 설립인가를 받았다는 이유로 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제32조 제1항 제13호에 따라 설립인가를 취소하였다. 甲은 乙의 인가취소가 잘못된 사실관계에 기초한 위법한 처분이라는 이유로 취소소송을 제기하면서 법인의 임시적 지위를 인정해주길 요청하고 있다. 가처분 가능성을 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 학설
III. 판례
IV. 검토 및 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

가처분이란 확정판결이 있을 때까지 발생할 수 있는 현저한 손해나 급박한 위험 등을 막기 위해 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하는 것을 목적으로 하는 가구제 수단을 말한다(「민사집행법」 제300조). 행정소송법에는 가처분에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않아 민사집행법의 가처분에 관한 규정을 준용할 수 있는지가 문제된다.

II. 학설

① 행정소송법이 가처분을 배제하는 규정을 두고 있지 않고, 행정소송법 제8조 제2에 의거 민사집행법상 가처분이 준용될 수 있다고 보는 <긍정설>, ② 권력분립의 원칙상 가처분을 인정하는 것은 사법권의 범위를 벗어나는 것이고, 현행법상 가처분의 본안소송인 의무이행소송을 인정하고 있지 않아 가처분을 부정하는 <부정설> 및 ③ 행정소송법이 집행정지제도를 두고 있는 관계상 집행정지를 통해 실질적인 권리구제가 되지 않

는 경우에만 가처분제도가 인정될 수 있다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

III. 판례

판례는 민사집행법 제300조 제2항이 규정한 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 그 성질상 주장 자체에 의하여 다툼이 있는 권리관계에 관한 정당한 이익이 있는 자가 가처분 신청을 할 수 있고, 그 경우 주장 자체에 의하여 신청인과 저촉되는 지위에 있는 자를 피신청인으로 하여야 한다며 민사집행법상의 가처분으로 행정청의 행정행위 금지를 구하는 것은 허용될 수 없다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

IV. 검토 및 사안의 해결

① 행정소송법에서 가구제 수단으로서 집행정지제도를 규정하고 있는데, 이는 민사집행법상의 가처분제도를 배제하는 특별 규정으로 볼 수 있다. 따라서 해석론상으로는 <부정설>이 타당하다. 다만, 국민의 권리보호 확대를 위해 입법론적으로는 가처분제도의 도입이 필요하며, 행정소송법 개정안에서도 가처분제도를 인정하고 있다. ② 사안의 경우 집행정지로 구제가 가능하고, 그 인용가능성도 있는바, 행정소송법에 규정이 없는 가처분을 인정하기 어렵다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 기본강의 8회

<p.134 취소소송의 소송요건-원고적격>기출25회2-1변형

01. 甲은 A시의 시외로 나가는 일반도로에 접한 자신 소유의 X토지에 교통로를 개설하고 대형음식점을 운영하고 있다. A시에서는 X토지와 이에 접하여 연결된 Y·W토지의 소유권을 취득하여 혼잡한 교통량을 분산할 목적으로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거하여 우회도로를 설치한다는 방침을 결정하고, A시의 시장은 X·Y·W토지의 개별공시지가 및 이 개별공시지가 산정의 기초가 된 P토지의 표준지공시지가와 도매물가상승률 등을 반영하여 산정한 보상기준가격을 내부적으로 결정하고 예산확보를 위해 중앙부처와 협의 중이다. 甲은 보상이 있을 것을 예상하여 더 많은 보상금을 받기 위해 부동산 가격공시에 관한 법률에 의거하여 감정평가사를 통해 산정된 P토지의 표준지공시지가에 불복하여 취소소송을 제기하려고 한다. 이 경우 甲에게 원고적격이 있는지를 검토하시오. (10점)

부동산 가격공시에 관한 법률 (약칭: 부동산공시법)

제8조(표준지공시지가의 적용) 제1호 각 목의 자가 제2호 각 목의 목적을 위하여 지가를 산정할 때에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 직접 산정하거나 감정평가법인등에 감정평가를 의뢰하여 산정할 수 있다. 다만, 필요하다고 인정할 때에는 산정된 지가를 제2호 각 목의 목적에 따라 가감(加減) 조정하여 적용할 수 있다. <개정 2020. 4. 7.>

(중략)

2. 지가 산정의 목적

가. 공공용지의 매수 및 토지의 수용·사용에 대한 보상

(이하 생략)

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 (약칭: 토지보상법)

제70조(취득하는 토지의 보상) ① 협의나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 비율을 말한다)과 그 밖에 그 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다. <개정 2016.

1. 19.>(이하 생략)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 행정소송법 12조 원고적격 의의

III. 법률상 이익의 의미

1. 학설
2. 판례
3. 검토

IV. 법률의 범위

V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

원고적격 관련하여 甲이 자신의 토지가 아닌 P토지의 표준지공시지가의 위법을 다룰 법률상 이익이 있는지 문제된다.

II. 행정소송법 12조 원고적격 의의

원고적격이란 행정소송에서 원고가 되어 본안판결을 받을 자격을 말한다. 「행정소송법」 제12조에서 원고적격과 관련하여 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

III. 법률상 이익의 의미

1. 학설

① 취소소송은 침해된 개인의 권리 회복을 목적으로 하므로, 권리가 침해된 자가 원고적격을 가진다고 보는 <권리구제설>, ② 항고소송의 기능을 법에 의하여 보호되는 이익을 구제하는 것으로 보아, 처분에 의해 권리가 침해된 자뿐만 아니라 법에 의해 보호되고 있는 이익을 가진 자도 원고적격이 있다고 보는 <법률상 이익구제설>, ③ 침해된 이익이 법률상 이익이든 사실상 이익이든 간에 실질적으로 재판상 보호할 가치 있는 이익이 침해된 자는 원고적격이 있다고 보는 <보호가치 있는 이익설> 및 ④ 취소소송의 기능을 개인의 권리구제보다 행정행위의 적법성 통제에 있다고 보아, 처분의 적법성 확보와 가장 밀접한 이익을 가진 자가 원고적격을 가진다고 보는 <적법성 보장설>이 있다.

2. 판례

판례는 법률상 보호되는 이익은 당해 처분의 근거법규 및 관련법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익이 있는 경우를 말한다고 하여 <법률상 이익구제설>의 입장을 취한다.

3. 검토

행정소송법은 취소소송을 주관적 소송으로 보아 개인의 권익구제를 주된 기능으로 규정하고 있으며, 동법 제12조의 원고적격의 해석상 <법률상 보호이익설>이 타당하다.

IV. 법률의 범위

법률상 보호되는 이익에서 '법률'의 범위가 문제 된다. 종래에는 당해 처분의 근거법규만을 고려 하였지만 오늘날에는 근거법규 뿐만아니라 관련법규까지 고려하며, 헌법상의 기본권도 법률상 이익으로 인정하는 듯한 판례도 있다. 근거법규와 관련법규를 기본으로 하여 보충적으로 헌법상 기본권도 고려하여야 한다고 보는 것이 일반적인 견해이다.

V. 사안의 해결

1. 토지보상법 70조 및 부동산공시법 8조

토지보상법 70조 1항에서 표준지공시지가를 기초로 한 공시지가기준법을 사용하여 보상액을 산정하도록 하고 있다. 부동산공시법 8조에서 토지의 수용·사용에 대한 보상 시 표준지공시지가를 기준으로 하도록 규정한다.

2. 사안의 해결

甲은 헌법 23조 3항에 따라 자신의 재산권에 대한 수용에 대하여 정당한 보상을 구할 수 있고 P토지의 공시지가는 X토지의 보상액 산정의 기초가 되는바, 관련규정을 종합하면 甲은 정당한 보상금을 받을 권리실현을 위한 법률상 이익이 인정된다. 즉, 취소소송을 구할 원고적격이 있다.

<p.136 취소소송의 소송요건-협의의 소익>기출27회4변형

02. 국토교통부장관은 감정평가업자 甲이「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 '감정평가법'이라 함) 제39조제1항제1호에 따른 감정평가기준을 위반하여 업무를 행하였다는 이유로 甲에게 1개월 업무정지처분을 하였다. 甲은 이러한 처분에 불복하여 취소소송을 제기하였으나 소송계속 중 1개월의 정지기간이 경과되었다. 감정평가법 시행령 제29조 [별표 3] '감정평가업자의 설립인가 취소와 업무정지의 기준'에 따르면, 위 위반행위의 경우 위반횟수에 따라 가중처분을 하도록 규정하고 있다(1차 위반 시 업무정지 1개월, 2차 위반 시 업무정지 3개월, 3차 위반 시 업무정지 6개월). 甲은 업무정지처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는가? (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 협의의 소익(행정소송법 제12조 제2문)

1. 의의 및 회복되는 법률상 이익의 범위
2. 협의의 소익이 부정되는 경우
3. 협의의 소익이 긍정되는 경우

III. 감정평가법 시행령 29조 별표3의 법적성질

IV. 제재적 처분기준이 법령에 있는 경우 협의의 소익 논의

1. 학설
2. 판례
3. 검토

V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

법규명령형식의 행정규칙이 가중처분 규정을 두고 있는 경우, 그 전제가 되는 처분 종료 후에도 협의의 소익을 인정할 수 있는지 검토한다.

II. 협의의 소익(행정소송법 제12조 제2문)

1. 의의 및 회복되는 법률상 이익의 범위

①협의의 소익이란 원고가 소송을 청구하여 본안판결을 구할 현실적 필요성을 말하며, 소권남용을 방지하여 법원의 부담을 경감하는데 그 취지가 인정된다. 「행정소송법」 제12조 제2문에서는 처분 등의 효력이 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자는 소송을 제기할 수 있도록 규정하고 있는데, 이를 협의의 소익의 근거로 보는 것이 일반적이다. ②회복되는 법률상 이익에 대해 견해가 나뉘나, 판례는 동조 전문의 법률상 이익과 동일하게 법률에 의해 보호되는 직접적이고 구체적인 이익으로 본다.

2. 협의의 소익이 부정되는 경우

①처분의 효력이 소멸한 경우 ②원상회복이 불가능한 경우 ③처분후의 사정에 의해 이익 침해가 해소된 경우 ④보다 실효적인 권리구제 수단이 있는 경우 소의 이익이 없는 것으로 본다.

3. 협의의 소익이 긍정되는 경우

①가중적 제재처분이 있는 경우 ②부수적 이익이 있는 경우 ③침해 해소가 완전하지 않은 경우 ④취소를 구할 현실적인 이익이 있는 경우 협의소익이 부정되는 경우에 해당되더라도 협의소익이 인정될 수 있다.

III. 감정평가법 시행령 29조 별표3의 법적성질

법규명령형식의 행정규칙에 해당한다. 견해대립이 있으나 판례는 청소년보호법 시행령이 법규명령의 성질을 가진다고 판시하여 대통령령 형식일 경우 대외적 구속력을 긍정한다.

IV. 제재적 처분기준이 법령에 있는 경우 협의의 소익 논의

1. 학설

①가중요건등이 법률이나 법규명령의 효력을 갖는 행정입법에 의해 규정되어 있다면 가중된 제재적 처분을 받을 불이익은 현실적이므로 협의의 소익이 인정되지만, 행정규칙으로 규정되어 있는 경우에는 불이익을 받을 현실적 위험이 불확실하여 협의의 소익을 부정하는 <부정설>과 ②제재적 처분기준이 행정규칙의 형식으로 규정된 경우에도 행정청이나 담당공무원은 행정규칙에 따라 가중된 제재적 처분을 행할 것이므로 장래

불이익을 받을 위험이 있다고 보아 긍정하는 <제한적 긍정설>등이 있다.

2. 판례

종래에는 제재적 처분기준이 법률 또는 법규명령인 경우에만 소의 이익을 긍정했다. 그러나 최근 대법원은 판례를 변경하여 제재적 처분기준에서 가중사유나 전제요건을 규정하고 있다면, 그 기준의 법적성질이 법규명령인지 행정규칙인지와 상관없이 행정청은 이를 준수할 의무가 있으므로 선행처분을 받은 상대방이 장래에 불이익한 후행처분을 받을 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로 협의의 소익을 긍정하는 입장이다.

3. 검토

가중요건이 규정된 제재적 처분기준이 행정규칙의 형식으로 규정되어 있더라도, 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있다. 따라서, 제재적 처분의 상대방은 그 처분의 효력이 소멸한 이후에도 당초 처분의 취소를 통해 장래 가중된 처분을 받을 불이익을 제거할 소의 이익이 인정되므로 <제한적 긍정설>이 타당하다. 이는 제재적 처분 기준이 법규명령형식의 행정규칙으로 규정되어 있는 경우도 마찬가지이다.

V. 사안의 해결

甲은 감정평가법 시행령 29조 별표3에 의해 장래에 가중처분을 받을 지위에 있는바 종전의 업무정지 기간이 경과하였음에도 불구하고 이를 취소할 법률상 이익이 인정될 것이다.

<p.138 취소소송의 소송요건-제소기간>

03. A시의 시장은 甲소유의 토지에 대해 2023.1.1.기준으로 한 개별공시지가를 2023.5.31.에 결정·고시하면서 별도로 개별통지하지 않았고, B시의 시장은 乙소유의 토지와 丙소유 토지에 대해 2023.1.1. 기준으로 한 개별공시지가를 2023.5.31.에 결정·고시하면서 乙과 丙에게 각각 개별통지 하였다. 한편, 丙은 당해 개별공시지가에 이의가 있어 2023.6.5. 이의신청을 하였고, 2023.7.1.이의 신청에 대한 결과를 통지받았다. 甲, 乙, 丙이 취소소송을 제기한다고 할 때 각각의 제소기간을 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 제소기간 1. 의의 2. 행정심판이나 이의신청을 거치지 않은 경우 3. 행정심판이나 이의신청을 거친 경우 III. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

개별공시지가 결정·고시의 제소기간을 개별통지를 받지 못한 경우와 받은 경우, 이의신청을 거친 경우로 나누어 검토한다.

II. 제소기간(행정소송법 제20조)

1. 의의

제소기간이란 소송을 제기할 수 있는 시간적 간격을 말한다. 제소기간은 행정의 안정성과 국민의 재판청구권의 조화를 고려해 입법 정책적으로 규정하며, 제소기간의 준수 여부는 법원의 직권조사사항이다.

2. 행정심판이나 이의신청을 거치지 않은 경우

①취소소송은 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하는데, '처분 등이 있음을 안 날'이란 통지, 공고, 기타의 방법에 의하여 당해 처분 등이 있었다는 사실을 현실적으로 안 날을 의미한다. ②처분이 있음을 모르는 경우 처분 등이 있는 날로부터 1년 내에 취소소송을 제기하여야 한다. '처분이 있는 날'이란 행정처분이 상대방에게 도달되어 효력이 발생한 날이라는 것이 통설·판례의 입장이다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우 1년이 경과하더라도 소송을 제기할 수 있다. ③위 두 기간 중 어느 하나의 기간이라도 먼저 경과하면 취소소송을 제기할 수 없다.

3. 행정심판이나 이의신청을 거친 경우

①행정심판을 거쳐 취소소송을 제기하는 경우 취소소송은 재결서의 정본을 송달받은 날로부터 90일 내에 제기하여야 한다. 재결서 정본을 송달받지 못한 경우에는 재결이 있는 날부터 1년 내에 제기하여야 한다. ②처분에 이의가 있는 당사자는 처분을 받을 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의를 신청할 수 있고(행정기 본법 제36조 제1항), 이러한 이의신청을 거친 경우에는 행정기본법 제36조 제4항이 적용되어 이의신청에 대한 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

III. 사안의 해결

①<판례>에 의하면 개별토지가격결정의 처분의 효력은 공고일부터 발생하지만 처분의 상대방인 토지소유자 및 이해관계인이 공고일에 개별토지가격결정처분이 있음을 알았다 고까지 의제할 수는 없어 별도의 고지절차를 취하지 않는 이상 처분이 있는 날부터 180일 이내 행정심판청구를 하면 된다고 판시한바 있다. ②<甲>은 개별통지를 받지 않았으므로, 개별공시지가 결정고시일인 2023.5.31.로부터 1년 이내에 취소소송을 제기하면 된다. ③<乙>은 개별통지를 받았으므로 2023.5.31.이 처분 등이 있음을 안 날이 되고, 이 날로 90일 내에 취소소송을 제기하여야 한다. ④<丙>은 행정기본법 36조 4항에 따라 이의신청에 대한 결과를 통지받은 날인 2023.7.1.로부터 90일 이내 취소소송을 제기하면 된다.

<p.142 취소소송의 소송요건-피고적격과 행정심판 전치>기출34회1-2번형
04. X공사는 토지보상법상 절차를 거쳐 공익사업을 진행하게 되었다. X공사는 사업구역 내 토지를 소유한 甲과 토지수용을 위한 협의가 성립되지 않아 관할 지방토지수용위원회에 토지수용의 재결을 신청하였다. 甲은 수용 자체가 위법이라고 주장하면서 관할 지방토지수용위원회의 수용재결과 중앙토지수요위원회의 이의재결을 거친 후 취소소송을 제기하였다. 취소소송의 피고적격과 행정심판전치주의에 관해 설명하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 피고적격
1. 의의 및 근거
2. 판례
3. 사안의 경우
III. 행정심판 임의적 전치주의(행정소송법 18조 및 토지보상법 83조)
IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

토지보상법상 이의재결이 특별법상 행정심판의 성질을 가지는바, 이를 거친 경우 피고적격에 대해 설명하고, 행정심판전치주의에 대해 설명한다.

II. 피고적격(행정소송법 제13조)

1. 의의 및 근거

피고적격을 가진 자는 처분 등을 행한 행정청, 즉 처분청이 됨이 원칙이다(행정소송법 제13조). 처분청이라 함은 국가 또는 공공단체 등의 의사를 결정하여 외부적으로 표시할 수 있는 기관을 의미한다. 또한, 피고를 잘못 지정한 경우 피고경정을 통해 피고를 변경할 수 있다.

2. 판례

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제85조 제1항 전문의 문언 내용과 같은 법 제83조, 제85조가 중앙토지수용위원회에 대한 이의신청을 임의적 절차로 규정하고 있는 점, 행정소송법 제19조 단서가 행정심판에 대한 재결은 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한하여 취소소송의 대상으로 삼을 수 있도록 규정하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 경우에도 수용재결을 한 중앙토지수용위원회 또는 지방토지수용위원회를 피고로 하여 수용재결의 취소를 구하여야 하고, 다만 이의신청에 대한 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에는 그 이의재결을 한 중앙토지수용위원회를 피고로 하여 이의재결의 취소를 구할 수 있다고 보아야 한다.

3. 사안의 경우

취소소송의 대상인 수용재결을 행한 관할 지방토지수용위원회가 피고적격을 가진다. 만약, 이의재결에 고유한 위법이 있는 경우라면 중앙토지수용위원회가 피고적격을 가질 수 있다.

III. 행정심판 임의적 전치주의(행정소송법 18조 및 토지보상법 83조)

① 행정심판의 전치란 행정소송을 제기하기 전에 행정청에 먼저 행정심판을 청구하여 처분의 시정을 구하고, 그에 불복하는 경우에 비로소 소송을 제기하는 것을 말한다. 행정소송법은 행정심판 임의주의를 취하고 있다. 따라서 처분에 대해 행정심판을 거쳐서 취소소송을 제기할 수도 있고, 곧바로 취소소송을 제기할 수도 있다. 만일 개별법에서 행정심판 전치주의를 규정하고 있다면, 행정소송을 제기하기 전에 반드시 행정심판을 거친 후 행정소송을 제기할 수 있다. ② 토지보상법 83조 1항은 재결에 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다고 하여 임의적 절차로 규정한다.

IV. 사안의 해결

① 이의재결에 고유한 위법이 없는 한 수용재결을 행한 관할 지방토지수용위원회가 피고적격을 가진다. ② 토지보상법은 행정심판 임의적 전치주의를 취한다.

<p.142 가구제-집행정지>기출34회3 변형

05. A감정평가법인(이하 'A법인'이라 함)에 근무하는 B감정평가사(이하 'B'라 함)는 2020. 4.경 甲소유의 토지(이하 '甲토지'라 함)를 감정평가하면서 甲토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 부동산 가격공시에 관한 법률에 따른 표준지공시지가를 기준으로 감정평가를 하지도 않았고 적정한 실거래가보다 3배 이상 차이가 나는 금액으로 甲토지를 감정평가하였다. 그러나 그 사실은 3년여가 지난 후 발견되었고 이에 따라 국토교통부장관은 감정평가관리징계위원회(이하 '위원회'라 함)에 징계요구를 요구하였으며 위원회는 3개월의 업무정지를 의결하였고, 국토교통부장관은 위원회의 의결에 따라 2023. 7. 10. B에 대해서 3개월의 업무정지처분(2023. 8. 1.부터)을 결정하였으며 A법인과 B에게 2023. 7. 10. 위 징계사실을 통보하였다. 이에 B는 위 징계가 위법하다는 이유로 2023. 7. 14. 취소소송을 제기하면서 집행정지를 신청하였다. 집행정지의 인용가능성을 검토하시오. (10점) (업무정지처분은 부작위하명으로 처분이다.)

<감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행령>

제29조(인가취소 등의 기준) 법 제32조제1항에 따른 감정평가업자의 설립인가 취소와 업무정지의 기준은 별표 3과 같다.

[별표 3] 감정평가업자의 설립인가 취소와 업무정지의 기준(제29조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간(제2호하목의 경우에는 최근 3년간을 말한다) 같은 위반행위(근거 법조문 내에서 위반행위가 구분되어 있는 경우에는 그 구분된 위반행위를 말한다)로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반횟수는 같은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후에 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 각각 기준으로 하여 계산한다.

<생략>

다. 국토교통부장관은 위반행위의 동기내용 및 위반의 정도 등을 고려하여 처분기준의 2분의 1 범위에서 그 기간을 늘릴 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 총 업무정지기간은 2년을 넘을 수 없다.

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차이상 위반
라. 법 제32조제1항을 위반하여 감정평가를 한 경우	법 제32조 제1항제4호	업무정지1개월	업무정지3개월	업무정지6개월
마. 법 제32조제3항에 따른 원칙과 기준을 위반하여 감정평가를 한 경우	법 제32조 제1항제5호	업무정지1개월	업무정지2개월	업무정지4개월

목차

I. 쟁점의 정리

II. 집행부정지 원칙과 집행정지(예외)(행정소송법 23조)

III. 집행정지 요건

- 적극적 요건(신청인에게 입증책임 있음)
 - 적법한 본안소송의 계속
 - 처분 등의 존재
 - 회복하기 어려운 손해발생의 우려
 - 긴급한 필요
- 소극적 요건(행정청에게 입증책임 있음)
 - 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없을 것
 - 본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것

IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

행정소송법 23조 1항의 집행부정지원칙의 예외로서 집행정지 요건을 검토한다.

II. 집행부정지 원칙과 집행정지(예외)(행정소송법 23조)

행정소송법 제23조 제1항은 '취소소송의 제기는 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다'고 하여 집행부정지를 원칙으로 규정하고 있다. 또한, 동조 제2항에서는 예외 규정으로 일정한 요건 하에서 처분의 효력등을 정지시키는 집행정지를 인정하고 있다. 소송의 과정은 장기간 소요되기도 하는데, 소송이 길어지면 승소 판결이 있다고 하더라도 당사자에게 회복되기 어려운 손해가 발생하는 등 실익이 없는 경우가 있을 수 있다. 따라서 예외적으로 집행정지를 인정하여 효과적인 권리보호를 실현하는데 그 취지가 인정된다.

III. 집행정지 요건

1. 적극적 요건(신청인에게 입증책임 있음)

1) 적법한 본안소송의 계속

민사소송법상의 가구제와는 다르게 행정소송법상 집행정지를 신청하기 위해서는 적법한 본안소송이 계속 중일 것을 요한다. 따라서 본안소송이 취하되면 집행정지결정의 효력도 소멸한다.

2) 처분 등의 존재

집행정지의 대상이 되는 처분 등이 존재하여야 한다. 따라서 부작위에 대해서는 집행정지가 허용되지 않고, 처분의 효력이 발생하기 전이나 처분의 효력이 소멸된 후에도 집행정지가 허용되지 않는다.

3) 회복하기 어려운 손해발생의 우려

처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어야 한다. '회복하기 어려운 손해'란 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 이는 금전보상이 불능인 경우 또는 금전보상으로는 사회관념상 당사자가 참고 견딜수 없거나 또는 참고 견디기가 현저히 곤란한 경우의 유형, 무형의 손해를 말한다. 특히, 기업의 경우 기업 이미지 및 신용의 훼손으로 인하여 사업 자체를 계속할 수 없거나 중대한 경영상의 위기를 맞게 될 것으로 보이는 등의 사정이 이에 해당될 수 있다.

4) 긴급한 필요

회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정되어야 한다. '긴급

한 필요'란 본안판결을 기다릴 여유가 없는 것을 의미한다. 판례는 처분의 성질과 내용, 처분상대방이 입는 손해, 원상회복·금전배 상의 방법 및 난이 등은 물론 본안청구의 승소가능성의 정도 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다고 본다.

2. 소극적 요건(행정청에게 입증책임 있음)

1) 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없을 것

행정소송법 제23조 제3항에 의거 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 허용되지 않는다. 여기서의 '공공복리'는 그 처분의 집행과 관련된 구체적이고도 개별적인 공익을 말하는 것이라고 보는 것이 판례의 입장이며, 비례의 원칙에 의해 집행정지가 공공복리에 미치는 영향과 집행부정지를 통해 당사자가 입는 손해를 비교·형량하여 결정한다.

2) 본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것

행정소송법상 명문으로 규정된 요건은 아니지만 '본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것'이 집행정지의 소극적 요건인지에 대해 견해 대립이 있다. 이에 대해 처분의 취소 가능성이 없음에도 집행정지를 인정하는 것은 집행정지제도의 취지에 반하며, 집행정지신청의 남용을 방지할 필요도 있으므로 '본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것'을 집행정지의 소극적 요건으로 보는 것이 일반적 견해이다.

IV. 사안의 해결

①B는 023. 7. 14. 취소소송을 제기하였고, 별도로 취하되지 않은바, 적법한 본안소송이 계속 중이다. ②집행정지의 대상이 되는 업무정지처분이 존재하고, ③감정평가업무의 특성상 업무정지로 업무가 단절될 경우 거래처 상실 등 중대한 경영상 위기를 맞게 될 것으로 보이는바, 회복하기 어려운 손해발생이 예상된다. ④처분의 효력 발생일을 고려할 때 긴급한 필요가 있다고 보인다. ⑤소극적 요건으로 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 있다고 판단할 근거가 미약하고, 감정평가법 시행령 별표3의 행정처분기준을 고려 시 본안청구가 이유 없음이 명백하다고 판단하기 어렵다. ⑥집행정지 요건을 충족하는바, 사안의 집행정지는 인용 가능할 것이다.

<p.145 가구제-가처분>기출23회3 변형

6. 20년 이상 감정평가업에 종사하고 있는 감정평가사 甲은 2년 전에 국토교통부장관 乙의 인가를 받아 50명 이상의 종업원을 고용하는 감정평가법인을 설립하였다. 그 후 乙은 甲이 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 감정평가법인의 설립인가를 받았다는 이유로 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제32조 제1항 제13호에 따라 설립인가를 취소하였다. 甲은 乙의 인가취소가 잘못된 사실관계에 기초한 위법한 처분이라는 이유로 취소소송을 제기하면서 법인의 임시적 지위를 인정해주길 요청하고 있다. 가처분 가능성을 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 학설
III. 판례
IV. 검토 및 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

가처분이란 확정판결이 있을 때까지 발생할 수 있는 현저한 손해나 급박한 위험 등을 막기 위해 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하는 것을 목적으로 하는 가구제 수단을 말한다(「민사집행법」 제300조). 행정소송법에는 가처분에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않아 민사집행법의 가처분에 관한 규정을 준용할 수 있는지가 문제된다.

II. 학설

① 행정소송법이 가처분을 배제하는 규정을 두고 있지 않고, 행정소송법 제8조 제2에 의거 민사집행법상 가처분이 준용될 수 있다고 보는 <긍정설>, ② 권력분립의 원칙상 가처분을 인정하는 것은 사법권의 범위를 벗어나는 것이고, 현행법상 가처분의 본안소송인 의무이행소송을 인정하고 있지 않아 가처분을 부정하는 <부정설> 및 ③ 행정소송법이 집행정지제도를 두고 있는 관계상 집행정지를 통해 실질적인 권리구제가 되지 않

는 경우에만 가처분제도가 인정될 수 있다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

III. 판례

판례는 민사집행법 제300조 제2항이 규정한 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 그 성질상 주장 자체에 의하여 다툼이 있는 권리관계에 관한 정당한 이익이 있는 자가 가처분 신청을 할 수 있고, 그 경우 주장 자체에 의하여 신청인과 저촉되는 지위에 있는 자를 피신청인으로 하여야 한다며 민사집행법상의 가처분으로 행정청의 행정행위 금지를 구하는 것은 허용될 수 없다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

IV. 검토 및 사안의 해결

① 행정소송법에서 가구제 수단으로서 집행정지제도를 규정하고 있는데, 이는 민사집행법상의 가처분제도를 배제하는 특별 규정으로 볼 수 있다. 따라서 해석론상으로는 <부정설>이 타당하다. 다만, 국민의 권리보호 확대를 위해 입법론적으로는 가처분제도의 도입이 필요하며, 행정소송법 개정안에서도 가처분제도를 인정하고 있다. ② 사안의 경우 집행정지로 구제가 가능하고, 그 인용가능성도 있는바, 행정소송법에 규정이 없는 가처분을 인정하기 어렵다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 기본강의 8-2회

<p.147 처분사유의 추가변경>기출29회2-2변형

01. 국토교통부장관A는 자격증을 부당행사 한 감정평가사 甲에게 감정평가법 제27조 위반을 이유로 징계절차를 거쳐 3개월의 업무정지처분을 하였고, 甲은 당해 처분이 위법하다고 보고 관할법원에 취소소송을 제기하였다. 이 취소소송의 계속 중 국토교통부장관 A는 당해 징계처분의 사유로 감정평가법 제27조의 위반사유 이외에, 징계처분 당시 甲이 국토교통부 장관에게 등록을 하지 아니하고 감정평가업무를 수행하였다는 동법 제17조의 위반사유를 추가하는 것이 허용되는가? (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 처분사유 추가변경의 의의 등
III. 처분사유 추가변경 인정여부
1. 학설
2. 판례
3. 검토
IV. 처분사유 추가변경 인정요건
V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

행정소송법은 처분사유의 추가·변경에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않아 취소소송 계속 중 처분사유 추가변경이 인정될 수 있는지, 사안의 경우 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는지 검토한다.

II. 처분사유 추가변경의 의의 등

처분사유의 추가·변경이란 처분청이 처분을 하면서 제시하지 않은 처분의 사실상·법률상

근거를 행정소송 계속 중에 추가·변경하여 처분의 적법성을 유지하는 것을 말한다.

III. 처분사유 추가변경 인정여부

1. 학설

① 처분사유의 추가·변경을 거부하여도 행정청은 새로운 사유를 들어 새로운 재처분을 할 수 있으므로 분쟁의 일회적 해결과 소송경제 측면에서 추가·변경을 인정하는 <긍정설>, ② 처분사유의 추가·변경을 인정하면 처분의 상대방은 예기치 않은 불이익을 받을 수 있으므로 부정하는 <부정설> ③ 소송경제와 원고의 방어권 보장을 조화시켜 제한적으로 허용하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

2. 판례

판례는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있다고 하여 <제한적 긍정설>의 입장을 취한다.

3. 검토

처분사유의 추가·변경을 부정하면 당해 처분이 취소되더라도 처분청은 다른 사유를 들어 새로운 재처분을 할 수 있으므로 소송경제 측면에서 타당하지 않다. 따라서 소송경제와 원고의 방어권을 보장을 조화시켜 당초 처분사유와 기본적 사실관계가 동일한 범위 내에서만 제한적으로 처분사유의 추가·변경을 긍정함이 타당하다.

IV. 처분사유 추가변경 인정요건

① 처분사유의 추가·변경은 사실심 변론종결시까지만 허용되며, ② 취소소송에서 처분의 위법성 판단의 기준시점을 처분시로 보는 <처분시설>에 따르면 처분시에 객관적으로 존재하였던 사유만이 처분사유의 추가·변경의 대상이 된다. ③ 처분사유의 추가·변경은 취소소송의 소송물 범위 내에서만 가능하다. ④ 추가·변경되는 처분사유는 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정되는 범위 내에서만 가능하다. 판례에 따르면 기본적 사실관계가 동일하다는 것은 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 말한다.

V. 사안의 해결

A가 추가한 처분사유는 당초 처분 시에 명시되지 않은 것이고, 당초 처분사유인 자격증 부당행사와 국토교통부장관에게 등록하지 않고 감정평가업무를 수행하였다는 점은 기본적 사실관계가 동일하다고 볼 수 없으므로, 같은 법 제17조의 위반사유를 추가하는 것은 허용될 수 없다.

<p.150 취소소송의 판결>

02. A구청장은 E구역 재개발사업시행인가처분을 하였다. 그런데 이곳은 재개발조합설립 및 사업시행인가에 필요한 동의를 법정요건을 갖추지 못한 곳이었다. 이에 당해 재개발지구 안의 토지소유자들은 취소소송을 제기하였고, 법원은 당해 처분이 위법하여 취소사유에 해당한다고 판단하였다. 만약 해당 지역의 주거환경이 열악하고, 90% 이상의 소유자가 재개발사업의 속행을 바라고 있어 재개발 사업의 공익목적에 비추어 그 처분의 취소가 현저히 공공복리에 적합하지 않는다고 인정될 때 법원이 할 수 있는 판결에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 사정판결의 의의(행정소송법 28조)
III. 사정판결의 요건
IV. 사정판결의 심리 및 효과
V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

사정판결에 대해 설명하고 사안을 검토한다.

II. 사정판결의 의의(행정소송법 28조)

사정판결이란 원고의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에도 처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우에 법원이 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다. 사정판결은 법률적합성의 원칙의 예외로서 판례는 공공복리를 위해 엄격한 요건 하에서 제한적으로 인정되어야 한다고 본다.

III. 사정판결의 요건

사정판결의 요건으로는 ① 원고의 청구가 이유 있다고 인정될 것, ② 처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 않을 것이 있다. 판례는 '현저히 공공복리에 적합하지 아니한가 여부'는 위법·부당한 행정처분을 취소·변경하여야 할 필요와 그 취소·변경으로 발생할 수 있는 공공복리에 반하는 사태 등을 비교·교량하여 그 적용 여부를 판단하여야 한다고 본다.

IV. 사정판결의 심리 및 효과

판례는 행정소송법 제26조를 근거로 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 사정판결이 가능하다고 본다. 처분의 위법성 여부는 <처분시설>에 따라 처분시를 기준으로 판단하고, 공공복리를 위한 사정판결의 필요성은 사실심 변론종결시(판결시)를 기준으로 판단한다. ① 법원은 판결의 주문에 위법함을 명시하여야 하고(행정소송법 제28조 제1항 단서), ② 미리 원고가 그로 인하여 입게 될 손해의 정도와 배상방법 그 밖의 사정을 조사하여야 하며(제2항), ③ 원고는 피고인 행정청이 속하는 국가 또는 공공단체를 상대로 손해배상, 제해시설의 설치 그 밖에 적당한 구제방법의 청구를 당해 취소소송등이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다(제3항).

V. 사안의 해결

사안의 처분은 관련 법령이 정하고 있는 소유자 동의요건을 갖추지 못해 위법한 처분이나 해당 지역의 주거환경이 열악하여 재개발이 시급한 점 등 재개발 사업의 공익목적에 비추어 그 처분의 취소가 현저히 공공복리에 적합하지 않다고 인정되는바, 법원은 사정판결을 할 수 있을 것이다.

<p.151 일부취소>

03. 국토교통부장관은 타당성조사 결과에 근거하여 고의로 잘못된 평가를 한 A 법인 소속 감정평가사 甲에 대하여 업무정지 6개월의 징계처분을 하였다. 이에 불복한 甲이 징계처분취소소송을 제기하였는바, 법원은 해당 징계처분을 업무정지 3개월의 징계처분으로 감경하는 판결을 할 수 있는지에 관하여 설명하시오. (10점) (업무정지는 일정기간 업무를 못하도록 하는 부작위하명으로 감정평가법 39조 1항 문언상 재량행위이다.)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 행정소송법 제4조 1호의 '변경'의 의미

III. 일부취소의 가능성 (요건 및 한계)

IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

행정소송법 제4조의 1호에서 취소소송을 '행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송'이라고 정의하고 있다. 이에 '변경'의 해석과 관련하여 법원이 일부취소판결을 할 수 있는지가 문제 된다.

II. 행정소송법 제4조 1호의 '변경'의 의미

①학설은 행정소송법 제4조 1호의 '변경'을 적극적 변경으로 보아 법원이 위법한 처분등을 취소하고 새로운 처분을 내용으로 하는 판결을 할 수 있다고 보는 <적극적 변경설>과 행정소송법에서 의무이행소송을 규정하고 있지 않으므로 행정소송법상 '변경'은 일부취소만을 의미한다고 보는 <소극적 변경설>이 대립하고, ②판례는 위 변경을 소극적 변경(일부취소)이라고 보는 입장을 취한다. ③생각건대, 적극적 변경설은 법원이 행정청의 처분권한을 행사하는 것과 같은 결과를 가져오므로 권력분립의 원칙에 반하여 타당하지 않고, 현행 행정소송법이 의무이행소송을 인정하고 있지 않으므로, 행정소송법상

'변경'을 소극적 변경으로서 일부취소를 의미한다고 보는 것이 타당하다.

III. 일부취소의 가능성 (요건 및 한계)

외형상 하나의 행정처분이라도 처분의 일부에만 위법이 있는 경우에 ① 가분성이 있거나, ② 일부취소되는 부분이 특정(특정성)될 수 있다면 그 일부만의 취소도 가능하다. 다만, 판례는 영업정지처분과 같이 재량행위인 경우에는 처분청의 재량권을 존중하여야 하므로 법원이 직접 처분을 하는 것은 인정되지 않는다고 본다. 따라서 일부취소판결을 할 수 없고 전부를 취소하여야 한다고 판시한다.

IV. 사안의 해결

업무정지는 일정기간 업무를 못하도록 하는 부작위하명으로 감정평가법 39조 1항 문언상 재량행위이다. 처분의 재량권 존중 차원에서 법원이 일부 취소할 수 없다. 따라서 법원은 해당 징계처분을 업무정지 3개월로 감경하는 판결을 할 수 없다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 기본강의 9회

<p.153 취소판결의 효력-형성력>기출25회 2-2번형

01. A시에서는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거하여 우회도로를 설치한 다는 방침을 결정하고, A시 시장은 X, Y, W토지의 개별공시지가 산정의 기초가 된 P토지의 표준지공시지가와 지가상승률 등을 반영하여 산정한 보상기준가격을 내부적으로 결정하고 중앙부처와 협의 중이다. X토지 소유자인 甲은 더 많은 보 상금을 받기 위해 P토지의 표준지공시지가에 불복하여 취소소송을 제기하여 확 정 인용판결을 받았다. 이 판결의 효력은 Y, W토지의 소유자인 乙에게도 미치는 지 설명하시오. (5점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 형성력(행정소송법 제29조) III. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

취소소송 인용판결의 효력 중 형성력이 문제된다.

II. 형성력(행정소송법 제29조)

판결의 형성력이란 처분 등에 대한 취소판결이 확정되면 처분청의 별도의 취소를 기다 릴 것 없이 처분 등이 당연히 효력을 상실하게 되는 것을 말한다. 행정소송법 제29조 제1의 해석에 의해 인정된다고 보며, 형성력은 제3자에게도 미친다.

III. 사안의 해결

P토지에 대한 표준지공시지가는 불특정 다수인을 상대방으로 하는 일반처분이다. 일반 처분의 취소에도 형성력 중 제3자효가 긍정된다. 따라서 乙은 Y, W토지의 개별공시지가 산정의 기초가 되는 표준지공시지가에 대한 취소의 인용판결의 효력에 영향을 받는다.

<p.153 취소판결의 효력-기판력>기출22회 2-1번형

02. 국토교통부장관은 감정평가업자 甲에 대하여 법령상 의무 위반을 이유로 6월 의 업무정지처분을 하였다. 甲은 업무정지처분취소소송을 제기하였으나 기각되었 고 동 기각판결은 확정되었다. 이에 甲은 위 처분의 위법을 계속 주장하며 동일 한 사항에 대해 취소소송을 제기할 수 있는지 설명하시오. (5점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 기판력 1. 의의 및 취지 2. 범위 III. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

사안은 취소소송의 인용판결의 효력 중 기판력이 문제된다.

II. 기판력

1.의의 및 취지
기판력이란 소송물에 관하여 판결이 확정되면 이후 동일한 사항이 문제되는 경우에 당 사자(승계인 포함)는 그에 반하는 주장을 할 수 없고(반복금지), 법원은 그에 반하는 판 단을 할 수 없는(모순금지) 구속력을 말한다. 기판력은 인용판결뿐만 아니라 기각판결에 도 인정되며, 재판 간 모순방지과 분쟁의 종국적인 해결에 그 취지가 인정된다.

2. 범위

①기판력은 당해 소송의 당사자 및 당사자와 동일시할 수 있는 승계인에게만 미치고, 제3자에게는 미치지 않는다. ②기판력은 사실심 변론종결시를 기준으로 발생한다. ③기 판력은 판결의 주문에 나타난 판단에만 미치며, 판결이유에서 실시된 그 전제가 되는 법률관계에까지는 미치지 않는다. 즉, 판결이유 중에 적시된 구체적인 위법사유에 관한 판단에는 미치지 않는다.

III. 사안의 해결

기판력은 기각판결에도 인정되며, 동일한 사항에 대해 당사자 및 법원을 구속한다. 따라 서 甲은 동일한 사항에 대해 취소소송을 제기할 수 없다. 단, 사실심 변론종결 이후 발 생한 새로운 사유를 들어 취소소송을 제기하는 건 가능하다.

<p.154 취소판결의 효력-기판력>기출22회 2-1번형

03. 국토교통부장관은 감정평가업자 甲에 대하여 법령상 의무 위반을 이유로 6월의 업무정지처분을 하였다. 甲은 업무정지처분취소소송을 제기하였으나 기각되었고 동 기각판결은 확정되었다. 이에 甲은 위 처분의 위법을 계속 주장하면서 이로 인한 재산상 손해에 대해 국가배상청구소송을 제기하였다. 이 경우 업무정지처분취소소송의 기판력이 국가배상청구소송에 미치는 영향을 설명하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 기판력
III. 기판력과 국가배상청구소송
1. 학설
2. 판례
3. 검토
IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

국가배상청구소송에서 취소소송의 소송물(위법성)이 국가배상청구소송의 선결문제가 되는 경우에 취소소송의 기판력이 국가배상청구소송에 영향을 미치는지가 문제 된다. 이는 위 소송에서 위법의 개념이 동일한 것인지에 대한 논의와 연결된다.

II. 기판력

기판력이란 소송물에 관하여 판결이 확정되면 이후 동일한 사항이 문제되는 경우에 당사자(승계인 포함)는 그에 반하는 주장을 할 수 없고(반복금지), 법원은 그에 반하는 판단을 할 수 없는(모순금지) 구속력을 말한다. 기판력은 인용판결뿐만 아니라 기각판결에도 인정되며, 재판간 모순방지와 분쟁의 종국적인 해결에 그 취지가 인정된다.

III. 기판력과 국가배상청구소송

1. 학설

① 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 동일한 개념이라고 보아 취소소송의 확정판결 (인용·기각판결)의 기판력이 국가배상청구소송에 미친다고 보는 <기판력 긍정설>, ② 취소소송의 위법과 국가배상청구소송의 위법을 다른 개념으로 보고, 양자의 소송물이 달라 기판력이 미치지 않는다고 보는 <기판력 부정설> 및 ③ 국가배상청구소송의 위법의 범위가 취소소송의 위법 보다 넓다고 보아 인용판결의 기판력은 국가배상청구소송에 미치나, 기각판결의 기판력은 미치지 않는다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

2. 판례

판례는 '국가배상책임에 있어 공무원의 가해행위는 법령을 위반한 것이어야 하고, 법령을 위반하였다 함은 엄격한 의미의 법령 위반뿐 아니라 인권존중, 권력남용금지, 신의성실과 같이 공무원으로서 마땅히 지켜야 할 준칙이나 규범을 지키지 아니하고 위반한 경우를 포함하여 널리 그 행위가 객관적인 정당성을 결여하고 있음을 뜻하는 것'(대판 2008.6.12 2007다64365)이라고 하거나, '어떠한 행정처분이 후에 항고소송에서 취소되었다고 할지라도 그 기판력에 의하여 당해 행정처분이 곧바로 공무원의 고의 또는 과실로 인한 것으로서 불법행위를 구성한다고 단정할 수는 없는 것'(대판 2000.5.12. 99다 70600)이라고 판시하는 바, 기판력에 관한 입장이 불분명하다.

3. 검토

취소소송과 국가배상청구소송의 위법의 개념을 어떻게 보는지에 따라 취소판결의 기판력이 미치는지 여부가 달라진다. 국가배상청구소송의 위법을 취소소송의 위법보다 더 넓게 보는 광의의 행위위법설이 통설이며 이 견해에 따라 인용판결의 기판력만이 국가배상청구소송에 미친다고 보는 <제한적 긍정설>이 일반적인 견해이다.

IV. 사안의 해결

손해전보를 목적으로 하는 국가배상에서 반드시 항고소송의 기판력이 미친다고 할 수 없지만, 공무원은 국민에 대한 봉사자 지위를 가지나, 손해발생방지의무를 부담하는 것이 타당하다. 따라서 제한적 긍정설이 타당하며, 기각판결의 경우 국가배상청구소송의 위법성 판단에 기판력이 미치지 않는다. 즉, 사안의 업무정지처분취소소송의 기각판결의 기판력이 국가배상청구소송의 위법성 판단에 영향을 미치지 않는다.

<p.155 취소판결의 효력-기속력>

04. 사업시행자 甲은 평창동계올림픽 대회시설사업을 하기 위해 사업인정 요건을 갖춰 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하였으나 국토교통부장관은 토지보상법 4조의 대상사업이 아니라는 이유로 거부하였다. 이에 甲은 거부처분 취소소송을 제기하였고 당해 거부처분이 위법하다는 인용판결을 받았다. 그런데, 소송 계속 중에 법령이 개정되어 평창동계올림픽 대회시설사업이 토지보상법 4조 공익사업에서 삭제되었다. 취소판결의 효력 중 기속력에 대해 설명하고, 사안의 국토교통부장관이 甲에게 토지보상법 4조의 대상사업이 아니라는 이유로 다시 거부처분을 할 경우 기속력에 반하는지 검토하시오. (20점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 기속력의 의의 및 법적성질(행정소송법 30조)
III. 기속력의 범위
1. 주관적 범위
2. 시간적 범위
3. 객관적 범위(기본적 사실관계의 동일성)
IV. 기속력의 내용
1. 반복금지의무 (「행정소송법」 제30조 제1항)
2. 재처분의무 (「행정소송법」 제30조 제2항)
3. 결과제거의무 (원상회복의무)
V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

인용판결 후 법령이 개정시행된 경우 개정된 법령 및 허가기준을 새로운 사유로 들어 다시 이전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있는지 기속력을 검토한다.

II. 기속력의 의의 및 법적성질(행정소송법 30조)

기속력이란 처분등을 취소하는 확정판결이 있으면 그 사건의 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청은 확정판결의 취지에 따라야 하는 의무를 발생시키는 효력(구속력)을 말한다. 기속력의 법적성질을 ① 기판력과 동일하다고 보는 <기판력설>이 있으나, ② 기속력은 취소판결의 실효성을 확보하기 위해 행정소송법에서 특별히 인정하는 효력이라고 보는 <특수효력설>이 통설 및 판례의 입장이다. 생각건대, 기판력은 모든 본안판결의 효력이며 소송법상 효력이나, 기속력은 취소판결(인용판결)에서의 효력이며 실체법상 효력이므로 양자를 다르게 보는 <특수효력설>이 타당하다.

III. 기속력의 범위

1. 주관적 범위

기속력은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 기속한다(행정소송법 제30조 제1항). 여기서 '관계 행정청'이란 당해 판결에 의해 취소되는 처분등을 기초로 하여 그와 관련되는 처분이나 부수되는 행위를 할 수 있는 모든 행정청을 말한다.

2. 시간적 범위

기속력의 시간적 범위는 처분의 위법성 판단의 기준시점을 처분시로 보는 처분시설에 따라 처분시에 존재 하던 사유에만 기속력이 미친다고 보는 것이 통설 및 판례의 태도이다. 따라서 처분의 취소판결이 있을 후 새로운 처분사유(법령 및 사실상태)에 의해 동일한 내용의 처분을 하더라도 이는 기속력에 반하지 않는다.

3. 객관적 범위(기본적 사실관계의 동일성)

① 기속력은 판결주문 및 그 전제가 된 처분의 구체적인 위법사유에만 미치는데, 여기서 처분의 구체적 위법사유는 판결주문 및 이유에서 판단된 위법사유와 기본적 사실관계가 동일한 사유를 말한다. ② 기본적 사실관계의 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지에 따라 결정된다. 기본적 사실관계의 동일성에 관해 구체적인 판단은 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양·결과 등의 제반사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

IV. 기속력의 내용

1. 반복금지의무 (「행정소송법」 제30조 제1항)

취소판결이 확정되면 당사자인 행정청과 관계 행정청은 확정판결에 반하는 처분을 하여서는 안 된다. 즉, 행정청은 동일한 사실관계 하에서 동일한 당사자에 대하여 동일한 내

용의 처분등을 반복해서는 안 되며, 이를 위반한 처분은 하자가 중대하고 명백하여 당 연무효가 된다.

2. 재처분의무 (「행정소송법」 제30조 제2항)

행정소송법 제30조 제2항에 의거 판결에 의하여 취소되는 처분이 당사자의 신청을 거부하는 것을 내용으로 하는 경우에는 그 처분을 행한 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다. 재처분의무는 판결의 취지를 존중하면 되는 것이므로 반드시 원고가 신청한 내용대로 재처분을 해야 하는 것은 아니다. 재처분 의무는 신청에 따른 처분이 절차의 위법을 이유로 취소되는 경우에 준용한다(동조 제3항).

3. 결과제거의무 (원상회복의무)

취소판결이 확정되면 행정청은 취소된 처분으로 인해 초래된 위법상태를 제거해야할 결과제거의무(원상 회복의무)를 진다. 결과제거의무에 대한 명문의 규정은 없지만 일반적으로 행정소송법 제30조 제1항의 해석상 인정된다고 보며, 행정소송법 개정안에는 이를 명문화하고 있다.

V. 사안의 해결

1. 관련판례

1) 새로운 사유로 하는 동일한 처분 (반복금지의무 위반 X)

행정소송법 제30조 제2항에 의하면, 행정청의 거부처분을 취소하는 판결이 확정된 경우에는 처분을 행한 행정청이 판결의 취지에 따라 이전 신청에 대하여 재처분을 할 의무가 있다. 행정처분의 적법 여부는 행정처분이 행하여진 때의 법령과 사실을 기준으로 판단하는 것이므로 확정판결의 당사자인 처분 행정청은 종전 처분 후에 발생한 새로운 사유를 내세워 다시 거부처분을 할 수 있고, 그러한 처분도 위 조항에 규정된 재처분에 해당한다. 여기에서 '새로운 사유'인지는 종전 처분에 관하여 위법한 것으로 판결에서 판단된 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 사유인지에 따라 판단되어야 한다.

2) 거부처분 후 법령 개정

행정처분의 적법 여부는 그 행정처분이 행하여진 때의 법령과 사실을 기준으로 하여 판단하는 것이므로 거부처분 후에 법령이 개정·시행된 경우에는 개정된 법령 및 허가기

준을 새로운 사유로 들어 다시 이전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있으며 그러한 처분도 행정소송법 제30조 제2항에 규정된 재처분에 해당된다.

2. 검토(기속력에 반하지 않음)

국토교통부장관의 거부처분에 대한 甲의 취소소송에서 당해 거부처분을 취소하는 확정 판결이 있는 취 국토교통부장관이 동일한 사유를 들어 다시 거부처분을 하였다 하더라도 확정판결 후 거부처분은 개정된 법령의 기준에 따른 것으로 행정소송법 30조 2항의 재처분에 해당한다. 따라서 국토교통부장관이 甲에게 토지보상법 4조의 대상사업이 아니라는 이유로 다시 거부처분을 하더라도 기속력에 반하지 않는다.

<p.158 간접강제>

05. 사업시행자 A는 토지보상법 4조에 따른 학교 건립 사업을 하기 위해 국토교통부장관에게 토지보상법상 사업인정요건을 갖춰 사업인정 신청을 하였으나 국토교통부장관은 공공성이 없다는 사유로 거부하였다. 이에 A는 거부처분 취소소송을 제기하였고, 인용판결을 받았다. 그러나 상당한 기간이 지나도록 국토교통부장관이 사업인정을 해주지 않고 있다. 행정소송법 제30조 제2항에 따른 재처분의무를 이행하지 않을 때, 판결의 실효성 확보를 위한 행정소송법상 제도에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리(간접강제)
II. 간접강제의 의의 및 취지(행정소송법 34조)
III. 간접강제의 요건 및 절차
IV. 배상금의 성질 및 적용범위
V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리(간접강제)

행정소송법 30조2항의 재처분의무를 이행하지 않을 때 행정소송법은 판결의 실효성 확보를 위해 간접강제 제도를 규정하고 있는바, 간접강제에 대해 설명한다.

II. 간접강제의 의의 및 취지(행정소송법 34조)

간접강제란 행정청이 행정소송법 제30조 제2항에 따른 재처분의무를 이행하지 않을 때, 법원이 일정한 절차에 따라 행정청에게 배상을 명하는 제도를 말한다. 간접강제는 판결의 실효성 확보에 그 취지가 인정된다.

III. 간접강제의 요건 및 절차

1. 간접강제의 요건으로는 ① 거부처분에 대한 취소판결이 확정될 것과 ② 처분청이 거부처분취소판결의 취지에 따른 재처분을 하지 않을 것이 있다. 여기에서 '재처분을 하지 않은 것'에는 아무런 재처분을 하지 않은 것뿐만 아니라, 재처분이 기속력에 반하여 당연무효가 된 것도 포함된다. 2. 간접강제는 ① 당사자가 제1심 수소법원에 간접강제를 신청하고, ② 법원은 간접강제의 신청이 이유 있다고 인정함으로써 간접강제결정을 한다. 간접강제결정으로써 법원은 상당 기간을 정하고 그 기간 내에 이행하지 아니하면 지연기간에 따라 일정한 배상을 명하거나, 즉시 손해배상 할 것을 명할 수 있다.

IV. 배상금의 성질 및 적용범위

판례는 간접강제는 행정청으로 하여금 확정판결의 취지에 따른 재처분의무의 이행을 확실히 담보하기 위한 것으로서 재처분 지연에 대한 제재나 손해배상은 아니고 재처분의 이행에 관한 심리적 강제수단에 불과한 것이라고 보았다. 따라서 간접강제결정에서 정한 의무이행기한이 경과한 후에도 확정판결의 취지에 따른 재처분의 이행이 있으면 더 이상 배상금을 추심하는 것은 허용되지 않는다고 본다. 무효등확인판결의 경우 행정소송법의 준용규정이 없어 견해대립이 있으나 판례는 부정하는 입장이다. 판결의 실효성 확보차원에서 긍정하는 것이 타당하다.

V. 사안의 해결

사안은 거부처분에 대한 취소판결이 확정되었고, 국토교통부장관이 그 취지에 따른 재처분을 하지 않았다. 이에 A는 제1심 수소법원에 간접강제를 신청할 수 있다. 간접강제결정으로써 법원은 상당 기간을 정하고 그 기간 내에 이행하지 아니하면 지연기간에 따라 일정한 배상을 명하거나, 즉시 손해배상 할 것을 명할 수 있다.

<p.160 청구의 병합>

06. 토지보상법 74조에 의해 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때 해당 토지소유자는 사업시행자(관할 토지수용위원회)에게 잔여지 매수(수용)청구를 할 수 있고, 동법73조에 의해 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되거나 수용됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 경우 등엔 사업시행자는 그 손실이나 공사비 등 보상을 하여야 한다. 즉, 잔여지 수용청구와 잔여지 가격감소로 인한 손실보상청구는 서로 양립할 수 없다. 잔여지 수용청구와 잔여지 가격감소로 인한 손실보상청구의 선택적 병합청구가 가능한지 검토하시오. (잔여지 수용청구와 잔여지 가격감소 손실보상청구의 개념검토는 생략할 것) (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 청구병합의 의의 및 취지(행정소송법 10조)
III. 청구병합의 종류
IV. 청구병합의 요건
V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

청구의 병합에 대해 설명하고, 취소소송 계속 중에 서로 양립할 수 없는 청구를 선택적으로 병합할 수 있는지에 대해 논한다.

II. 청구병합의 의의 및 취지(행정소송법 10조)

청구의 병합이란 하나의 소송절차에서 여러 개의 청구를 하는 것(객관적 병합) 또는 소송당사자가 수인이 되는 것(주관적 병합)을 말한다. 청구의 병합은 소송경제 도모와 판결간 모순방지 등에 취지가 있으며, 행정소송법 제10조 제2항, 민사소송법 제253조 등에 근거가 있다.

III. 청구병합의 종류

청구의 병합의 종류에는 ① 양립하는 여러 개의 청구를 병렬적으로 병합하는 단순병합(모든 청구에 대해 법원의 판결이 필요), ② 여러 개의 청구 가운데 어느 하나가 인용되면 다른 청구에 대해서는 심판을 바라지 않은 형태의 선택적 병합, ③ 양립되지 않는 청구를 주위적·예비적으로 병합하는 예비적 병합이 있다.

IV. 청구병합의 요건

청구의 병합의 요건으로는 ① 주된 청구인 행정사건에 관련 청구를 병합할 것, ② 각 청구가 적법요건을 갖출 것, ③ 청구 사이에 기초되는 사실의 관련성(견련성)이 있어야 한다. 다만, 피고가 같을 필요는 없다.

V. 사안의 해결

①서로 양립 가능한 여러 개의 청구 가운데 어느 하나가 인용되면 다른 청구에 대해서는 심판을 하지 않는 형태의 병합이 선택적 병합인데, ②잔여지 수용청구와 잔여지 가격감소로 인한 손실보상청구는 서로 양립할 수 없는 관계에 있어 선택적 병합이 불가능하고 주위적·예비적 병합이 가능할 것이다. 판례도 두 청구의 선택적 병합이 불가능하다 보았다.

<p.160 소송참가>

07. A시에서는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거하여 우회도로를 설치한
다는 방침을 결정하고, A시 시장은 X, Y, W토지의 개별공시지가 산정의 기초가
된 P토지의 표준지공시지가와 지가상승률 등을 반영하여 산정한 보상기준가격을
내부적으로 결정하고 중앙부처와 협의 중이다. X토지 소유자인 甲은 더 많은 보
상금을 받기 위해 P토지의 표준지공시지가에 불복하여 당해 국토교통부장관을
피고로 취소소송을 제기하였다. 이 취소소송에 P토지 소유자인 丙이 소송에 참가
할 수 있는지 검토하십시오. (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 제3자의 소송참가 의의 및 취지(행정소송법 16조)

III. 제3자의 소송참가의 요건과 절차

IV. 소송참가인의 지위

V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

甲의 취소소송 계속 중에 제3자인 丙의 소송참가 가능여부를 검토한다.

II. 제3자의 소송참가 의의 및 취지(행정소송법 16조)

제3자의 소송참가란 소송의 결과에 의해 권익의 침해를 받을 제3자가 있는 경우에 당
사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 그 제3자를 소송에 참가시키는 제도를 말
한다. 제3자의 권익을 보호에 그 취지가 인정된다.

III. 제3자의 소송참가의 요건과 절차

제3자의 소송참가의 요건으로는 ① 타인간의 취소소송 등이 계속 중일 것, ② 소송결과

에 따라 법률상 이익의 침해를 받을 제3자일 것이 있다. 여기에서 '제3자'란 소송당사자
이외의 자를 말하고, '이익의 침해'는 법률상 이익을 말하며, 단순한 사실상의 이익이나
경제상의 이익은 포함되지 않는다. 법원은 소송의 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권
에 의해 참가결정을 하고, 법원이 결정을 하는 때에는 미리 당사자 및 제3자의 의견을
들어야 한다. 제3자는 각하결정에 대해 즉시항고를 할 수 있다.

IV. 소송참가인의 지위

소송참가는 민사소송법 제67조가 준용되므로 소송참가인의 필수적 공동소송에서의 공
동소송인에 준하는 지위에 서게 되나, 당사자적격은 없으므로 공동소송적 보조참가인의
지위와 유사하다고 보는 것이 통설이다.

V. 사안의 해결

①사안의 취소소송의 당사자는 甲과 국토교통부장관으로 丙은 소송당사자 외의 자이며,
②취소소송이 적법하게 계속 중이라면 ③丙은 P토지의 공시지가 상승 시 과세 등에 있
어 불리한 지위에 놓을 수 있으므로 법률상 이익의 침해우려가 있으므로 ④신청 또는
직권에 의하여 공동소송적 보조참가인의 지위에서 위 취소소송에 참가할 수 있을 것이
다.

<p.162 무효등확인소송-사정판결>

08. 감정평가법인A는 ‘업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간 중에 감정평가법 제10조의 업무를 하게 한 사유’로 업무정지처분을 받아야 하나, 표준지공시지가 업무를 수행하고 있는 법인으로서 업무정지처분에 갈음하여 동법 제41조 과징금 처분을 받았다. 그런데 국토교통부장관이 아닌 권한 없는 행정청의 과징금 처분이었다. A법인은 무효등확인소송을 제기하였고, 피고는 공익의 중대함을 사유로 사정판결을 주장하였다. 법원은 사정판결을 할 수 있는지 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 과징금처분의 법적성질, 위법성 및 위법성정도
III. 무효등확인소송의 사정판결 가능성
1. 학설
2. 판례
3. 검토
IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

주체상 하자가 있는 과징금 처분이 무효인지 검토하고, 행정소송법 38조1항은 동법28조 사정판결을 준용하지 않는바, 무효등확인소송에서 사정판결을 할 수 있는지 검토한다.

II. 과징금처분의 법적성질, 위법성 및 위법성정도

①과징금이란 행정법상 의무를 위반한 자에게 그 위반행위로 인한 경제상 이익을 박탈

하기 위하여 부과·징수하는 금전을 의미하나, 감정평가법상 과징금은 업무정지처분에 갈음하는 변형된 과징금이다. 과징금처분은 급부하명으로 처분이다. ②사안의 과징금처분은 권한 없는 행정청의 처분으로 주체상 하자가 있고, 이는 통설판례인 중대명백설에 따라 중대하고 명백한 하자로 무효사유에 해당한다.

III. 무효등확인소송의 사정판결 가능성

1. 학설

① 무효나 취소는 하자의 정도의 차이에 불과하고 그 구별이 상대적이므로 공익성을 존중하여 사정판결을 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>과 ② 법문언상 준용규정이 없으므로 인정될 수 없다고 보는 <부정설>이 대립한다.

2. 판례

판례는 ‘당연무효의 행정처분을 소송목적물로 하는 행정소송에서는 존치시킬 효력이 있는 행정행위가 없기 때문에 행정소송법 제28조 소정의 사정판결을 할 수 없다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

3. 검토

사정판결은 법치주의의 예외적 조치에 해당하므로 그 해석에 있어 엄격성이 요구된다. 따라서 준용 규정이 없음을 근거로 판례의 태도와 같이 무효등확인소송에서 사정판결은 부정함이 타당하다.

IV. 사안의 해결

사안은 당연무효의 행정처분으로 존치시킬 처분도 없거니와 무효등확인소송에서 사정판결을 준용할 규정이 없는바, 법원은 사정판결을 할 수 없다.

<p.163 무효등확인소송-즉시확정 이익>

09. 감정평가법인A는 ‘업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간 중에 감정평가법 제10조의 업무를 하게 한 사유’로 업무정지처분을 받아야 하나, 표준지공시지가 업무를 수행하고 있는 법인으로서 업무정지처분에 갈음하여 동법 제41조 과징금 처분을 받았다. A법인은 과징금을 전액 납부하였다. 그런데 당해 과징금처분은 국토교통부장관이 아닌 권한 없는 행정청의 과징금 처분이었다. 그 사실을 안 A법인은 무효등확인소송을 제기하였다. A법인이 부당이득반환소송이라는 보다 실효적인 권리구제 수단이 있음에도 불구하고 무효등확인소송을 제기한 것이 적법한지 검토하시오. (10점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 과징금처분의 법적성질, 위법성 및 위법성정도
III. 무효등확인소송의 소송요건
IV. 확인소송의 보충성(즉시확정 이익의 필요 여부)
1. 학설
2. 판례
3. 검토
V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

무효등확인소송의 소송요건을 검토하고, 행정소송법 35조의 ‘확인을 구할 법률상 이익’과 관련하여 민사소송법상의 확인의 이익이 무효등확인소송에서도 요구되는지 검토한다.

II. 과징금처분의 법적성질, 위법성 및 위법성정도

① 감정평가법상 과징금은 업무정지처분에 갈음하는 변형된 과징금이며, 급부하명의로 처분이다. ② 사안의 과징금처분은 권한 없는 행정청의 처분으로 주체상 하자가 있고, 이는 통설판례인 중대명백설에 따라 중대하고 명백한 하자로 무효사유에 해당한다.

III. 무효등확인소송의 소송요건

무효등확인소송이란 행정청의 처분 등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송을 말한다. 무효등확인소송이 적법하려면 대상적격(행정소송법 19조, 38조 1항), 원고적격(동법 35조), 피고적격(동법 13조, 38조 1항) 등의 요건을 갖추어야 한다. 그러나 예외적 행정심판전치주의(동법 18조)나 제소기간(동법 20조)에 관한 규정은 적용되지 않는다. 사안의 과징금처분은 처분으로 대상적격이 있다.

IV. 확인소송의 보충성(즉시확정 이익의 필요 여부)

1. 학설

① 무효등확인소송에서 취소판결의 기속력(행정소송법 제30조) 규정을 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 판결의 실효성을 확보할 수 있어 확인의 소의 보충성은 요구되지 않는다고 보는 <보충성 불요설>과 ② 무효등확인소송은 확인소송의 성질을 가지고 있으므로 확인의 소의 보충성이 필요하다고 보는 <보충성 필요설>이 대립한다.

2. 판례

종래에는 무효등확인소송에서 확인의 소의 보충성이 필요하다고 보았으나, 이를 변경하여 무효확인소송의 보충성이 요구되는 것이 아니라고 판시하였다.

3. 검토

무효등확인소송은 행정소송법 제30조를 준용하므로 무효확인판결의 기속력에 따라 무효판결만으로도 판결의 실효성을 확보할 수 있다. 따라서 확인소의 보충성이 요구되지 않는다고 보는 <보충성 불요설>이 타당하다.

V. 사안의 해결

과징금처분은 대상적격이 인정되며, 민사소송과 달리 무효등확인소송은 확인의 이익이 불요한바, A법인 제기한 무효등확인소송은 적법하다.

<p.165 부작위위법확인소송>(기출16회 1번 변형)

10. 사업시행자인 甲은 사업인정을 받은 후에 토지소유자 乙과 협의절차를 거쳤으나 협의가 성립되지 아니하여 중앙토지수용위원회에 재결을 신청하였다. 그러나 丙이 乙명의의 토지에 대한 명의신탁을 이유로 재결신청에 대해 이의를 제기하자, 중앙토지수용위원회는 상당한 기간이 경과한 후에도 재결처분을 하지 않고 있다. 이에 甲은 부작위위법확인소송을 제기하였다. 법원은 어떠한 판단을 하여야 하는지 검토하시오. 만약 부작위위법확인소송 계속 중에 중앙토지수용위원회의 거부처분이 있을 경우 거부처분취소소송으로 소변경 가능한지 검토하시오. (15점)

목차
I. 쟁점의 정리
II. 부작위위법확인소송의 의의 및 성질
III. 부작위위법확인소송의 소송요건
1. 대상적격
1) 부작위의 의의
2) 부작위의 성립요건
2. 원고적격
3. 제소기간
4. 소송요건 검토
IV. 부작위위법확인소송의 심리범위 및 위법성 판단시점
V. 거부처분취소소송으로 소변경 가능성
1. 학설
2. 검토
VI. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

부작위위법확인소송의 소송요건과 심리범위에 대해 검토하고, 소 계속 중 거부처분이 있을 경우 행정소송법 22조 준용규정이 없는바, 소변경 가능성을 검토한다.

II. 부작위위법확인소송의 의의 및 성질

부작위위법확인소송이란 행정청이 상대방의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 해야 할 의무가 있음에도 불구하고 이를 이행하지 않는 경우 이러한 부작위가 위법한 것임을 확인하는 소송을 말한다. 확인소송이자, 항고소송이다.

III. 부작위위법확인소송의 소송요건

1. 대상적격(부작위)

1) 부작위의 의의

부작위라 함은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말한다(행정소송법 제2조 2호).

2) 부작위의 성립요건

①당사자의 신청이 있어야 한다. 신청권의 필요성에 대해 견해대립이 있으나 판례는 당사자에게 법규상·조리상 신청권이 없는 경우 부작위위법확인소송은 부적법하다고 판시한바 있다. ②당사자의 신청 후 상당한 기간이 경과하도록 행정청이 아무런 처분을 하지 않아야 한다. ③행정청에게 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고, ④아무런 처분을 하지 않아야 한다.

2. 원고적격

행정소송법 제36조에서 '부작위위법확인소송은 처분의 신청을 한 자로서 부작위의 위법의 확인을 구할 법률상 이익이 있는 자만이 제기할 수 있다'고 규정하고 있다. 법규상·조리상 신청권 유무에 대해 견해대립이 있으나 통설 및 판례는 부작위의 성립 요건으로 신청권을 요구하고 있으므로, 부작위가 있으면 신청권이 있는 자에게 원고적격이 인정된다고 본다.

3. 제소기간

행정소송법 38조2항에서 제소기간 준용규정이 있으나 명시적 처분등이 없으므로 제소기간에 대해 견해가 나뉜다. 판례는 부작위가 계속되는 한 그 위법의 확인을 구할 이익이 있다고 보아 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않는다고 본다. 생각건대, 행정심판법상 부작위에 대한 의무이행심판에 심판청구기간의 제한을 두고 있지 않고, 상당한 기간도 불확정적인 것으로 부작위의 종료시점을 정하기가 어려운 점을 고려하여 ②설 및 판례와 같이 제소기간의 제한이 없다고 보는 것이 타당하다.

4. 소송요건 검토

①사업시행자 甲의 토지보상법 28조에서 신청권을 인정하는, 재결신청이 있었고, 토지보상법 31조~35조에 따라 중앙토지수용위원회의 재결 의무가 있음에도, 상당한 기간이 경과하도록 아무런 처분을 하지 않고 있으므로 대상적격인 부작위가 있다. ②사업시행자 甲은 신청의 당사자로 토지보상법상 인정되는 법률상 이익이 있는바, 원고적격도 인정된다. ③부작위가 계속되고 있어 제소기간의 제한이 없는바, 사안은 소송요건을 갖춘 적법한 부작위위법확인소송이다.

IV. 부작위위법확인소송의 심리범위 및 위법성 판단시점

①부작위의 위법 여부만 심리하는지 처분의무 여부도 심리하는지 견해대립이 있으나 판례는 부작위위법확인소송은 부작위의 위법을 확인하여 부작위 내지 무응답이라는 소극적인 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 한다고 하여 <절차적 심리설>의 입장을 취한다. 생각건대, 확인 소송인 점에서 판례와 같이 부작위의 위법한 여부만을 심리하는 <절차적 심리설>이 타당하다. ②부작위위법확인소송은 처분이 존재하지 않으므로, 위법성 판단은 <판결시>를 기준으로 하여야 한다.

V. 거부처분취소소송으로 소변경 가능성

1. 학설

① 행정소송법 제22조의 처분변경에 의한 소의 변경에 대한 준용규정을 두지 않은 것은 입법의 불비에 해당하므로, 행정소송법 제21조를 적용하여 소변경을 인정하여야 한다고 보는 <긍정설>과 ② 행정소송법 제21조는 행정소송의 종류를 잘못할 선택한 경우에 위함을 방지함에 그 취지가 있는 것이고, 행정소송법 제22조를 준용하지 않으므로 처분변경으로 인한 소의 변경을 할 수 없다고 보는 <부정설>이 대립한다.

2. 검토

부작위위법확인소송과 거부처분취소소송은 모두 일정한 처분을 받는 것을 목적으로 한다. 이에 양자의 청구의 기초에 변경이 없으므로 행정소송법 제21조를 준용하여 소의 변경이 가능하다고 보는 것이 타당하다.

VI. 사안의 해결

①사안의 부작위위법확인소송은 소송요건을 갖춘 적법한 소송으로 중앙토지수용위원회는 사업시행자의 재결신청을 받은 경우 일정한 기간 내 재결을 하여야 하는 토지보상법상 의무가 있음에도 아무런 처분을 하지 않은 위법이 있다. 만약 판결 시까지 중앙토지수용위원회의 부작위가 계속된다면 법원은 인용판결을 하게 될 것이다. ②만약 부작위위법확인소송 계속 중에 중앙토지수용위원회의 거부처분이 있다면 행정소송법 22조 준용규정 미비에도 불구하고, 부작위위법확인소송과 거부처분취소소송의 목적의 균형을 고려하여 거부처분취소소송으로의 소변경이 가능하다고 볼 것이다.

<p.169 당사자소송> 개념확인

11. 재개발조합을 상대로 조합원자격 유무에 관한 확인을 구하는 소송과 같이 행정청의 처분 등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송으로 그 법률관계 한 쪽 당사자를 피고로 하는 소송에 대해 설명하시오. (10점)

목차
I. 개설(당사자소송의 의의)
II. 당사자소송의 대상
III. 당사자소송의 종류
1. 실질적 당사자소송
2. 형식적 당사자소송
IV. 기타논의(확인 의 이익 요구)

I. 개설(당사자소송의 의의)

행정소송법 제3조 2호에서 당사자소송을 '행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송'이라고 정의하고 있다. 당사자소송은 공법상의 법률관계에 관하여 의문이나 다툼이 있는 경우에 그 법률관계의 당사자가 원고 또는 피고가 되어 법률관계를 다투는 소송을 의미한다. 항고소송과는 소송의 성질, 피고적격, 제소기간 등에서 구별된다.

II. 당사자소송의 대상

항고소송은 행정청의 공권력 행사를 직접 대상으로 하지만, 당사자소송은 공권력 행사·불행사로 생긴 법률관계 및 그 밖의 공법상 법률관계를 대상으로 한다.

III. 당사자소송의 종류

1. 실질적 당사자소송

실질적 당사자소송이란 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송을 말한다. 일반적으로 당사자소송이라 함은 실질적 당사자소송을 의미한다. 구체적으로 과징금처분의 무효를 이유로 한 부당이득반환청구소송처럼 <처분 등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송>과 공법상 계약에 관한 소송, 공법상 금전지급청구소송, 공법상 신분·지위 확인 소송, 공법상 결과제거청구소송, 행정처분에 이르는 절차적 요건의 존부나 효력유무에 관한 소송, 법률관계 그 자체를 다투는 소송 등이 있다.

2. 형식적 당사자소송

형식적 당사자소송이란 실질적으로는 행정청의 처분등을 다투는 것이나 형식적으로는 처분등으로 인해 형성된 법률관계를 다투기 위해 관련 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 당사자소송을 말한다. 토지보상법 제85조 제2항의 보상금증감청구소송이 이에 해당 한다.

IV. 기타논의 (확인 의 이익 요구)

행정소송법에 당사자소송의 원고적격에 대한 규정이 없다. 따라서 민사소송법이 준용되어, 소송의 내용이 이행소송인 경우 이행청구권이 있음을 주장하는 자이면 원고적격이 인정되고, 소송의 내용이 확인소송인 경우 확인의 이익을 가지는 자에게 원고적격이 인정된다. 당사자소송은 민사소송과 유사하기 때문에 당사자소송 중 확인소송은 무효등확인소송과 달리 즉시확정의 이익이 요구된다. 당사자소송은 국가, 공공단체 그 밖의 권리주체를 피고로 하며 행정청이 피고가 되지 않는다.

스터디파이터 _ 답안작성과 함께 하는 행정법 기본강의 10회

<p.173 ~ p.179 행정상 손해배상>

01. <기출24회 2-1>

甲은 S시에 임야 30,000㎡를 소유하고 있다. S시장은 甲 소유의 토지에 대하여 토지의 이용 상황을 실제 이용되고 있는 '자연림'으로 하여 개별공시지가를 산정한 다음 A감정평가법인에 검증을 의뢰하였는데, A감정평가법인이 그 토지의 이용상황을 '공업용'으로 잘못 정정하여 검증지가를 산정하고, 시(市) 부동산가격공시위원회가 검증지가를 심의하면서 그 잘못을 발견하지 못하였다. 이에 따라 甲소유 토지의 개별공시지가가 적정가격 보다 훨씬 높은 가격으로 결정, 공시되었다 B은행은 S시의 공시지가를 신뢰하고, 甲에게 70억 원을 대출하였는데, 甲이 파산함에 따라 채권회수에 실패하였다.

B은행은 S시를 대상으로 국가배상을 청구하였다. S시의 개별공시지가 결정행위가 국가배상법 제2조상의 위법행위에 해당하는가에 관하여 논하시오. (20점)

부동산 가격공시에 관한 법률 (약칭: 부동산공시법)

제10조(개별공시지가의 결정·공시 등) ① 시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용 되도록 하기 위하여 제25조에 따른 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격(이하 "개별공시지가"라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 표준지로 선정된 토지, 조세 또는 부담금 등의 부과 대상이 아닌 토지, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지에 대하여는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.

③ 시장·군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 분할·합병 등이 발생한 토지에 대하여는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.

④ 시장·군수 또는 구청장이 개별공시지가를 결정·공시하는 경우에는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지

가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하되, 해당 토지의 가격과 표준지공시지가가 균형을 유지하도록 하여야 한다.

⑤ 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 지가의 변동상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 감정평가법인등의 검증을 생략할 수 있다. <개정 2020. 4. 7.>

⑥ 시장·군수 또는 구청장이 제5항에 따른 검증을 받으려는 때에는 해당 지역의 표준지의 공시지가를 조사·평가한 감정평가법인등 또는 대통령령으로 정하는 감정평가실적 등이 우수한 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다. <개정 2020. 4. 7.>

⑦ 국토교통부장관은 지가공시 행정의 합리적인 발전을 도모하고 표준지공시지와 개별공시지가의와의 균형유지 등 적정한 지가형성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 개별공시지가의 결정·공시 등에 관하여 시장·군수 또는 구청장을 지도·감독할 수 있다.

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 것 외에 개별공시지가의 산정, 검증 및 결정, 공시기준일, 공시의 시기, 조사·산정의 기준, 이해관계인의 의견청취, 감정평가법인등의 지정 및 공시절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2020. 4. 7.>

제12조(개별공시지가의 정정) 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.

목차

I. 쟁점의 정리

II. 국가배상책임의 성립요건(국가배상법 제2조)

III. 국가배상법 제2조상 위법행위

1. 국가배상법의 위법의 개념
 - 1) 학설
 - 2) 판례 및 검토
2. 법령의 의미
3. 관련규정의 검토
 - 1) 부동산공시법 제10조 제1항
 - 2) 동법 제10조 제4항
 - 3) 동법 제10조 제5항

IV. 사안의 해결

1. 법령위반 여부
2. 기타 국가배상책임 요건 검토

I. 쟁점의 정리

부동산공시법 10조의 개별공시지가 결정행위가 국가배상법 제2조상의 위법행위에 해당 하는지 성립요건을 검토한다.

II. 국가배상책임의 성립요건(국가배상법 제2조)

①공무원이 ②직무를 집행하면서 ③고의 또는 과실로 ④법령에 위반하여 ⑤타인에게 손 해를 가한 때에 ⑥공무원의 위법행위와 손해 상이 인관관계가 있으면 국가배상책임이 발생한다.

III. 국가배상법 제2조상 위법행위

1. 국가배상법의 위법의 개념

1) 학설

- ① 국가배상법상의 위법은 공무원의 직무행위가 '법 규범'에 적합한지를 기준으로 판단 하여야 한다고 보는 <협의의 행위위법설>.
- ② '법령 위반' 뿐만 아니라 인권존중·권력남용 금지의 원칙·신의성실의 원칙의 위반도 포함된다고 보는 <광의의 행위위법설>
- ③ 가해행위의 결과로 국민이 받은 손해를 국민 이 수인하여여 하는가를 기준으로 판단하는 <결과불법설> 및 ④ 직무행위의 적법·위법 뿐만 아니라, 피침해이익의 성격과 침해의 정도, 가해행위의 태양 등을 종합 고려하여야 한다고 보는 <상대적 위법성설>이 있다.

2) 판례 및 검토

①시위자들의 화염병으로 인해 발생한 약국화재 사건에서 결과불법설을 배제하고 국가 배상의 위법을 법령의 위반을 기준으로 판시한 바 있다. 이 판례와 같이 <행위위법설> 이 주류적인 입장이다. 다만, 상대적 위법성설 입장에서 피침해이익의 종류 및 성질, 침 해행위가 되는 행정처분의 태양 및 그 원인, 행정처분의 발동에 대한 피해자측의 관여 의 유무, 정도 및 손해의 정도 등 제반 사정을 종합하여 손해의 전보책임을 판단하여야 한다고 보는 판례도 있다. ②손해배상은 위법행위에 대한 전보수단으로, 적법행위로 발 생한 손실에 대한 전보수단인 손실보상과 구별되고, 취소소송에서 위법의 본질이 법규 위반인 점을 고려할 때 국가배상도 위법의 개념을 '법질서 위반'이라는 단일한 가치판단 기준으로 보아야 하며, 국민의 권리구제 확대를 위해 <광의의 행위위법설>의 입장이 타당하다.

2. 법령의 의미

관습법, 조리 등이 법령에 포함되는지에 대해 견해가 대립하나, '법 일반'을 의미한다고 보는 것이 일반적인 견해(행위위법설 입장)이고, 법 일반에는 성문법뿐만 아니라 관습법, 법의 일반원칙, 조리 등불문법도 포함된다.

3. 관련규정의 검토

1) 부동산공시법 제10조 제1항

시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 제25조에 따른 시·군·구부

동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

2) 동법 제10조 제4항

시장·군수 또는 구청장이 개별공시지가를 결정·공시하는 경우에는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하되, 해당 토지의 가격과 표준지공시지가가 균형을 유지하도록 하여야 한다.

3) 동법 제10조 제5항

시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

IV. 사안의 해결

1. 법령위반 여부

S시장은 부동산공시법 10조 및 12조에 따라 개별공시지가의 검증 및 정정 의무가 있다. S시장은 이용상황의 명백한 오류를 정정하지 못하였고, 부동산가격공시위원회가 검증지가를 심의하면서 그 잘못을 발견하지 못하였다. 이는 부동산공시법령을 위반한 것이다.

2. 기타 국가배상책임 요건 검토(추가논의)

① S시장의 개별공시지가 결정고시 행위는 공무원의 직무상 행위이다. ② 제시된 문언상 법령위배행위에 S시의 고의가 있다고 보기 어려우나, 검증절차의 잘못을 발견하지 못한 것은 직무상 주의의무를 위반한 것으로, 과실이 인정된다. ③ B은행에 손해가 발생하였으나 ④ 공무원의 위법행위와 B은행의 손해 사이 인과관계가 있는지는 별도 논의가 필요하다. 판례는 부동산공시법 입법취지와 개별공시지가 기능상 양자의 인과관계를 부정한 바 있다.

<p.173 ~ p.179 행정상 손해배상>

02. <기출24회 2-2>

甲은 S시에 임야 30,000㎡를 소유하고 있다. S시장은 甲 소유의 토지에 대하여 토지의 이용 상황을 실제 이용되고 있는 '자연림'으로 하여 개별공시지가를 산정한 다음 A감정평가법인에 검증을 의뢰하였는데, A감정평가법인이 그 토지의 이용상황을 '공업용'으로 잘못 정정하여 검증지가를 산정하고, 시(市) 부동산가격공시위원회가 검증지가를 심의하면서 그 잘못을 발견하지 못하였다. 이에 따라 甲소유 토지의 개별공시지가가 적정가격 보다 훨씬 높은 가격으로 결정, 공시되었다 B은행은 S시의 공시지가를 신뢰하고, 甲에게 70억 원을 대출하였는데, 甲이 파산함에 따라 채권회수에 실패하였다.

S시장은 개별공시지가제도의 입법목적은 이유로 S시 담당공무원들의 개별공시지가 산정에 관한 직무상 행위와 B은행의 손해사이에 상당 인과관계가 없다고 항변한다. S시장의 항변의 타당성에 관하여 논하시오. (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 상당인과관계 의미 및 판단기준

III. 개별공시지가제도의 입법목적

IV. 개별공시지가의 구속력의 범위

V. 관련판례

VI. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

개별공시지가제도의 입법목적과 판례를 중심으로 S시 담당공무원들의 직무상 위법행위와 B은행의 손해 사이 상당 인과관계가 있는지 검토한다.

II. 상당인과관계 의미 및 판단기준

상당인과관계는 전자가 없었더라면, 후자도 없었을 관계를 의미한다. 상당인과관계의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 직무상 의무를 부과하는 법령을 비롯한 행동규범의 목적, 가해행위의 양태와 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

III. 개별공시지가제도의 입법목적

부동산공시법 1조는 “부동산의 적절한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.”고 규정한다. 동법 10조는 “국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 개별공시지가를 결정·공시한다.”고 규정한다.

IV. 개별공시지가의 구속력의 범위

개별공시지가는 그 산정 목적인 개발부담금의 부과, 토지 관련 조세 부과 등 다른 법령이 정하는 목적을 위해 지가를 산정하는 경우에 그 산정 기준이 되는 범위 내에서는 납세자인 국민 등의 재산상 권리·의무에 직접적인 영향을 미칠 수 있지만, 이에 더 나아가 개별공시지가가 당해 토지의 거래 또는 담보제공을 받음에 있어 그 실제 거래가액 또는 담보가치를 보장한다거나 어떠한 구속력을 미친다고 할 수는 없다.

V. 관련판례

판례는 개별공시지가가 토지의 거래 또는 담보제공을 받음에 있어 실제 거래가액 또는 담보가치를 보장한다거나 djE한 구속력을 미친다고 할 수 없다고 보아, 상당인과관계를 부정하였다.

VI. 사안의 해결

B은행은 구속력이 미치지 않는 담보가치 산정 목적으로 개별공시지가를 신뢰하였고 이로 인하여 손해가 발생하였다. 따라서 개별공시지가 산정에 관한 S시 담당공무원들의

직무상 위법행위와 위 손해사이에는 상당인과관계가 없다. S시장의 항변은 타당하다.

<p.173 ~ p.179 행정상 손해배상>

03. <기출25회3>

법원으로부터 근저당권에 근거한 경매를 위한 감정평가를 의뢰받은 감정평가사 乙이 감정평가 대상토지의 착오로 실제 대상토지의 가치보다 지나치게 낮게 감정평가액을 산정하였다. 토지소유자인 甲이 이에 대해 이의를 제기하였음에도 경매담당 법관 K는 乙의 감정평가액을 최저입찰가격으로 정하여 경매절차를 진행하였으며, 대상토지는 원래의 가치보다 결국 낮게 丙에게 낙찰되어 甲은 손해를 입게 되었다.

甲이 법관의 과실을 이유로 국가배상을 청구한 경우 이 청구의 인용가능성을 검토하시오. (15점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 국가배상책임의 의의 및 요건

III. 사법작용과 국가배상

1. 학설
2. 판례
3. 검토

IV. 위법성 검토

V. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

국가배상법 제2조의 '공무원'에 법관도 포함되고, 재판행위도 직무에 해당한다. 그러나 법관의 재판행위의 결과인 확정판결이 있으면 기판력이 발생되므로 재판행위에 대해 국

가배상청구가 가능한지가 문제 된다.

II. 국가배상책임의 의의 및 요건

①공무원이 ②직무를 집행하면서 ③고의 또는 과실로 ④법령에 위반하여 ⑤타인에게 손해를 가한 때에 ⑥공무원의 위법행위와 손해 사이 인관관계가 있으면 국가가 이를 배상해주는 제도를 의미한다. 법적성질에 대해 견해대립이 있으나, 판례는 민법의 특별법으로 본다. 사안의 경우 법관도 특정직공무원이고, 경매절차 진행은 법관의 직무행위이며 소유자인 甲의 이의제기에도 불구하고 당해 감정평가액을 최저입찰가격으로 경매절차를 진행한바 통상 주의의무를 간과한 경과실이 인정된다. 이하 사법작용이 국가배상청구의 대상이 되는지와 위법성을 검토한다.

III. 사법작용과 국가배상

1. 학설

① 국가배상책임을 인정하여도 확정판결의 기판력을 침해하는 것은 아니라는 <국가배상청구 긍정설>, ② 국가배상책임을 인정하는 것이 확정판결의 효력을 부정하는 것은 아니지만, 판결의 위법성이 인정되어야 하고, 이는 기판력을 침해하는 것이므로 부정하는 <국가배상청구 부정설> 및 ③ 재판행위의 특수성을 고려하여 법적 안정성과 국민의 권리구제를 적절히 조화시켜 제한적으로 인정하여야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

2. 판례

판례는 법관의 재판행위에 국가배상책임이 인정되려면 당해 법관이 위법 또는 부당한 목적을 가지고 재판을 하였다거나 법관이 그에게 부여된 권한의 취지에 명백히 어긋나게 이를 행사하였다고 인정할 만한 특별한 사정이 있어야 한다고 하여 제한적으로 인정하고 있다.

3. 검토

재판행위의 특수성은 국가배상의 성립요건인 위법성 또는 고의·과실의 판단과정에서 고려될 수 있으며, 법관도 공무원이고 재판행위도 직무에 포함되므로 <국가배상청구 긍정설>에 따라 위법한 재판행위에 대해 국가배상청구가 가능하다고 보는 것이 타당하다.

IV. 위법성 검토

① 국가배상법은 배상책임의 요건으로 '법령의 위반'을 요구한다. 여기에서 '법령'은 '법 일반'을 의미한다고 보는 것이 일반적인 견해(행위위법설 입장)이고, 법 일반에는 성문법 뿐만 아니라 관습법, 법의 일반원칙, 조리 등 불문법도 포함된다. '위반'의 의미에 대해서는 행위위법설, 결과위법설 등 견해 대립이 있는데, 손해배상은 위법행위에 대한 손해전보 수단이며, 취소소송에서 위법의 본질이 법규 위반인 점을 고려할 때 국가배상도 위법에 개념을 '법질서 위반'이라는 단일한 가치판단을 기준으로 보아야 하므로 법규범의 위반을 기준으로 판단하는 <행위위법설>이 타당하다. ② K법관의 지나치게 낮은 감정평가액을 기초한 최저입찰가격 결정은 민사집행과 관련한 법규범 위반에 해당하고, 객관적 주의의무를 위반한 것으로 보여 위법하다.

V. 사안의 해결

사법행위도 국가배상법상 직무행위로 볼 수 있는바, 특정직 공무원인 K법관의 직무행위인 경매절차 행위가 있었고, 객관적 주의의무 위반인 경과실로 관련 법령에 위반하여 토지소유자 甲에게 손해가 발생하였다. K법관의 위법행위와 甲의 손해사이 상당인과관계가 있는바, 甲의 국가배상청구는 인용가능성이 있다.

<p.173 ~ p.179 행정상 손해배상>

04. <기출25회3 변형>

법원으로부터 근저당권에 근거한 경매를 위한 감정평가를 의뢰받은 감정평가사 乙이 감정평가 대상토지의 착오로 실제 대상토지의 가치보다 지나치게 낮게 감정평가액을 산정하였다. 토지소유자인 甲이 이에 대해 이의를 제기하였음에도 경매담당 법관 K는 乙의 감정평가액을 최저입찰가격으로 정하여 경매절차를 진행하였으며, 대상토지는 원래의 가치보다 결국 낮게 丙에게 낙찰되어 甲은 손해를 입게 되었다.

법관의 과실을 이유로 국가배상청구가 인정된다면 甲은 국가배상청구 외에 별도로 K법관에게 손해배상책임을 물을 수 있는지 논하시오. (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 국가배상법 2조의 법적성질

III. 공무원의 배상책임

1. 학설
2. 판례
3. 검토

IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

헌법 제29조 제1항 단서는 공무원 개인의 책임은 면제되지 않는다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 국가배상책임에서 가해 공무원 개인도 피해자에 대해서 배상책임을 지는지가 문제 된다.

II. 국가배상법 2조의 법적성질

① 학설은 피해자 구제를 위하여 국가가 대신하여 책임을 지는 것으로 보는 <대위책임설>, 배상책임은 국가 등의 자기책임이라고 보는 <자기책임설> 및 공무원의 위법행위가 경과실인 경우에는 공무원의 행위는 국가 행위이므로 국가가 자기책임으로서 배상 책임을 지지만, 고의 또는 중과실에 의한 것일 때에는 기관의 행위로서 품격을 상실하므로 원칙적으로 공무원 개인의 책임이나, 피해자 구제를 위해 국가가 대신하여 책임지는 것이라고 보는 <절충설>이 있다. ② 판례는 <절충설>의 입장을 취한다.

III. 공무원의 배상책임

1. 학설

① 국가배상책임을 자기책임으로 보는 입장에서 국가와 공무원 개인의 책임은 독립해서 성립되고, 피해자의 권리구제를 폭넓게 보장하기 위하여 선택적 청구권 행사를 긍정하는 <긍정설>, ② 국가배상책임을 대위책임으로 보는 입장에서 공무원의 직접책임을 인정하는 것은 공무원의 직무집행을 위축시킬 우려가 있으므로 선택적 청구권 행사를 부정하는 <부정설> 및 ③ 경과실에 기한 것인 경우는 여전히 기관행위이므로 국가만이 책임을 지고, 고의·중과실인 경우에는 공무원 개인의 불법행위로 보아 선택적 청구권을 긍정하는 <제한적 긍정설>이 있다.

2. 판례

판례는 공무원이 직무를 수행함에 있어 경과실로 타인에게 손해를 입힌 경우에는 여전히 국가 등의 기관의 행위로 보아 그로 인하여 발생한 손해에 대한 배상책임도 전적으로 국가 등에만 귀속시키고, 반면에 공무원의 위법행위가 고의·중과실에 기한 경우에는 기관행위로서의 품격을 상실하여 국가 등에게 그 책임을 귀속시킬 수 없으므로 공무원 개인에게 불법행위로 인한 손해배상책임을 부담시켜야 한다고 하여 <제한적 긍정설>의 입장을 취한다.

3. 검토

헌법 제29조 제1항 단서에서 공무원의 책임이 면제되지 않는다고 규정하고 있으나 구체적인 손해배상책임을 범위까지 규정하고 있지는 않고, 국가배상법은 공무원의 내부적 책임만 규정하고 있을 뿐 외부적 책임에 대해서는 규정한 바 없다. 따라서 양자를 조화롭게 해석하고 공무원의 직무집행행위를 위축시키지 않기 위해서 고의·중과실의 경우에만 공무원 개인의 책임을 인정하는 <제한적 긍정설>이 타당하다.

IV. 사안의 해결

1. K법관의 중과실

과실은 평균인이 통상 갖추어야 할 주의의무를 게을리 하는 것을 의미한다. 과실이 인정되기 위해서는 위험·손해발생에 대한 예측가능성과 회피가능성이 있어야 한다. 법관 K는 소유자인 甲이 이의제기하였을 때 위법한 최저입찰가격 결정 가능성에 대한 예측가능성과 회피가능성이 모두 있었다. 또한 K는 甲의 이의제기 시 약간의 주의를 하였더라면 甲의 손해를 방지할 수 있었으므로 중과실이 있다.

2. K법관의 손해배상책임(甲은 K에게 별도 손해배상책임을 물을 수 있음)

제한적 긍정설 입장에서 고의·중과실인 경우 공무원 개인의 불법행위로 보아 선택적 청구권을 긍정하는바, 甲은 국가배상청구 외에 별도로 법관 K에게 손해배상책임을 물을 수 있다.

<p.183 ~ p.186 조합설립인가>

05. <기출25회 1-1>

S시의 시장 A는 K구의 D지역(주거지역)을 도시 및 주거환경정비법(이하 '도정법')상 정비구역으로 지정·고시하였다. 그러자 이 지역의 주민들은 조합을 설립하여 주택재개발사업을 추진하기 위해 도정법에서 정한 절차에 따라 조합설립추진위원회를 구성하였고, 동 추진위원회는 토지등소유자의 동의, 정관, 공사비 등 정비사업에 드는 비용과 관련된 자료 등을 첨부하여 A로부터 X조합설립인가를 받아登記하였다. X조합은 조합총회를 개최하고 도정법상 토지등 소유자 동의를 얻어 지정개발자로서 Y를 사업시행자로 지정하였다. D지역의 토지소유자 중 甲이 "추진위원회가 주민의 동의를 얻어 X조합을 설립하는 과정에서 '건설되는 건축물의 설계의 개요' 등에 관한 항목 내용의 기재가 누락되었음에도 이를 유효한 동의로 처리하여 조합설립행위에 하자가 있다."고 주장하며 행정소송으로 다투려고 한다. 이 경우 조합설립인가의 법적 성질을 검토한 다음, 이에 기초하여 쟁송의 형태에 대해 설명하시오. (20점)

목차
I. 쟁점의 정리 II. 조합설립인가의 법적 성질 1. 학설 2. 판례 3. 검토 III. 쟁송의 형태 1. 판례 2. 검토 IV. 사안의 해결

I. 쟁점의 정리

조합설립인가가 강학상 인가인지, 특허인지 검토하고, 이에 따라 조합설립행위에 대한 효력을 다투는 소송을 제기하여야 하는지, 설립행위의 하자를 이유로 조합설립인가처분의 효력을 다투는 소송을 제기하여야 하는지 검토한다.

II. 조합설립인가의 법적 성질

1. 학설

조합설립인가의 법적성질에 대해 ① 조합설립행위를 기본행위로 보고, 인가는 이를 보충하여 법률상의 효과를 완성시키는 보충행위로서 <강학상 인가>로 보는 견해와 ② 조합설립행위를 조합설립인가를 받기 위한 필요 요건으로 보고, 인가는 조합을 행정주체로 설정하는 행위로서 <강학상 특허>로 보는 견해가 있다.

2. 판례

①종래에는 조합설립인가를 제3자의 법률행위를 보충하여 그 법률상의 효과를 완성시키는 보충행위라고 보았다. 즉, 조합설립행위는 사법행위로서 기본행위이고, 시장 등의 조합설립인가는 기본행위의 효력을 완성시켜주는 보충행위로서 <강학상 인가>로 보는 입장을 취했다. ②최근에는 판례를 변경하여 조합설립인가처분을 도시정비법상 재건축사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체로서의 지위를 부여하는 설권적 처분으로 보고, 조합설립행위는 인가처분을 위한 요건 중에 하나라고 판시한 바 있다.

3. 검토

조합설립인가가 있으면 조합은 사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체의 지위를 갖게 되므로 조합설립인가를 특허로 보는 것이 타당하다.

III. 쟁송의 형태

1. 판례

①종래에는 조합설립인가를 강학상 인가로 보아 기본행위인 조합설립에 하자가 있는 경우에는 민사쟁송으로써 따로 그 기본행위의 취소 또는 무효확인 등을 구하는 것은 별론으로 하고 기본행위의 불성립 또는 무효를 내세워 바로 그에 대한 감독청의 인가처분의 취소 또는 무효확인을 소구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다고 판시하였으나, ②최

근에는 조합설립인가를 강학상 특허로 보는 입장에서 조합설립결의에 하자가 있다면 그 하자를 이유로 직접 항고소송의 방법으로 조합설립인가처분의 취소 또는 무효확인을 구하여야 한다고 판시한다.

2. 검토

① 조합설립인가처분을 <인가>로 보는 견해에 의하면 사법상 법률행위인 조합설립행위를 직접 민사소송으로 다룰 수 있고, <판례 및 특허>로 보는 견해에 의하면 조합설립행위의 하자를 이유로 조합인가처분을 대상으로 항고쟁송으로 다룰 수 있을 것이다. ② 조합설립인가를 특허로 보는 것이 타당한바, 조합설립행위에 하자가 있다면 이는 인가처분의 요건에 하자가 있는 것이므로 그 하자를 이유로 인가처분을 직접 대상으로 하여 항고쟁송을 제기하여 다투는 것이 타당하다.

IV. 사안의 해결

甲 주장에 의하면 조합설립인가처분은 적법한 요건을 결한 것으로 위법하다. 따라서 甲은 조합설립인가처분에 대한 취소소송 또는 무효등확인소송을 제기할 수 있다.

<p.192 ~ p.193 매도청구소송>

06. <기출28회3>

지목은 대(垓)이지만, 그 현황이 인근 주민의 통행에 제공된 사실상 도로인 토지를 대상으로 도시 및 주거환경정비법에 따른 매도청구권을 행사하는 경우와 토지보상법에 따른 수용재결이 행하여지는 경우에 관하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

1) 매도청구권 행사에 따른 쟁송절차와 수용재결에 따른 보상금을 다투는 쟁송절차의 차이점을 설명하시오. (10점)

목차

<물음1 (10점)>

I. 매도청구소송과 보상금을 다투는 쟁송절차

1. 매도청구소송(「도시정비법」제64조)
2. 보상금을 다투는 쟁송절차

II. 각 쟁송절차의 차이점

1. 소송형태 및 관할법원
2. 절차 및 제소기간
3. 원고와 피고

<물음2 (10점)>

I. 기준시점 (가격시점)

II. 개발이익

III. 사실상 사도

2) 토지의 감정평가방법과 그 기준에 있어 매도청구권이 행사되는 경우와 수용재결이 행하여지는 경우의 차이점을 설명하시오. (10점)

<물음1 (10점)>

I. 매도청구소송과 보상금을 다투는 쟁송절차

1. 매도청구소송(「도시정비법」 제64조)

매도청구권은 사업시행자가 조합설립이나 사업시행자 지정에 동의 않은 토지등소유자(현금청산자)를 상대로 토지의 소유권과 그 밖의 권리를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 매도청구권은 형성권으로 청구권 행사시 매매계약이 성립한 것으로 본다.

2. 보상금을 다투는 쟁송절차

수용재결에 따른 쟁송절차는, 이의신청(토지보상법 제83조), 보상금증감청구소송(동법 제85조 제2항)이 있다.

II. 각 쟁송절차의 차이점

1. 소송형태 및 관할법원

① 매도청구를 둘러싼 법률관계는 사법상의 법률관계로서 그 매도청구권 행사에 따른 소유권이전등기의무의 존부를 다투는 소송인 매도청구소송은 민사소송이다. 따라서 관할 법원은 민사법원이 된다. 반면에, ② 토지보상법 제85조 제2항에 따라 제기하는 보상금증감청구소송은 공법상 당사자소송이며, 사업시행자와 피수용자가 각각 피고 또는 원고가 되어 보상금을 다투는 소송이므로 형식적 당사자소송에 해당한다. 따라서 행정법원이 관할 법원이 된다.

2. 절차 및 제소기간

① 매도청구권의 경우 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 30일 이내에 미동의자에게 동의 여부를 회답할 것을 촉구하고, 미동의자가 2개월 이내에 회답하지 않으면 부동의하는 것으로 보고 2개월 이내에 매도를 청구할 수 있다. 반면에, ② 보상금증감청구소송은 토지보상법 제85조 제1항의 제소기간이 적용되어 재결서 정본 송달일로부터 90일, 이의재결서 정본 송달일로부터 60일 이내 각각 소송을 제기할 수 있다.

3. 원고와 피고

① 매도청구소송의 원고는 재건축조합이 되고 피고는 조합설립에 동의하지 아니한 자가 된다. 반면에, ② 보상금증감청구소송은 사업시행자와 피수용자가 각각 원고와 피고가

된다.

<물음2 (10점)>

I. 기준시점 (가격시점)

① 매도청구에 따른 감정평가는 도시정비법 제64조에 따라 매매계약 성립일을 기준으로 하고, ② 수용재결의 경우 토지보상법 제67조 제1항에 따라 수용재결일이 가격시점이 된다.

II. 개발이익

① 매도청구에 따른 감정평가는 보상평가가 아니고 일반 시가평가이다. 여기에서 '시가'란 시가란 매도청구권이 행사된 당시의 토지나 건물의 객관적 거래가격으로서 재건축으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 개발이익이 포함된 가격을 말한다. 반면에, ② 수용재결을 위한 보상평가는 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다고 규정하고 있는 토지보상법 제67조 제2항에 따라 개발이익을 포함하지 않는다.

III. 사실상 사도

① 매도청구권 행사에 따른 평가는 시가평가이며 판례는 '토지의 현황이 도로일지라도 재건축사업이 시행될 것을 전제로 할 경우의 인근 대지 시가와 동일하게 평가하되, 각 토지의 형태, 주요 간선도로와의 접근성, 획지조건 등 개별요인을 고려하여 감액 평가하는 방법으로 산정하는 것이 타당하다'고 판시하고 있다. 반면에, ② 수용재결을 위한 보상평가는 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 2호에 의거 인근토지에 대한 평가액의 1/3 이내로 평가하여야 한다.

<p.194 이전고시>

07. <기출33회 1-1>

X는 도시 및 주거환경정비법 (이하 '도시정비법'이라 함)에 따른 재개발정비사업 조합이고, 甲은 X의 조합원으로서, 해당 정비사업구역 내에 있는 A토지와 B토지의 소유자이다. A토지와 B토지는 연접하고 있고 그 지목이 모두 대(垓)에 해당하지만, A토지는 사도법 에 따른 사도가 아닌데도 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 왔고, B토지는 甲이 소유한 건축물의 부지로서 그 건축물의 일부에 임차인 乙이 거주하고 있다. X는 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간을 공고하였으나 甲은 그 기간 내에 분양신청을 하지 않았다. 이에 따라 X는 甲을 분양대상자에서 제외하고 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았고, 그에 불복하는 행정심판이나 행정소송은 없었다. X는 도시정비법 제73조 제1항에 따른 甲과의 보상협정이 이루어지지 않자 A토지와 B토지에 관하여 관할 토지수용위원회에 수용재결을 신청하였고, 관할 토지수용위원회는 A토지와 B토지를 수용한다는 내용의 수용재결을 하였다. 甲이 수용재결에 대한 취소소송을 제기하면서, 'X가 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간과 그 기간 내에 분양신청을 할 수 있다는 취지를 명백히 표시하여 통지하여야 하는데도 이러한 절차를 제대로 거치지 않았다'고 주장할 경우에, 甲의 주장이 사실이라면 법원은 그것을 이유로 수용재결을 취소할 수 있는지 설명하시오. (단, 사실심 변론종결 전에 도시정비법에 따른 이전고시가 효력을 발생한 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하여 설명할 것) (10점)

목차

I. 쟁점의 정리

II. 수용재결의 의의, 근거, 취지(토지보상법 34조, 50조)

III. 이전고시의 개념

IV. 소송요건 검토

V. 분양신청 통지 흠결을 수용재결의 취소사유로 주장할 수 있는지

VI. 이전고시가 효력을 발생한 경우

VII. 이전고시가 효력을 발생하지 않은 경우

I. 쟁점의 정리

소송요건 검토 후 법원은 분양신청 통지 절차의 하자를 이유로 당해 수용재결을 취소할 수 있는지 이전고시 효력 발생 유무에 따라 검토한다.

II. 수용재결의 의의, 근거, 취지(토지보상법 34조, 50조)

수용재결은 사업인정고시 후 협의 불성립 시 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용결정의 최종적 판단절차이다. 공익사업의 원활한 진행에 취지가 있고, 수용재결은 처분으로 취소소송의 대상이 된다.

III. 이전고시의 개념

이전고시는 도정법 86조 등에 근거를 둔 절차로 주공 후 대지, 건축물의 소유권 이전에 관한 고시를 의미한다.

IV. 소송요건 검토

수용재결을 처분으로 대상적격(행정소송법 19조)이 인정되며, 甲은 처분의 당사자로 원고적격(동법12조 전문)이 있으며, 협의 소익(동법12조 후문)은 이전고시 효력발생 유무에 따라 별도 검토가 필요하다. 나머지 소송요건은 특별히 문제되지 않는 것으로 판단된다.

V. 분양신청 통지 흠결을 수용재결의 취소사유로 주장할 수 있는지

판례는 분양신청기간의 통지 등 절차는 재개발구역 내의 토지 등의 소유자에게 분양신청의 기회를 보장해 주기 위한 것으로서 토지수용을 하기 위하여 반드시 거쳐야 할 필요적 절차이고, 그 통지를 함에 있어 분양신청기간과 그 기간 내 분양신청을 할 수 있다는 취지를 명백히 표시하여야 하며 그렇지 않고 이루어진 수용재결은 위법하다고 보았다. [2004두6235]

VI. 이전고시가 효력을 발생한 경우

①판례는 이전고시의 효력 발생으로 이미 대다수 조합원 등에 대하여 획일적·일률적으로 처리된 권리귀속 관계를 모두 무효화 하고 다시 처음부터 관리처분계획을 수립하여 이전고시 절차를 거치도록 하는 것은 정비사업의 공익적·단체법적 성격에 배치되므로, 이전고시가 효력을 발생하게 된 이후에는 조합원 등이 관리처분계획의 취소 또는 무효 확인을 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 타당하다고 판시한바 있다. ②생각건대, 이전고시의 효력이 발생한 경우 정비사업의 공익적·단체법적 성격 상 관리처분계획의 취소 또는 무효 확인을 통해 甲이 회복할 수 있는 법률상 이익이 없는바, 甲의 주장이 사실이라 하더라도 법원은 그것을 이유로 수용재결을 취소할 수 없다.

VII. 이전고시가 효력을 발생하지 않은 경우

이전고시가 효력을 발생하지 않은 경우 甲의 주장이 사실이라면 법원은 그것을 이유로 수용재결을 취소할 수 있다.

행정법 총론 한눈에 보기

목차				논의 실익	취소소송				
					소송요건	심리(본안판단)	판결	판결의효력	기타
					본안심리를 받기 위한 요건 대상적격(19)원고적격(12전)소익(12후) 피고적격(13)제소기간(20)관할(9)전치(18)	위법성 판단	각하/ 기각/ 인용		가구제: 집행정지
PART1	제1장	행정과 행정법	행정법 개념, 특성,						
	제2장	행정의 법원	성문법원(헌법, 법률, 명령, 자치법규) 불문법원(행정관습법, 판례법, 조리 등)	본안판단은 결국 '위법성'판단인데, 무엇을 "법"으로 볼 것인지 결정돼야, 위"법"성을 판단할 수 있다.		<개별법>과 <명령> 중요. 기속행위는 법에 기속되는바, 법과 다르면 위법. 재량행위는 재량의 일탈남용 판단.			
	제3장	행정의 법원칙	법치행정의 원칙 평등의 원칙 비례 원칙 성실의무 및 권한남용금지 원칙 신뢰보호 원칙 부당결부금지의 원칙	대표적 불문법(조리=상식)이었음. (현재 행정기본법8조~13조에 성문화됨)		재량의 일탈남용 판단 시 기준이 된다.			
	제4장	행정법 관계	공법관계와 사법관계 행정법 관계의 당사자 공권, 사인의 공법행위	->소송형태 결정에 영향을 미침 ->처분의 개념요소를 이해하는 데 도움 ->원고적격/신청권 이해에 도움	개인적 공권은 원고적격의 법률상 이익/ 거부처분이나 부작위에서의 신청권과 관련있다.				
PART2	제1장	행정입법	법규명령 행정규칙 형식과 실질의 불일치(중요)	법규성 인정여부에 따라 본안판단이 달라질 수 있다.		예) 법규성 인정 시 해당 법규명령 (혹은 행정규칙)위반으로 위법			
	제2장	행정행위	행정행위 행정행위 요건과 효력 행정행위 하자(무효/취소) (절차 하자/내용상 하자) (치유는 절차 하자이면서 취소에만) 하자승계(선후행정행위 선행행위 취소+불가쟁력, 후행위 적법) 행정행위 직권취소/철회/실효 행정행위의 부관 확약	->소송요건 중 대상적격 문제 ->본안판단의 문제 ->본안판단의 문제 ->(본안판단)하자승계 유형별 판례 암기 ->직권취소/철회의 제한(본안판단) ->대상적격/소송형태/본안판단 확약	※대상적격 검토 행정행위 직권취소/철회 부관의 종류(부담만 독립쟁송 가능)	행정행위 요건(주체/절차/형식/내용) 행정행위의 하자(무효/취소) 행정행위 유형 (주체/절차/형식/내용상 하자) 직권취소/철회의 제한 부관의 부작가능성/독립취소가능성			
	제3장	행정계획	법적성질/계획재량/계획보장청구권/	대상적격과 위법성 판단의 특수성	대상적격이 인정되는 행정계획 -도시군관리계획, 관리처분계획	형량명령			

행정법 총론 한눈에 보기

목차				논의 실익	취소소송				
					소송요건	심리(본안판단)	판결	판결의효력	기타
PART3	제1장	행정절차법	사전통지/의견청취/이유제시/ 절차상 하자(독자적 위법성, 위법성정도, 절차하자와 기속력)	위법성 판단의 주체/절차/형식/내용 중 절차적 위법성 판단(본안판단)		절차 위반/독자적 위법성		절차하자에 기속력 준용	
	제2장	행정의 실효성 확보수단	대집행/과징금/명단공표/행정조사	각 수단의 법적성질 -소송요건 중 대상적격 논의 각 수단의 요건검토 -요건 미비 위법	대집행 각 절차 대상적격 인정 (계통실비) 과징금(급부하명)/ 명단공표(비권력적사실행위-> 일반적으로 대상적격 불인정) 행정조사(권력적조사는 대상적격인정)				
PART4	제2장	행정심판	이의신청/행정심판 종류, 청구기간,재결/ 가구제(집행정지,임시처분)/ 고지제도	이의신청과의 구별 원처분과 재결의 대상적격 문제	원처분주의 재결의 고유한 하자(예-제3자효 수반하 는 행정행위에 대한 행정심판 재결)	재결의 고유한 하자는 본안판단 문제			
	제3장	행정소송	취소소송(소송요건/가구제/심리/ 판결/효력/간접강제) 무효등확인소송/ 부작위위법확인소송/ 당사자소송	행정법총론은 행정작용에 대한 권리구제가 핵심이며 권리구제는 존속보장->손해전보 순이 국민의 권익구제에 유리하다. 존속보장을 위한 대표적 구제수단이 항고소송이며 행정소송법에서 취소소송 중심으로 규정된바, 취소소송의 이해가 중요하다.		집행정지 처분사유의 추가변경			